BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

LÊ THANH LÂM

XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH CỐ ĐẤT THEO TẬP QUÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

LÊ THANH LÂM

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422073

XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH CỐ ĐẤT THEO TẬP QUÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

PGS. TS. GVCC. PHAN TRUNG HIỀN

TS. NGUYỄN LAN HƯƠNG

NĂM 2024

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Khoa Luật, Khoa Sau đại học của Trường Đại học Cần Thơ, Quý Thầy Cô thuộc đơn vị Khoa Luật và các đơn vị tham gia giảng dạy, truyền đạt cho tôi những kiến thức hữu ích liên quan đến ngành Luật Kinh tế, đó chính là cơ sở quan trọng để tôi hoàn thành luận văn.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền, TS. Nguyễn Lan Hương. Thầy, cô đã tận tình hướng dẫn, định hướng, truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu làm nền tảng cho tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học để hoàn thành luận văn này.

Bên cạnh đó, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, các anh chị và bạn bè đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn.

Trong quá trình nghiên cứu luận văn do còn hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thời gian nên không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì thế, tác giả rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ Quý Thầy, Cô và người đọc.

Kính chúc Quý Thầy, Cô thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Tác giả thực hiện

Lê Thanh Lâm

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Giới thiệu: Giao dịch cố đất là một loại hình giao dịch dân sự liên quan đến đất đai có lịch sử lâu đời tại Việt Nam, đặc biệt phổ biến đối với đất nông nghiệp ở các vùng nông thôn. Mặc dù không được quy định rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện hành nhưng cũng không có quy định cấm thực hiện, giao dịch cố đất vẫn tồn tại như một thực tế phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng nông thôn. Tuy nhiên, chính vì sự khuyết thiếu quy định điều chỉnh nên sự tồn tại của giao dịch cố đất đặt ra nhiều vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn cần được nghiên cứu.

Mục tiêu: Phân tích các vấn đề lý luận, quy định pháp luật, đánh giá quy định hiện hành có liên quan và thực trạng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất của người dân ở các vùng nông thôn Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu rút ra những vướng mắc, bất cập và đưa ra định hướng, giải pháp áp dụng pháp luật, hoàn thiện pháp luật có liên quan.

Phương pháp: Tác giả sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật để phân tích, làm rõ các khái niệm liên quan đến giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam.

Kết luận: Thông quan nghiên cứu, có thể kết luận rằng giao dịch cố đất là một giao dịch có đối tượng là quyền sử dụng đất, được xác lập và thực hiện theo tập quán. Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có quy định điều chỉnh nhưng cũng không có quy định cấm các chủ thể thực hiện giao dịch cố đất. Do đó, thực trạng quy định và áp dụng pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập liên quan đến giao dịch này. Với những định hướng và giải pháp được đề xuất, kiến nghị trong luận văn sẽ góp phần giải quyết được vấn đề khuyết thiếu quy định điều chỉnh của pháp luật, xác định đúng đắn và thống nhất về đường lối trong việc giải quyết tranh chấp hướng đến việc bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật trong nước để điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: Giao dịch cố đất, cầm cố quyền sử dụng đất, áp dụng tập quán.

ABSTRACT

Introduction: Land mortgage transactions are a type of civil transaction involving land that has a long-standing history in Vietnam, particularly prevalent for agricultural land in rural areas. Although not explicitly regulated in the current legal framework, and without any legal prohibition against their execution, land mortgage transactions continue to exist as a common practice and play a significant role in the socio-economic life of rural communities. However, the lack of specific regulatory provisions governing these transactions raises numerous theoretical, legal, and practical issues that require thorough research.

Objective: Analyze theoretical issues, legal provisions, and assess the current regulations related to land mortgage transactions, as well as the practical application of the law in state management and dispute resolution concerning land mortgage transactions based on customary land use practices of rural communities in Vietnam. From this analysis, the study identifies challenges and shortcomings and proposes orientations and solutions for the application and improvement of relevant legal frameworks.

Methodology: The author employs historical methods, as well as methods of analysis and synthesis of legal normative documents, to examine and clarify concepts related to land mortgage transactions based on customary land use practices in rural areas of Vietnam.

Conclusion: Through this study, it can be concluded that land mortgage transactions involve land use rights as their subject matter and are established and executed based on customary practices. While current Vietnamese law does not provide specific regulations governing these transactions, it also does not prohibit parties from engaging in them. As a result, the current legal framework and its application still reveal numerous limitations and inadequacies concerning these transactions. The orientations and solutions proposed in this thesis aim to address the lack of regulatory provisions, establish a consistent and accurate approach to dispute resolution, and contribute to the development and improvement of domestic legal regulations to effectively govern land mortgage transactions based on customary practices in rural Vietnam.

Keywords: Land mortgage transactions, Pledge of land use rights, Application of customary practices.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Lê Thanh Lâm, là học viên ngành Luật Kinh tế, khóa 29, Trường Đại học Cần Thơ. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của bản thân tôi được sự hướng dẫn của PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền và TS. Nguyễn Lan Hương.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài luận văn được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lắp với các đề tài khác cùng cấp đã được công bố trước đây. Tác giả đồng ý về việc Nhà trường có quyền công bố và phổ biến để phục vụ nhu cầu đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2024

Người hướng dẫn	**Tác giả thực hiện**
PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền	**Lê Thanh Lâm**
TS. Nguyễn Lan Hương	

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BLDS	Bộ luật Dân sự
ĐBSCL	Đồng bằng Sông Cửu Long
QSDĐ	Quyền sử dụng đất
TAND	Tòa án nhân dân
VKSND	Viện kiểm sát nhân dân
XHCN	Xã hội chủ nghĩa

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU **1**

1. Lý do chọn đề tài **1**

2. Tình hình nghiên cứu đề tài **2**

3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu **6**

4. Câu hỏi nghiên cứu **6**

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu **6**

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu **7**

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn **7**

8. Kết cấu của luận văn **8**

Chương 1 LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH CỐ ĐẤT THEO TẬP QUÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM **9**

1.1 Khái quát về chế độ sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất **9**

1.1.1 Khái quát về chế độ sở hữu đất đai *9*

1.1.1.1 Đất đai và quyền sở hữu đối với đất *9*

1.1.1.2 Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam *10*

1.1.2 Khái quát về quyền sử dụng đất *11*

1.1.2.1 Khái niệm quyền sử dụng đất *11*

1.1.2.2 Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất *11*

1.1.2.3 Quyền thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất tại Việt Nam *13*

1.1.3 Lý thuyết về vật quyền bảo đảm và vấn đề quyền sử dụng đất là đối tượng của vật quyền bảo đảm cầm cố trong pháp luật Việt Nam *15*

1.1.3.1 Lý thuyết về vật quyền bảo đảm *15*

1.1.3.2 Vấn đề quyền sử dụng đất là đối tượng của vật quyền bảo đảm cầm cố trong pháp luật Việt Nam *16*

1.2 Khái quát về giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn **18**

1.2.1 Các khái niệm về cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn *18*

1.2.1.1 Tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam *18*

1.2.1.2 Cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam *19*

1.2.2 Các hình thức thỏa thuận của giao dịch cố đất theo tập quán *21*

1.2.2.1 Cố đất đơn thuần có thời hạn chuộc lại 21

1.2.2.2 Cố đất có cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất 23

1.2.2.3 Cố đất có thỏa thuận cho thuê lại đất đã cố 23

1.2.2.4 Cố đất chỉ phát sinh trong tương lai theo điều kiện thỏa thuận 24

1.2.3 Bản chất pháp lý của giao dịch cố đất theo tập quán 25

1.2.3.1 Quyền, nghĩa vụ của các bên trong giao dịch cố đất 25

1.2.3.2 Phân biệt giao dịch cố đất và thế chấp quyền sử dụng đất 26

1.2.3.3 Phân biệt giao dịch cố đất và cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 26

1.2.3.4 Phân biệt giao dịch cố đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện chuộc lại 27

1.2.4 Lý do người dân ở nông thôn vẫn lựa chọn giao dịch cố đất theo tập quán 28

1.3 Pháp luật về giao dịch cố đất ở một số quốc gia và quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch cố đất qua các thời kỳ 29

1.3.1 Quy định pháp luật của một số quốc gia về giao dịch cố đất 29

1.3.1.1 Pháp luật của Pháp 29

1.3.1.2 Pháp luật của Lào 31

1.3.1.3 Pháp luật của Nhật Bản 31

1.3.2 Quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch cố đất qua các thời kỳ 32

1.3.2.1 Thời kỳ phong kiến 32

1.3.2.2 Thời kỳ Pháp thuộc (1858 – 1945) 35

1.3.2.3 Thời kỳ cải cách ruộng đất đến nay 36

1.4 Nguyên tắc pháp lý, các giá trị và tiêu chí xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam 36

1.4.1 Khái niệm nguyên tắc pháp lý 36

1.4.2 Các giá trị mang lại của việc xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh một quan hệ xã hội nội sinh chưa có điều luật áp dụng 37

1.4.2.1 Lấp đầy khoảng trống pháp lý và tăng cường tính công bằng 37

1.4.2.2 Bảo tồn giá trị văn hóa, tập quán và tạo nền tảng pháp lý vững chắc 38

1.4.2.3 Thúc đẩy sự minh bạch, ổn định và phát triển bền vững 38

1.4.3 Các tiêu chí xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam 39

1.4.3.1 Tôn trọng, áp dụng và kế thừa các giá trị tập quán tốt đẹp 39

1.4.3.2 Tôn trọng quyền tự do định đoạt, tự nguyện thỏa thuận 44

1.4.3.3 Đảm bảo minh bạch, công khai, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành ..45

1.4.3.4 Thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định nguồn lực đất đai ở nông thôn ..46

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 48

Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT, ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH CỐ ĐẤT THEO TẬP QUÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM.....50

2.1 Thực trạng pháp luật liên quan đến giao dịch cố đất hiện nay 50

2.1.1 Thực trạng quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch cố đất *.....50*

2.1.1.1 Quy định về các quyền của người sử dụng đất 50

2.1.1.2 Quy định về cầm cố tài sản là quyền sử dụng đất.....51

2.1.1.3 Quy định về cầm cố tài sản khác không phải quyền sử dụng đất 52

2.1.1.4 Những quy định khác có liên quan đến quản lý nhà nước và giải quyết tranh chấp trong thực tiễn xét xử tại Tòa án về giao dịch cố đất.....53

2.1.2 Thực trạng áp dụng pháp luật liên quan đến giao dịch cố đất *.....56*

2.1.2.1 Trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai 56

2.1.2.2 Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất 57

2.1.3 Những hạn chế, bất cập khi thực trạng pháp luật Việt Nam đang "lãng tránh" vấn đề cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam *.....60*

2.1.3.1 Về xây dựng và áp dụng pháp luật.....61

2.1.3.2 Về mặt xã hội và chính sách phát triển nông thôn.....62

2.2 Kiến nghị áp dụng tập quán để giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất 63

2.2.1 Định hướng áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất *...63*

2.2.1.1 Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong áp dụng tập quán.....63

2.2.1.2 Áp dụng tập quán về giao dịch cố đất nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ dân sự.....64

2.2.1.3 Áp dụng tập quán về giao dịch cố đất hướng đến việc xây dựng án lệ và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.....64

2.2.2 Nội dung áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất *.....66*

2.2.2.1 Áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất 66

2.2.2.2 Các quy tắc xử sự chung của tập quán cố đất cần được áp dụng.....68

2.2.2.3 Các quy tắc xử sự chung của tập quán cố đất không được áp dụng.....69

2.3 Đề xuất xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất 71

***2.3.1 Định hướng xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh về giao dịch cố đất** ..71*

2.3.1.1 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải phù hợp với chế độ sở hữu về đất đai và bản chất pháp lý của QSDĐ.....71

2.3.1.2 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải phù hợp với tập quán và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.....72

2.3.1.3 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải đảm bảo quyền tự do giao dịch trong kinh tế thị trường, thúc đẩy dòng vốn và tích tụ đất nông nghiệp.....74

2.3.1.4 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải đảm bảo tính đồng bộ giữa Luật Đất đai và quy định pháp luật khác có liên quan 75

***2.3.2 Nội dung xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất**.....76*

2.3.2.1 Quy định về "điều cấm của luật" và vấn đề "áp dụng tập quán".....76

2.3.2.2 Quy định về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố quyền sử dụng đất....77

2.3.2.3 Quy định về các quyền thực hiện giao dịch bằng quyền sử dụng đất.....79

***2.3.3 Nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về giao dịch cố đất**.....80*

2.3.3.1 Hoàn thiện quy định về thông tin và đăng ký quyền sử dụng đất 80

2.3.3.2 Hướng dẫn áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất.....81

2.3.3.3 Lựa chọn và công bố án lệ về giao dịch cố đất ở nông thôn Việt Nam 82

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 83

KẾT LUẬN 85

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i

DANH MỤC VĂN BẢN.....iv

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Từ Hiến pháp năm 1980, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai chính thức được ghi nhận. Chính sách, pháp luật về đất đai của Việt Nam không ngừng được đổi mới, hoàn thiện để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tư duy về phát huy tiềm năng nguồn lực đất đai thông qua giao dịch QSDĐ trong dân sự và thương mại đã được thể hiện rõ khi Nhà nước sửa đổi pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nếu như Luật Đất đai năm 1987 chỉ cho phép người sử dụng đất có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, thành quả lao động từ đất mà không có các quyền về định đoạt thì Luật Đất đai năm 1993 đã quy định cho người sử dụng đất có 05 quyền về chuyển giao QSDĐ có tính chất định đoạt và các quyền lợi trên đất cũng được phát triển hơn trước; đến Luật Đất đai năm 2003, người sử dụng đất đã có 09 quyền chuyển giao QSDĐ có tính chất định đoạt; Luật Đất đai năm 2013 quy định cho người sử dụng đất có 08 quyền chuyển giao QSDĐ có tính chất định đoạt (bỏ quyền bảo lãnh bằng QSDĐ).

Hiện nay, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030) tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có định hướng: "*Phát triển thị trường, đẩy mạnh thương mại hóa QSDĐ, tăng cường đăng ký QSDĐ và áp dụng định giá đất theo thị trường bảo đảm công khai, minh bạch* ". Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục khẳng định quan điểm: "*QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; QSDĐ, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ*". Có thể thấy, để phát triển thị trường thì cần có nhiều hàng hóa, trong đó QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh pháp luật hiện hành, bao gồm cả quy định mới của Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất tiếp tục bị "bó buộc" trong 08 quyền. Hay nói cách khác, có 08 loại giao dịch về QSDĐ được thực hiện hợp pháp, gồm: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ. Trong đó, chỉ có 01 trong số 09 biện pháp bảo đảm quy định trong BLDS năm 2015 có thể được thực hiện bằng QSDĐ, đó là *thế chấp tài sản*.

Trên thực tế, bằng chính tiềm năng và giá trị độc đáo vốn có của mình, QSDĐ từ bao đời nay đã là một loại hàng hóa đặc biệt. Bên lề quy định của luật, óc thực tế và sự linh hoạt của người sử dụng đất đã sáng tạo ra những thể thức giao dịch về QSDĐ rất đa dạng, phong phú. Trong đó, ***giao dịch cố đất*** là một tập quán giao dịch về đất đã tồn tại gần như suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt ở vùng nông thôn. Thật vậy, trong lịch sử pháp luật thời phong kiến Việt Nam qua các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ Cải cách ruộng đất đều có những quy định điều chỉnh (hoặc công nhận) giao dịch cố đất của người dân. Trong đời sống dân sự hiện nay, việc các chủ thể áp dụng biện pháp cố đất (hay còn gọi là thục đất, cầm cố QSDĐ) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ là rất phổ biến. Không phải tự nhiên mà QSDĐ được lựa chọn làm

đối tượng của quan hệ cầm cố, lý do bên có quyền và nghĩa vụ lựa chọn QSDĐ làm tài sản cầm cố xuất phát từ thực tế QSDĐ ngày càng có giá trị rất lớn trên thị trường, khi nhận cầm cố bên có quyền có thể được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ QSDĐ cầm cố nếu có thỏa thuận, v.v. Như vậy, việc cầm cố QSDĐ đã và đang mang lại lợi ích nhất định cho các bên[1].

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành của Việt Nam không có văn bản pháp luật nào ghi nhận và điều chỉnh trong khi bản thân loại giao dịch này vẫn tồn tại phổ biến, như một tập quán vốn có của người nông dân Việt Nam. Ở góc độ luật chung, BLDS năm 2015 công nhận và cho phép áp dụng tập quán. Tuy nhiên, sự khuyết thiếu quy định về cố đất trong một thời gian dài, kể từ khi Luật Đất đai đầu tiên năm 1987, sau đó là BLDS đầu tiên của Việt Nam năm 1995 cho đến nay đã hình thành nhiều quan điểm khác nhau, trong đó có quan điểm cho rằng đây là loại giao dịch dân sự bị cấm thực hiện. Từ thực tiễn xét xử, các vụ án tranh chấp giao dịch cố đất thường được xác định tên quan hệ tranh chấp là "Tranh chấp hợp đồng cầm cố QSDĐ". Kết quả xét xử cho thấy, Tòa án tuyên xử theo hướng hợp đồng vô hiệu với nhận định giao dịch này là vi phạm điều cấm của pháp luật[2]. Nhu cầu của xã hội đối với giao dịch cố đất vẫn thể hiện ở mức độ ổn định và tồn tại lâu dài của loại giao dịch này trong đời sống dân sự, nhất là ở vùng nông thôn Việt Nam. Ở góc độ quản lý, nhà nước cũng chỉ tuyên truyền, khuyến khích mà không có biện pháp hay công cụ nào khác để can thiệp và kiểm soát.

Tác giả nhận thấy rằng, vẫn còn những rào cản pháp lý nhất định để QSDĐ có thể thực sự phát huy giá trị thương mại, nếu người sử dụng đất vẫn bị giới hạn bởi các quyền năng được Luật Đất đai liệt kê cụ thể. Vì vậy, thông qua việc tiếp cận từ khía cạnh bản chất đến thực tiễn xét xử của Tòa án đối với ***giao dịch cố đất***, là 01 trong những loại giao dịch về QSDĐ hình thành từ rất lâu, tồn tại phổ biến đến ngày nay mà chưa được pháp luật hiện hành điều chỉnh, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu về: "*Xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam*" để làm Luận văn thạc sĩ Luật học.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Trong quá trình nghiên cứu tài liệu để thực hiện công trình này, tác giả đã khái quát được tình hình nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đề tài như sau:

Các công trình khoa học, bài báo khoa học:

Hoàng Thị Loan, Nguyễn Ngọc Tuyến, "*Bản chất QSDĐ tại Việt Nam và sự ảnh hưởng đến cấu trúc của Luật Đất đai*", Tạp chí Luật học số 4/2022. Trên cơ sở khái quát

[1] Trương Kim Phụng, Nguyễn Hoàng Chương, Một số vướng mắc về việc tuyên bố vô hiệu hợp đồng cầm cố QSDĐ do vi phạm điều cấm của luật và hướng hoàn thiện, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển Trường Đại học Tây Đô, số 16 – 2022, tr. 111.

[2] Ths. Bùi Ai Giôn, *Bàn về cầm cố QSDĐ và quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí điện tử Kiểm sát, https://kiemsat.vn/ban-ve-cam-co-quyen-su-dung-dat-va-quyen-so-huu-tri-tue-63955.html [truy cập 17/3/2024]

về bản chất QSDĐ ở Việt Nam, quan niệm của một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị và luận giải theo hướng mở rộng các quyền tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, thay đổi cấu trúc của Luật Đất đai trên cơ sở coi trọng hơn các quyền của người sử dụng đất.

Huỳnh Thị Kim Lan, Cao Thị Mỹ Duyên, "*Bàn về cầm cố tài sản là QSDĐ và nhà ở*", HCMCOUJS-Kỷ yếu, 17(2), 69-75. Bài viết đã phân tích những quy định đối với cầm cố tài sản là QSDĐ và nhà ở. Qua đó, người viết chỉ ra những bất cập đối với cầm cố bất động sản, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định này.

Lê Thị Thu Thủy, *"Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ - nhìn từ góc độ lý luận"*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 18 (370), tháng 9/2018. Bài viết cho rằng vấn đề cầm cố động sản và cầm cố bất động sản chưa được phân định rõ ràng trong BLDS 2015. Tác giả bài viết cũng đã gợi mở bài học kinh nghiệm từ pháp luật của Liên bang Nga. Ở Liên bang Nga, cầm cố tài sản có thể gắn với chuyển giao (nếu là động sản) hoặc không chuyển giao tài sản (nếu là bất động sản). Từ đó sẽ có các cơ chế khác biệt đối với sử dụng và xử lý tài sản cầm cố là bất động sản như bên cầm cố bất động sản vẫn có thể sử dụng bất động sản cầm cố, việc xử lý tài sản này yêu cầu bên cầm cố phải giao bất động sản cho bên nhận cầm cố để xử lý.

Sỹ Hồng Nam, "*Hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại và giải quyết tranh chấp tại Tòa án*", Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số tháng 01/2012. Bài viết nêu bật hai quan điểm nhận thức về bản chất của giao dịch "cố đất" trong thực tiễn xét xử và quan điểm của tác giả cho rằng "cố đất" thực chất là hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có điều kiện chuộc lại. Đây là giao dịch rất phổ biến tại miền Nam. Khi giải quyết tranh chấp hợp đồng "cố đất", Tòa án các cấp áp dụng không đúng pháp luật gây thiệt hại cho bên "cố đất" và bên nhận "cố đất".

Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân, "*Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại vùng ĐBSCL*", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 58, Số chuyên đề SDMD (2022): 170-181. Bài viết đã phân tích, đánh giá những bất cập về hiện trạng quản lý, sử dụng đất đai trong phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL. Đặc biệt, với những số liệu thống kê chi tiết về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của vùng, tác giả bài viết chỉ ra rằng việc người nông dân "lách luật" thông qua giao dịch "cố đất", giao dịch "bằng giấy tay" là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng sử dụng đất nông nghiệp hiện nay là: Số lượng lớn người được Nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ đã không còn là người có QSDĐ thực sự, minh chứng cho vấn đề này là thực tế đã có rất nhiều cá nhân đang có hàng trăm, hàng ngàn hecta đất trồng lúa, đất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu của bài viết này là một trong những dữ kiện quan trọng giúp tác giả có cơ sở tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khách quan, toàn diện về sự tồn tại của giao dịch "cố đất" theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn hiện nay.

Phan Trung Hiền, Hugh D. Spitzer, *Vietnam's "Entire People Ownership" of Land: Theory and Practice*, University of Pennsylvania Asian Law Review. 19. 1-26. Bài viết này cung cấp một cái nhìn toàn diện từ góc độ lịch sử, lý thuyết và thực tiễn về quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam. Đồng thời, các tác giả còn phát triển mối liên hệ giữa "quyền sở hữu đất đai của Nhân dân ở Việt Nam" với "quyền sở hữu đất đai của Nhà vua ở Vương quốc Anh". Cả 2 trường hợp sở hữu đất đai vừa nêu đều đưa đến hệ quả pháp lý là những người trực tiếp nắm giữ đất chỉ được sở hữu quyền lợi về đất đai chứ không phải nắm giữ quyền bá chủ tuyệt đối. Theo các tác giả đánh giá, ở Việt Nam, QSDĐ (mặc dù không phải quyền sở hữu đất) về cơ bản là một hàng hóa thị trường. Về mặt này, QSDĐ hàm ý sâu sắc các vấn đề kinh tế vượt ngoài khái niệm đơn giản là "sử dụng", và thực tế nó đã trở thành một loại hàng hóa đặc biệt, có thể được chuyển nhượng và lưu thông. Xét từ góc độ thực tế, điều này làm cho QSDĐ gần giống như quyền sở hữu đất đai. Cuối cùng, các tác giả kiến nghị Việt Nam nên trao cho người sử dụng đất hợp pháp quy chế "chủ sở hữu thứ cấp" về đất, thực chất là đồng sở hữu với Nhà nước và được bảo hộ quyền sở hữu tài sản. Kết quả nghiên cứu của bài viết là cơ sở để tác giả tiếp tục mở rộng, kiến nghị trong luận văn này về các giải pháp bảo hộ quyền của người sử dụng đất ở Việt Nam, mà trước hết là cho phép họ giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất hiện nay.

Giáo trình, sách:

Phan Trung Hiền (chủ biên), "Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam", Nxb. Đại học Cần Thơ, năm 2016 đề cập và phân tích chuyên sâu về "quyền đất đai an toàn" của người nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta. Trong đó, tác giả Nguyễn Lan Hương đánh giá "*về phạm vi của quyền, nếu một chế định đất đai trao cho người có quyền đất đai càng nhiều tự do (quyền) trong việc sử dụng và quản lý đất đai, đặc biệt là các quyền quan trọng, thì chế định đó được xem là mang lại mức độ an tâm càng cao cho người nắm quyền*"[3]. Đồng thời, tác giả đúc kết 3 ý nghĩa của quyền đất đai an toàn cho thấy về mặt kinh tế, sự an toàn của quyền đất đai là một điều kiện quan trọng để thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là đầu tư dài hạn, vào đất nông nghiệp và từ đó giúp tăng năng suất nông nghiệp.

Bùi Xuân Đính, (1985), *Lệ làng phép nước*, Nxb Pháp lý, Hà Nội và Bùi Xuân Đính (1998), *Hương ước và quản lý làng xã*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội: Đây là hai công trình liên quan đến tập quán pháp, là những công trình đề cập đến các hình thức tồn tại của tập quán trong xã hội, vai trò của chúng trong quản lý cộng đồng, tác động của chúng lên hiệu quả điều chỉnh của pháp luật.

Ngoài ra, Khâm định Việt Sử thông giám cương mục, Đại Việt Sử Ký toàn thư, Hồng Đức Thiện Chính thư và các sách luật cổ Việt Nam gồm Bộ luật Hồng Đức, Bộ

[3] Phan Trung Hiền (Chủ biên), Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam", Phan Trung Hiền (chủ biên), Nxb. Đại học Cần Thơ, năm 2016, tr. 53.

luật Gia Long, là những tác phẩm đề cập đến quy định về điển cố, điển mại, nội dung sắc dụ của vua về ruộng đất và giải quyết kiện tụng, chuộc lại ruộng đất đã cầm cố.

Các công trình là luận án, luận văn:

Luận án: "Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của TAND ở Việt Nam hiện nay", Nguyễn Thị Tuyết Mai, Người hướng dẫn GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế, 2014. Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra rằng, các quy phạm pháp luật vẫn chưa thể ghi nhận và điều chỉnh được hết tất cả mọi quan hệ xã hội trên các lĩnh vực đời sống mà Nhà nước cần điều chỉnh. Có rất nhiều giải pháp đã được đề ra. Từ gốc rễ của vấn đề, Nhà nước ta đã và đang thực hiện giải pháp sử dụng và nghiên cứu khả năng sử dụng nguồn bổ trợ cho pháp luật, bao gồm tập quán và án lệ. Những quy phạm pháp luật ghi nhận khả năng áp dụng tập quán bổ trợ cho pháp luật thành văn đã ra đời. Nhiều tranh chấp trong các quan hệ pháp luật tưởng chừng bế tắc đã có cơ sở hợp pháp và phù hợp để giải quyết. Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự được TAND các cấp thực hiện ngày càng thường xuyên hơn.

Luận văn: "*Hợp đồng mua bán tài sản với điều kiện chuộc lại*", Nguyễn Phương Thảo, Người hướng dẫn PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2017). Luận văn nghiên cứu về những quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại và những hình thức tồn tại chủ yếu của dạng hợp đồng này trên thực tế. Điểm đáng chú ý ở đây là tác giả đã có những phân tích và luận giải, từ đó đi đến kết luận "cố đất" là một trong những hình thức tồn tại của dạng hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại.

Một trong những công trình chứa đựng nhiều thông tin về thực tiễn là luận văn tốt nghiệp đại học của sinh viên Phùng Thị Ánh Xuân với đề tài Tập quán cố đất ở ĐBSCL - lý luận và thực tiễn. Nội dung của công trình tập trung phân tích về lý luận và đặc biệt là thực tiễn thực hiện, thực tiễn áp dụng pháp luật khi có tranh chấp xảy ra đối với loại giao dịch mang nặng yếu tố tập quán về đất đai mà người dân ĐBSCL quen gọi là cố đất (cầm cố đất đai để đảm bảo nghĩa vụ vay tiền, vàng). Công trình chủ yếu khảo sát ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở phân tích những nét tương đồng và khác biệt giữa loại giao dịch cố đất với một số giao dịch dân sự đã được điều chỉnh trong BLDS, tác giả cho rằng cố đất là một giao dịch dân sự theo tập quán và cần phải tiếp tục có những nghiên cứu để làm hoàn thiện hơn quy định về vấn đề này trong BLDS.

Tóm lại, các bài viết, công trình nghiên cứu khoa học nêu trên đã cung cấp một số nội dung quan trọng trong việc đưa ra những đánh giá về khoảng trống pháp lý đối với giao dịch "cố đất", một trong những giao dịch rất phổ biến ở nông thôn, kinh nghiệm của một số quốc gia bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, là cơ sở giúp cho người viết có cách nhìn tổng quan và tìm hiểu sâu hơn đối với giao dịch về cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng khung pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất ở Việt Nam vừa là vấn đề mang tính lý luận về bản chất QSDĐ, bảo đảm nghĩa vụ bằng QSDĐ, về nguồn của luật (tập quán pháp), v.v. đồng

thời liên quan đến thực tiễn xét xử các tranh chấp về cố đất tại Tòa án. Từ trước đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập trực tiếp, toàn diện và hệ thống nội dung lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp cho việc xây dựng pháp luật điều chỉnh để giải quyết tranh chấp về cố đất tại Tòa án ở Việt Nam.

3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam, giải pháp bảo đảm việc áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp liên quan đến loại giao dịch này của TAND ở Việt Nam một cách hợp pháp và có hiệu quả.

Mục tiêu nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, đề tại hướng đến 3 mục tiên nghiên cứu cơ bản sau đây:

- Nghiên cứu loại giao dịch cố đất trong tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam từ trước đến nay, nhận diện điểm giống và khác giữa cố đất và các giao dịch khác có liên quan.

- Phân tích, đánh giá quy định pháp luật của một số quốc gia và thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh cũng như áp dụng để giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất.

- Xác định quan điểm và kiến nghị về việc xây dựng khung pháp lý để điều chỉnh loại giao dịch này, đường lối giải quyết tranh chấp phù hợp hơn, trên cơ sở tôn trọng tập quán và đề cao hơn các quyền của người sử dụng đất trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng XHCN.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, trên cơ sở tình hình nghiên cứu của đề tài, luận văn đã đặt ra một số câu hỏi cơ bản như sau:

1. Giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam về bản chất pháp lý là gì mà pháp luật chưa có quy định, tại sao phải có quy định pháp luật điều chỉnh giao dịch cố đất và những yếu tố nào chi phối đến pháp luật về giao dịch cố đất?
2. Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành có quy định nào tương tự và thực tiễn áp dụng như thế nào đối với giao dịch cố đất, định hướng, giải pháp, đề xuất, kiến nghị về vấn đề giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn như thế nào?

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Việc nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng là quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành khi thực hiện giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trên phạm vi không gian là ở Việt Nam. Số liệu, dẫn chứng được trích dẫn không giới hạn địa phương.

- Về thời gian nghiên cứu:

Thời gian nghiên cứu của đề tài tập trung vào giai đoạn từ khi Luật Đất đai năm 2013 được ban hành cho đến nay, quy định của BLDS hiện hành năm 2015, đối chiếu với quy định mới của Luật Đất đai năm 2024.

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận:

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là những cơ sở lý luận, là hệ tư tưởng, là kim chỉ nam giúp người viết xây dựng cách thức tiếp cận những nội dung đề tài trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học, thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện qua việc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu. Trước hết, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng trong triết học Mác -Lênin như: Phân tích, Tổng hợp, Lịch sử - cụ thể để nghiên cứu tất cả các chương trong nội dung luận án. Ngoài ra, đề tài còn kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác như:

- Phương pháp phân tích, diễn giải, bình luận, tổng hợp: Các phương pháp này được sử dụng để phân tích các điều luật, văn bản pháp luật, các vụ việc liên quan đến giao dịch cố đất trong thực tiễn.

- Phương pháp so sánh: Phương pháp này sử dụng để so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, giữa quy định hiện hành và quy định pháp luật trong các thời kỳ lịch sử Việt Nam đối với cùng vấn đề điều chỉnh giao dịch cố đất trong tập quán sử dụng đất ở nông thôn.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn

Về ý nghĩa khoa học của luận văn: Luận văn tổng hợp một cách hệ thống cơ sở lý luận và quy định pháp luật có liên quan đến giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam, trên cơ sở pháp luật Việt Nam qua từng thời kỳ, tham khảo quy định của một số quốc gia có bối cảnh pháp lý tương đồng. Từ đó, nghiên cứu làm sáng tỏ bản chất, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch, xây dựng được khái niệm, đặc trưng của giao dịch cố đất và định hướng xây dựng các nguyên tắc pháp lý để điều chỉnh loại giao dịch này, đề xuất đường lối giải quyết tranh chấp phù hợp hơn, trên cơ sở tôn trọng tập quán và đề cao hơn các quyền của người sử dụng đất, hướng đến việc hoàn thiện pháp luật về giao dịch QSDĐ tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Về giá trị ứng dụng của luận văn: Luận văn là một công trình khoa học độc lập để các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên, học viên chuyên ngành luật tham khảo trong việc thực hiện các công trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập các vấn đề liên quan đến giao dịch cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam.

8. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được trình bày bằng 03 chương.

Chương 1: Lý luận liên quan đến xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam.

Trong Chương này, tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về chế độ sở hữu đất đai và QSDĐ tại Việt Nam, nhận diện giao dịch cố đất ở nông thôn Việt Nam so với các loại giao dịch khác, nhất là các loại giao dịch bảo đảm có tính chất tương đồng về quyền, nghĩa vụ của các bên, vấn đề áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp khi chưa có pháp luật quy định. Đồng thời, tác giả cũng nghiên cứu và trình bày khái quát trong nội dung Chương này về quy định pháp luật ở một số quốc gia, cũng như pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ điều chỉnh về giao dịch cố đất để có cái nhìn tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Cũng trong Chương này, tác giả khái quát về việc xây dựng nguyên tắc pháp lý và các tiêu chí xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam, tạo nền tảng lý luận và tiền đề cho việc phân tích và đề xuất giải pháp ở Chương 2 của luận văn.

Chương 2: Thực trạng pháp luật, định hướng và đề xuất những nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam

Trong Chương này, tác giả phân tích thực trạng quy định và áp dụng pháp luật liên quan đến giao dịch cố đất theo tập quán ở vùng nông thôn Việt Nam. Trên cơ lý luận đã phân tích ở Chương 1, thực trạng quy định, thực tiễn xét xử và yêu cầu tất yếu khách quan của xã hội, tác giả đề xuất một số quan điểm áp dụng pháp luật; đồng thời, nêu ra định hướng, kiến nghị áp dụng tập quán trong giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch cố đất; đề xuất một số nguyên tắc pháp lý, giải pháp hoàn thiện pháp luật trong nước để điều chỉnh giao dịch cố đất phù hợp với tập quán, nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta.

Chương 1
LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH CỐ ĐẤT THEO TẬP QUÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

1.1 Khái quát về chế độ sở hữu đất đai và quyền sử dụng đất

1.1.1 Khái quát về chế độ sở hữu đất đai

1.1.1.1 Đất đai và quyền sở hữu đối với đất

Trong giao lưu dân sự, BLDS Việt Nam hiện hành (2015) ghi nhận đất đai là một trong các loại tài sản thuộc nhóm bất động sản, là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý[4].

Đất đai là vừa là tài nguyên, vừa là tài sản và hàng hóa đặc biệt. Do đó, quyền sở hữu đối với đất đai trong kinh tế thị trường cũng là một phạm trù sở hữu đặc biệt khác với quyền sở hữu tài sản khác. Nếu như quyền sở hữu tài sản thông thường trong dân sự được xem là một vật quyền hoàn hảo, thể hiện đầy đủ quyền năng của một chủ sở hữu, đó là: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt thì sở hữu đất đai được xem là quyền sở hữu hạn chế và có sự chia sẻ lợi ích. Trong hầu hết mọi trường hợp, bản chất của sở hữu đất đai dù được đặt dưới chế độ sở hữu tư nhân thì cũng chỉ là *sở hữu tư hạn chế*, hay dưới chế độ công hữu về đất đai thì cũng chỉ là *sở hữu công mở rộng*[5].

Trong chế độ tư hữu về đất đai, người chủ sở hữu trực tiếp nắm giữ và bảo vệ nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của quyền lực nhà nước, được toàn quyền sử dụng nhưng phải chia sẻ lợi ích với đất nước thông qua các sắc thuế. Nhà nước định đoạt về mục đích, người có đất chỉ định đoạt về giao dịch đất đai trên thị trường.

Trong chế độ công hữu về đất đai, chủ sở hữu lại không thực hiện quyền chiếm hữu tuyệt đối mà người sử dụng đất mới là người nắm giữ và bảo vệ đất. Nhà nước trao cho người sử dụng đất được quyền sử dụng, đầu tư vào đất, khai thác tài nguyên đất trong khuôn khổ pháp luật. Người sử dụng đất không có quyền định đoạt trực tiếp đối với đất mà gián tiếp thực hiện thông qua việc định đoạt "QSDĐ".

Có thể nói, trong kinh tế thị trường, không thể thừa nhận quyền sở hữu tuyệt đối trọn vẹn của một chủ thể công hay tư đối với đất đai vì bản chất đặc biệt của nó. Việc quy định chế độ sở hữu đất đai thuộc về công hay tư dường như có ý nghĩa đối với chế độ chính trị, quản lý hành chính nhà nước, v.v. Còn trong giao lưu dân sự, dù dưới chế độ công hữu hay tư hữu về đất đai, tên gọi "đất đai" hay "QSDĐ" về bản chất đều vận

---

[4] Khoản 2 Điều 105, điểm a khoản 1 Điều 107, Điều 197 của BLDS năm 2015.

[5] GS. TSKH. Đặng Hùng Võ, Vận hành chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong cơ chế thị trường, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương, https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/nghien-cuu-trao-doi/bai-1-van-hanh-che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-trong-co-ch.html [truy cập ngày 09-10-2024].

hành với tư cách một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt. Trong đó, cùng một loại hàng hóa là "QSDĐ", nếu có thể đưa vào chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp thì cũng có thể được cầm cố hoặc giao dịch bằng phương thức khác miễn là quyền, nghĩa vụ của các bên được đảm bảo trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

1.1.1.2 Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam

Ngày 18/12/1980, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI đã thông qua Hiến pháp năm 1980. Một chế độ sở hữu đối với đất đai ở nước ta đã được xác lập, đó là chế độ công hữu mới dưới tên gọi "sở hữu toàn dân". Từ đó đến nay, trải qua nhiều lần sửa đổi Hiến pháp, pháp luật dân sự và đất đai, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai vẫn tiếp tục được duy trì như một nguyên tắc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật.

Cơ sở nền tảng của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam dựa trên học thuyết của Mác - Lê nin về chủ nghĩa xã hội. Theo đó, trong nhà nước XHCN, các tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc sở hữu công cộng. Trong đó, đất đai là một loại tư liệu sản xuất vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, ở các nước theo XHCN thì đất đai đều thuộc chế độ công hữu. Pháp luật Trung Quốc, Triều Tiên cũng không ghi nhận đất đai có thể thuộc sở hữu tư nhân. Đồng thời, ở các nước ghi nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai như Hoa Kỳ, Pháp và cả các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Liên Bang Nga thì pháp luật cũng ghi nhận song song cả hình thức sở hữu đối với đất đai[6].

Thực tế, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai có nhiều ưu điểm, tiêu biểu là hạn chế tình trạng đầu cơ đối với đất đai, đặc biệt đối với đất nông nghiệp. Từ đó, bảo đảm cho người nông dân luôn có tư liệu sản xuất để sản xuất. Bởi vì, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước sẽ trao lại QSDĐ cho người sử dụng đất thông qua hoạt động giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ. Trong đó, đối với đất nông nghiệp Nhà nước có cơ chết giao đất dựa trên đầu người (cấp theo nhân khẩu), vì thế người nông dân luôn đảm bảo có đất để canh tác; đồng thời, đảm bảo được vấn đề an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, nhược điểm của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, đó là khi đất đai không thuộc sở hữu của người sử dụng đất thì không thật sự khuyến khích người sử dụng đất đầu tư trên đất, cải tạo đất, giữ gìn tài nguyên đất. Về lý luận, khi Nhà nước đại diện chủ sở hữu để trao "QSDĐ" cho người sử dụng đất thì người này được tự mình khai thác các công năng, lợi ích của đất nhằm đạt được mục đích mà mình mong muốn[7]. Song, thực tế QSDĐ được trao lại cho người sử dụng có thời hạn hoặc ổn định

[6] Lê Hồng Hạnh, Bản chất pháp lý của QSDĐ trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 8/2017, tr. 23.

[7] PGS, TS. Vũ Văn Phúc, *Sở hữu toàn dân về đất đai: Tất yếu lịch sử trong điều kiện nước ta hiện nay*, Tạp chí Cộng sản điện tử, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/20654/so-huu-toan-dan-ve-dat-dai--tat-yeu-lich-su-trong-dieu-kien-nuoc-ta-hien-nay.aspx [truy cập 09-10-2024].

lâu dài, sử dụng đúng mục đích và được thực hiện các "quyền" theo quy định của Luật[8]. Cho nên, khi áp dụng vào thực tiễn giao lưu dân sự và thương mại, người sử dụng đất bị hạn chế khả năng tự do áp dụng các phương thức giao dịch mới ngoài luật định, hoặc các giao dịch tồn tại theo tập quán chưa được luật hóa. Nếu không có giải pháp đổi mới tư duy lý luận và định hướng quan điểm, vẫn còn giới hạn các phương thức giao dịch về "QSDĐ" theo luật định thì nguồn lực đất đai sẽ không thực sự được khai phóng, hiệu suất của việc khai thác tài nguyên đất không thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

1.1.2 Khái quát về quyền sử dụng đất

1.1.2.1 Khái niệm quyền sử dụng đất

Trước khi Hiến pháp năm 1980 ra đời, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, khái niệm "QSDĐ" chưa được sử dụng để chỉ những quyền năng đối với đất đai của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức. Thay vào đó là khái niệm "quyền sở hữu" đối với đất đai.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 1980, Luật Đất đai năm 1987 được ban hành và khái niệm "QSDĐ" được xem là một sự sáng tạo pháp lý nhằm thực hiện sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta và cũng như là một công cụ pháp lý để giúp Nhà nước thực hiện được quyền năng chủ sở hữu của mình. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, pháp luật thực định của Việt Nam vẫn chưa có định nghĩa chính thức về nội hàm của khái niệm QSDĐ.

Theo Từ điển Luật học năm 2006 thì *"QSDĐ là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi ích từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho..."*[9]. Trong khi đó, Giáo trình Luật Đất đai của Trường Đại học Luật Hà Nội thì cho rằng: *"QSDĐ là quyền khai thác các thuộc tính có ích của đất đai để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước"*[10].

1.1.2.2 Bản chất pháp lý của quyền sử dụng đất

Nhìn lại quá trình xây dựng pháp luật đất đai, vấn đề đưa chế độ sở hữu toàn dân về đất đai vào cơ chế thị trường như thế nào cho phù hợp đã được đặt ra từ lý luận cũng như thực tiễn. Khái niệm QSDĐ ra đời vốn là một sáng kiến cơ bản thay thế cho đất đai, để đất đai được "yên lặng" thuộc công hữu, còn QSDĐ có thể thuộc tư nhân để đưa vào vận hành trong cơ chế thị trường[11]. Do đó, việc nhận diện đúng bản chất pháp lý của

---

[8] Điều 5 của Luật Đất đai năm 2024.

[9] Viện Khoa học pháp lý (năm 2006), *Từ điển Luật học* (trang 655), Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa và Nhà Xuất bản Tư pháp, Hà Nội.

[10] Đại học luật Hà Nội (2011), *Giáo trình Luật Đất đai* (trang 92), NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

[11] GS. TSKH. Đặng Hùng Võ, Vận hành chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong cơ chế thị trường, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương, https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/nghien-cuu-trao-doi/bai-1-van-hanh-che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-trong-co-ch.html [truy cập ngày 09-10-2024].

QSDĐ có ý nghĩa rất quan trọng về mặt lý luận để xác định các quyền cụ thể của chủ thể được trao QSDĐ.

Thực tế, trong văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam đều chưa có định nghĩa cụ thể nào nói lên được bản chất của QSDĐ là gì. Đến khi BLDS năm 2015 ban hành quy định "*QSDĐ là quyền tài sản*"[12], ta thấy quan điểm của các nhà làm luật đã xác định QSDĐ là một loại tài sản, thuộc nhóm quyền tài sản. Về mặt lý luận, quyền tài sản là quyền được định đoạt về tài sản kể cả khi không là chủ sở hữu tài sản. Một người thế chấp tài sản vào ngân hàng để vay tiền thì quyền tài sản thuộc ngân hàng. Tương tự, khi một người đã trả tiền sử dụng đất cho chủ sở hữu đất thì được nhận quyền tài sản và thực hiện quyền đó theo quy định của pháp luật. Theo quan niệm như vậy, đất đai vẫn luôn thuộc sở hữu toàn dân và được vận hành trực tiếp trong kinh tế thị trường, không phải thay thế bằng QSDĐ, người sử dụng đất có quyền tài sản đối với đất đó, quyền tài sản đối với đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật.[13]

Dưới góc độ quan điểm chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đảng ta khẳng định QSDĐ là *"một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu"*[14]. Khi QSDĐ được coi là một loại tài sản, được đưa vào giao dịch thì tất yếu trở thành một loại hàng hóa, nhưng là hàng hóa đặc biệt. Thực tế, QSDĐ đã được pháp luật quy định là một trong các loại hàng hóa trong thị trường bất động sản[15]. Với tư cách là một loại hàng hóa, QSDĐ có thể được tiếp cận thông qua hai thị trường: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Trong thị trường sơ cấp, các chủ thể được nhận QSDĐ do Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận QSDĐ. Trong thị trường thứ cấp, có nhiều cách thức để các chủ thể tiếp cận thông qua các giao dịch dân sự và thương mại. Từ thực tiễn, có thể thấy người sử dụng đất không chỉ có quyền sử dụng và hưởng lợi mà phải được trao các quyền giao dịch, định đoạt QSDĐ thì mới có thể vận hành được thị trường nguồn lực đất đai.

Ở một khía cạnh khác, khi đề cập đến bản chất của "QSDĐ", một số nhà khoa học pháp lý so sánh với quyền sử đụng đất tại Vương quốc Anh. Theo đó, toàn bộ đất đai ở Vương quốc Anh thuộc về Hoàng gia, các tổ chức và cá nhân chỉ có QSDĐ mà không có quyền sở hữu đất. Tương tự, ở Việt Nam toàn bộ đất đai thuộc về sở hữu của một chủ

---

[12] Khoản 2 Điều 115 của BLDS năm 2015.

[13] GS. TSKH. Đặng Hùng Võ, Vận hành chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong cơ chế thị trường, Tlđd.

[14] Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (ngày 31/10/2012), *Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại*.

[15] Khoản 1 Điều 3 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2013.

thể đặc biệt hơn là "toàn dân". Dù có hai chủ sở hữu khác nhau, song cả hai trường hợp sở hữu vừa nêu đều đưa đến hệ quả pháp lý là người trực tiếp nắm giữ đất chỉ được sở hữu quyền lợi về đất chứ không phải nắm giữ quyền sở hữu tuyệt đối. Vậy, QSDĐ ở Việt Nam (dù không phải quyền sở hữu đất đai) về cơ bản cũng là một hàng hóa trên thị trường. Theo cách hiểu này, bản chất của QSDĐ hàm chỉ rộng hơn đến các giá trị kinh tế, vượt ngoài khái niệm đơn giản là "sử dụng", và thực tế nó đã trở thành một loại hàng hóa đặc biệt, có thể được chuyển nhượng, lưu thông trong các giao dịch dân sự và thương mại. Xét từ góc độ thực tế, điều này làm cho QSDĐ gần giống như một quyền sở hữu đặc biệt[16].

1.1.2.3 Quyền thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Về mặt lý luận, một khi thừa nhận QSDĐ là một loại tài sản tức là thừa nhận khả năng giao dịch của nó trong nền kinh tế thị trường. QSDĐ, với tư cách là một loại tài sản được pháp luật Việt Nam bảo hộ, có thể trị giá được thành tiền và hoàn toàn có quyền được lưu thông trong các giao dịch dân sự, thương mại thông qua các phương thức định đoạt theo ý chí và mục đích của người có tài sản.

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2024 ghi nhận cho người sử dụng đất có 08 phương thức thực hiện giao dịch về QSDĐ (Điều 27). Trước đó, Khoản 4, Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ có định nghĩa cụ thể hơn đối với giao dịch về QSDĐ, *"là trường hợp các bên liên quan thực hiện việc chuyển đổi hoặc chuyển nhượng hoặc tặng cho hoặc cho thuê, cho thuê lại hoặc thừa kế hoặc thế chấp hoặc giao dịch cố đất theo quy định của pháp luật về đất đai*". Song, tóm lại thì giao dịch về QSDĐ được định hình trong 08 phương thức xác định bởi Luật Đất đai. Vấn đề là, ngoài 08 phương thức giao dịch này, người có QSDĐ có được phép thực hiện các giao dịch khác đối với QSDĐ hay không vẫn là vấn đề đang bỏ ngõ và tranh cãi nhiều từ lý luận đến thực tiễn.

Về nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, khoản 2 Điều 3 của BLDS năm 2015 quy định: "*Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng*". Trong khi Luật Đất đai chỉ đề cập đến những giao dịch cơ bản nhất, không có quy định loại bỏ hay cấm hẳn người sử dụng đất không được thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại nào. Người có tài sản có quyền lựa chọn phương thức giao dịch và đưa tài sản của mình tham gia vào giao dịch đó; điều này chỉ thúc đẩy lưu thông dân sự, tạo ra nhiều hơn giá trị hơn cho kinh tế thị trường. Mọi phương hại có thể xảy ra đã được Nhà nước kiểm soát vĩ mô bằng công cụ pháp luật, không có lý do gì để cho phép chủ thể được thực hiện giao dịch này mà không được thực hiện giao dịch khác đối với cùng một loại tài sản là QSDĐ.

[16] Phan Trung Hiền, Hugh D. Spitzer, *Vietnam's "Entire People Ownership" of Land: Theory and Practice*, University of Pennsylvania Asian Law Review. 19. 1-26

Đánh giá vấn đề này ở góc độ xã hội, ta thấy bất kỳ một cá nhân nào khi tham gia giao dịch đều mong muốn tối đa hóa lợi ích trong một hoàn cảnh nhất định. Điều đó dẫn đến việc, mỗi cá nhân luôn phải cân nhắc giữa chi phí và lợi nhuận. Các cá nhân chỉ quyết định thực hiện giao dịch khi chi phí ngang bằng hoặc thấp hơn lợi nhuận mà họ có thể đạt được[17]. Do đó, khi một chủ thể quyết định đem QSDĐ của mình tham gia vào một giao dịch nào đó nằm ngoài các quyền được liệt kê tại Điều 27 của Luật đất đai (như cầm cố, bảo lãnh, chuyển nhượng có điều kiện chuộc lại chẳng hạn) thì đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên hay họ cố tình làm điều gì đó ngoài luật định. Thực tế, lợi ích và nhu cầu của các chủ thể là yếu tố khởi điểm cho mọi hành động xã hội[18].

Ở một khía cạnh khác, tự do ý chí cũng là một nguyên tắc thỏa thuận trong pháp luật dân sự, là nền tảng hình thành quan hệ hợp đồng. Thông qua việc biểu lộ ý chí mong muốn trao đổi nghĩa vụ và nhận lấy quyền lợi, sự thống nhất về ý chí giao kết làm phát sinh ra hậu quả pháp lý của hợp đồng. Không có tự do ý chí thì không thể hình thành quan hệ hợp đồng và ngược lại, tự do ý chí có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhằm biến các dự định hoặc kế hoạch trở thành hiện thực[19]. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tự do ý chí tuyệt đối cho phép các bên cạnh tranh vượt ngoài sự kiểm soát và điều tiết của nhà nước, thực tế không giải quyết ổn thỏa một số giao dịch mà đời sống xã hội đặt ra. Do vậy, từ đầu thế kỷ XIX, với sự thay đổi bối cảnh kinh tế - xã hội và sự ra đời lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ của J.M Keynes, vai trò can thiệp của nhà nước vào tự do thỏa thuận hợp đồng đã được khẳng định thông qua các công cụ kinh tế vĩ mô. Lúc này, giải pháp chung vẫn là tôn trọng quyền tự do ý chí trong giao kết, thỏa thuận và thực hiện hợp đồng nhưng có tính đến các lợi ích xã hội. Từ đó, hợp đồng vẫn là kết quả của tự do ý chí và thống nhất ý chí của các bên nhưng phải chịu sự giám sát chặt chẽ của pháp luật, thông qua việc quy định những giới hạn cụ thể mà các bên phải tuân thủ khi giao kết hợp đồng.[20]

Từ góc nhìn vai trò của nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của ta hiện nay đã hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do. Người sử dụng đất hầu hết chỉ thuần túy vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận hoặc tích tụ ruộng đất cũng vì mục tiêu tạo ra giá trị luân chuyển trong nền kinh tế thị trường. Do đó, mở rộng tự do giao dịch về QSDĐ là một trong những định hướng phù hợp, đảm bảo các quyền dân sự của con người và cũng là công cụ hiệu quả để thúc đẩy nguồn lực đất đai phát triển lành mạnh, bền vững. Thiết nghĩ, việc giới hạn tự do hợp đồng không phải ở việc thừa nhận giao dịch này, loại bỏ

---

[17] Jonh Stuart Mill (1863), Utilitarianism, Batoche Book, Kitchener, Canada, edited by George Sher (2001), tr.96.

[18] Vũ Hào Quang, Về lý thuyết hành động xã hội của M. Weber, Tạp chí Xã hội học, Số 1 (57), 1997.

[19] Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật Hợp đồng, Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013, tr.27.

[20] Dương Anh Sơn, Hoàng Vĩnh Long, "Tự do hợp đồng – từ bàn tay vô hình đến chủ nghĩa can thiệp", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 397 – Tháng 6/2011.

giao dịch kia ra khỏi đời sống dân sự, mà là ở những công cụ pháp lý vĩ mô đảm bảo cho sự bình đẳng, an toàn của các chủ thể khi tham gia giao dịch.

1.1.3 Lý thuyết về vật quyền bảo đảm và vấn đề quyền sử dụng đất là đối tượng của vật quyền bảo đảm cầm cố trong pháp luật Việt Nam

1.1.3.1 Lý thuyết về vật quyền bảo đảm

Lý thuyết về vật quyền bảo đảm trong khoa học pháp lý và lập pháp Việt Nam hiện nay được xem là lý thuyết quan trọng trong xây dựng pháp luật về giao dịch bảo đảm. BLDS 2015 cũng được thiết kế dựa trên những lý thuyết về vật quyền và trái quyền nhưng không sử dụng thuật ngữ pháp lý này trong văn bản luật; tuy vậy, ảnh hưởng của lý thuyết vật quyền trong những quy định pháp lý của BLDS 2015 là khá rõ rệt. Làm rõ lý thuyết về vật quyền bảo đảm là cơ sở để hiểu rõ bản chất của các quy định pháp lý về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong pháp luật dân sự.

a) Khái niệm

Vật quyền bảo đảm là một khái niệm của hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa (Civil law), được dùng để chỉ quyền trực tiếp và ngay tức khắc của bên nhận bảo đảm trên một tài sản được chủ sở hữu của nó dùng để đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ. Vật quyền bảo đảm chỉ một biện pháp làm tăng quyền năng của trái chủ, mà không phụ thuộc vào người khác, cho phép trái chủ có quyền lợi đặc biệt đối với tài sản của người thụ trái.

Quan hệ bảo đảm hiện nay không chỉ bao gồm trái chủ và người thụ trái mà còn có thể có bên thứ ba dùng tài sản của mình để đảm bảo cho nghĩa vụ của người thụ trái. Như vậy, nói một cách rộng hơn, vật quyền bảo đảm phát sinh khi chủ sở hữu của tài sản đã tách quyền định đoạt cho bên nhận bảo đảm để nhằm mục đích dành cho chủ thể đó sự đảm bảo về mặt tài sản, quyền lợi đó trực tiếp thuộc về bên nhận bảo đảm mà không phụ thuộc vào bên nào khác. Quan hệ vật quyền bảo đảm cho phép chủ thể có quyền "áp đặt" quyền của mình lên tài sản, mà không cần đến sự đồng ý hoặc không đồng ý của chủ thể khác. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa vật quyền bảo đảm nói riêng và vật quyền nói chung với quan hệ trái quyền (trong quan hệ trái quyền thì quyền của chủ thế này, đồng thời là nghĩa vụ của chủ thể khác)[21].

b) Vật quyền bảo đảm trong mối quan hệ với vật quyền sở hữu

- Sự phái sinh sơ cấp mà vật quyền sở hữu là vật quyền gốc, vật quyền bảo đảm là vật quyền phái sinh.

Quan hệ bảo đảm chỉ phát sinh khi có một quan hệ trái quyền được xác lập. Một bên có quyền yêu cầu bên còn lại thực hiện nghĩa vụ. Nhưng quan hệ trái quyền vốn phụ thuộc nhiều vào thiện chí của các bên khi tham gia, đặc biệt là bên có nghĩa vụ. Quan

[21] Ngô Thu Trang, Lý thuyết về vật quyền bảo đảm và vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, https://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2326

hệ trái quyền chỉ xác lập *quyền yêu cầu* cho bên có quyền, còn có thực hiện nghĩa vụ được yêu cầu không thì lại do thiện chí của bên có nghĩa vụ. Khi xác lập quan hệ bảo đảm, bên bảo đảm đồng ý chuyển giao quyền định đoạt tài sản của mình cho bên nhận bảo đảm để bảo đảm rằng một nghĩa vụ sẽ được thực hiện khi bên nhận bảo đảm – cũng là bên có quyền yêu cầu – yêu cầu, và nếu nghĩa vụ ấy không được thực hiện, bên nhận bảo đảm có quyền định đoạt đối với tài sản dùng để bảo đảm. Tài sản là đối tượng của bảo đảm bao giờ cũng phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm (cho dù bên bảo đảm không phải là bên có nghĩa vụ - như trong các hợp đồng bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba). Phải như vậy thì bên nhận bảo đảm mới có thể được chuyển giao quyền định đoạt tài sản đó ngay khi nghĩa vụ không được thực hiện.

Như vậy, vật quyền bảo đảm bao giờ cũng phái sinh sơ cấp từ vật quyền sở hữu bởi theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm và vật quyền bảo đảm được chuyển dịch trực tiếp từ người bảo đảm sang bên nhận bảo đảm.

- Sự dịch chuyển quyền định đoạt đối với tài sản

Các chủ sở hữu đem tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ đều phải chấp nhận rằng nếu nghĩa vụ được bảo đảm không được thực hiện thì quyền định đoạt (xử lý – theo cách gọi của pháp luật Việt Nam hiện tại) tài sản đó thuộc về bên nhận bảo đảm. Trong khi, quyền xử lý tài sản bảo đảm được xác định là một vật quyền nên thông qua giao dịch bảo đảm, một quyền đối vật được chuyển dịch.

- Vật quyền bảo đảm là một trong những nội dung của quan hệ luôn được hình thành theo thỏa thuận (quan hệ bảo đảm) giữa chủ sở hữu tài sản với người có quyền trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm.

Quan hệ bảo đảm luôn được hình thành từ các giao dịch (hợp đồng) bảo đảm nên yếu tố thỏa thuận là nét đặc trưng và duy nhất trong quan hệ này. Trong đó, chủ thể của thỏa thuận này thì một bên (bên nhận bảo đảm) bao giờ cũng là bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng giao dịch bảo đảm, còn bên kia (bên bảo đảm) có thể chính là người có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm hoặc có thể là người khác nhưng bao giờ cũng phải là chủ sở hữu của tài sản bảo đảm.

1.1.3.2 Vấn đề quyền sử dụng đất là đối tượng của vật quyền bảo đảm cầm cố trong pháp luật Việt Nam

Ở góc độ học thuyết, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được xếp thành 2 nhóm – bảo đảm đối vật và bảo đảm đối nhân. Theo đó, các biện pháp cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ và bảo lưu quyền sở hữu là các biện pháp bảo đảm đối vật; bảo lãnh và tín chấp là các biện pháp bảo đảm đối nhân.

Trong pháp luật Việt Nam, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được ghi nhận tại Điều 292 của BLDS hiện hành bao gồm cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản. Về tài

sản bảo đảm, Điều 295 BLDS quy định chung về tài sản bảo đảm của các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có đặc tính "*phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu*". Do đó, vấn đề QSDĐ (với tư cách là một tài sản trong nhóm quyền tài sản) có thể trở thành đối tượng của vật quyền bảo đảm hay không đang là vấn đề lý luận có nhiều quan điểm.

Ở Việt Nam, QSDĐ là một loại tài sản đặc biệt trong pháp luật Việt Nam, phát sinh từ nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý. Người sử dụng đất được Nhà nước trao QSDĐ theo các hình thức giao, thuê, hoặc công nhận quyền sử dụng. Trong khi đó, vật quyền bảo đảm là cơ chế pháp lý giúp bên nhận bảo đảm có quyền ưu tiên thanh toán từ tài sản bảo đảm khi bên bảo đảm không thực hiện nghĩa vụ. Song, pháp luật lại chỉ ghi nhận QSDĐ là đối tượng của vật quyền bảo đảm thế chấp mà bỏ ngỏ vấn đề QSDĐ là đối tượng của vật quyền bảo đảm cầm cố.

Quan điểm loại trừ QSDĐ khỏi đối tượng của cầm cố cho rằng:

- Cầm cố là hình thức bảo đảm nghĩa vụ, trong đó bên bảo đảm giao tài sản của mình cho bên nhận bảo đảm. Đặc điểm của cầm cố là sự chuyển giao vật lý tài sản, cho phép bên nhận bảo đảm kiểm soát và sử dụng tài sản nếu cần thiết. Tuy nhiên, QSDĐ không thể được chuyển giao vật lý, vì quyền này gắn liền với tư cách pháp lý của người sử dụng đất và nghĩa vụ duy trì mục đích sử dụng đất. Điều này khiến cầm cố không phù hợp với bản chất pháp lý của biện pháp cầm cố.

- Cầm cố QSDĐ chưa được ghi nhận trong pháp luật thực định Việt Nam còn do ảnh hưởng của chính sách người cày có ruộng, nông dân có đất sản xuất. Suốt một thời gian dài, Nhà nước không khuyến khích tích tụ ruộng đất cho một nhóm người trong xã hội, trong đó giao dịch cố đất hay cầm cố QSDĐ là giao dịch cố đất có thể khiến người nông dân nghèo phải giao đất canh tác (nguồn sống chính) cho người khác trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng tập trung lại ruộng đất mà nhà nước đã thực hiện chính sách trang trãi. Thay vào đó, Nhà nước khuyến khích người được giao quyền sử dụng đất trực tiếp canh tác và khai thác giá trị từ đất.

- Bên cạnh đó, quan điểm và định hướng loại bỏ giao dịch cố đất để thay thế bằng các giao dịch pháp lý khác dễ kiểm soát như chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn cũng là một chính sách dẫn đến loại trừ QSDĐ khỏi nhóm đối tượng được quyền cầm cố trong khung cảnh pháp luật hiện hành của Việt Nam. Cùng là vật quyền bảo đảm đối vật nhưng thế chấp QSDĐ chỉ cho phép bên nhận thế chấp giữ giấy tờ về QSDĐ mà không nắm giữ và canh tác ruộng đất như khi thực hiện cầm cố. Do đó, đặc tính này giúp cho biện pháp thế chấp QSDĐ trở nên hoàn hảo hơn đối với nhà làm luật và làm cho biện pháp cầm cố QSDĐ trở nên rủi ro hơn.

Ngược lại, quan điểm QSDĐ có thể là đối tưởng của cầm cố cho rằng:

- Trên cơ sở lý luận về vật quyền bảo đảm, tài sản bảo đảm là đối tượng của quyền đối vật trong quan hệ bảo đảm (vật quyền bảo đảm). Pháp luật Châu Ân lục địa có phân

loại tài sản thành tài sản hữu hình và tài sản vô hình (quyền tài sản) hoặc phân loại thành động sản và bất động sản. QSDĐ với tư cách là một quyền tài sản đã được luật định, có thể là đối tượng của biện pháp bảo đảm đối vật bằng cầm cố.

- Cho phép cầm cố sẽ mở rộng khả năng sử dụng QSDĐ trong các giao dịch dân sự và thương mại. Việc này không chỉ giúp người sử dụng đất tận dụng giá trị kinh tế của đất đai để tiếp cận nguồn vốn, mà còn góp phần thúc đẩy luân chuyển tài sản và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các quy định chi tiết để kiểm soát cầm cố QSDĐ sẽ giảm thiểu rủi ro, đồng thời tạo sự linh hoạt trong thực hiện quyền tài sản. Quan điểm này phù hợp với bối cảnh kinh tế, chính trị - xã hội của Việt Nam hiện hành, khi mà tích tụ đất nông nghiệp có kiểm soát không còn là rủi ro trong thực hiện chính sách đất đai mà còn là giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

- Để giải quyết các rủi ro pháp lý tiềm ẩn, quan điểm này đề xuất xây dựng cơ chế pháp luật rõ ràng cho việc cầm cố QSDĐ. Cụ thể, cần xác định rõ vai trò của giấy chứng nhận QSDĐ trong giao dịch cầm cố, quyền hạn của bên nhận bảo đảm, và phương thức xử lý khi bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ. Ngoài ra, cần bổ sung các biện pháp giám sát và quản lý chặt chẽ để đảm bảo giao dịch cầm cố không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất và quyền lợi của các bên liên quan.

1.2 Khái quát về giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn

1.2.1 Các khái niệm về cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn

1.2.1.1 Tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam

Tập quán sử dụng đất ở vùng nông thôn là những quy tắc, thói quen hoặc cách thức sử dụng đất được hình thành qua thời gian dài, được cộng đồng tại khu vực đó thừa nhận và tuân theo như một chuẩn mực. Tập quán này không nhất thiết phải được ghi nhận bằng văn bản, nhưng có giá trị trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội liên quan đến sử dụng đất ở địa phương.

Thực tế, việc sử dụng đất ở nông thôn bên cạnh việc tuân theo quy định của pháp luật, người dân còn dựa vào tập quán để vận hành, chẳng hạn như tập quán tưới nước, tiêu nước trong canh tác; tập quán phân định ranh giới, mốc giới theo mương dẫn nước, cây trồng, trụ đá, v.v. hay tập quán giao dịch cố đất thay vì thế chấp quyền sử dụng đất để vay mượn tài sản trong cộng đồng. Đây là những thói quen, cách thức sử dụng đất được hình thành qua quá trình lâu dài, gắn liền với văn hóa, phong tục, và lối sống của cộng đồng; được cộng đồng địa phương công nhận và thực hiện rộng rãi, không dựa trên sự áp đặt của pháp luật nhưng mang tính bền vững, ít thay đổi theo thời gian.

Vai trò của tập quán sử dụng đất trong cộng đồng thể hiện ở những khía cạnh:

(1) Bảo đảm sự hài hòa, ổn định trong cộng đồng: Tập quán sử dụng đất hạn chế tranh chấp đất đai nhờ sự thừa nhận chung trong cộng đồng dân cư ở nông thôn.

(2) Hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững: Tận dụng kinh nghiệm và tri thức bản địa trong quản lý đất đai; nhu cầu thực tế của người dân ở địa phương, vùng, miền nhất định trong canh tác và vận hành đất đai tạo ra giá trị cho thị trường.

(3) Bổ sung và điều chỉnh pháp luật: Trong một số trường hợp, pháp luật có thể dựa vào tập quán địa phương để giải quyết tranh chấp hoặc tạo khung pháp lý phù hợp hơn với thực tiễn. Từ đó, bổ sung và hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh bằng hành lang pháp lý an toàn đối với các giao dịch, cách thức sử dụng đất theo tập quán.

Tuy nhiên, tập quán sử dụng đất cũng có những hạn chế nhất định, có thể dẫn đến xung đột nếu mâu thuẫn với quy định pháp luật hiện hành. Do đó, chính sách pháp luật Việt Nam hiện hành có xu hướng chung là điều chỉnh và công nhận tập quán trong khuôn khổ phù hợp nhằm bảo đảm tính hài hòa giữa pháp lý và thực tiễn.

1.2.1.2 Cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam

Hiện nay, *cố đất* còn được gọi trong các bản án, quyết định của Tòa án là *cầm cố QSDĐ*, chưa được pháp luật quy định và hầu hết quan điểm giải quyết cho rằng QSDĐ là tài sản không được phép cầm cố. Do vậy, để hiểu rõ về khái niệm cố đất, trước tiên cần phải có sự đối sánh với khái niệm "cầm cố tài sản".

Điều 309 của BLDS năm 2015 quy định cầm cố tài sản là một biện pháp bảo đảm nghĩa vụ, theo đó "*bên cầm cố giao tài sản thuộc sở hữu của mình cùng các giấy tờ có liên quan cho bên nhận cầm cố giữ hoặc giao cho người thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố hoặc người thứ ba có quyền chiếm hữu tài sản cho đến khi nghĩa vụ được bảo đảm hoàn thành hoặc có quyền xử lý tài sản theo thỏa thuận hoặc theo luật định khi bên cầm cố không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ*".

Về phần mình, giao dịch cố đất theo tập quán là một loại giao dịch đã hình thành và tồn tại rất lâu ở nông thôn Việt Nam. Từ thời phong kiến, người dân vốn sinh sống nhờ vào kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, nhưng phần lớn ruộng đất lại tập trung vào bộ phận giai cấp địa chủ. Do đó, người làm ruộng vì không có đủ ruộng đất để tự túc quanh năm, hoặc vì mùa màng thất thu, v.v. nên phải vay tiền, vay thóc (lúa) để sử dụng tạm, làm cho loại giao dịch này trở nên rất phổ biến. Từ đó, sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng cách đem ruộng đất của con nợ cầm thế cho chủ nợ cũng được hình thành và phát triển.

Để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh, xử lý tranh chấp phát sinh thì pháp luật nước ta qua các thời kỳ phong kiến cũng đã sớm đề ra những quy định. Trong đó, văn bản quy phạm cổ nhất về cố đất mà ngày nay ta còn thấy ghi chép trong chính sử đã được ban hành dưới triều vua Lý Anh Tông (1128 – 1175). Vào tháng 12 năm Đại Định thứ ba (1142), vua xuống chiếu quy định thể lệ cầm cố ruộng đất [22]. Bên cạnh đó, tập quán giao dịch cũng hình thành những quy tắc, thể lệ riêng để định hình các quyền và nghĩa vụ của

[22] Khâm định Việt sử Thông Giám Cương mục – Chính biên – Quyển IV, tr. 165 và Đại Việt Sử ký toàn thư, 2013, Nxb Thời Đại, tr. 235.

mỗi bên khi tham gia vào việc cố đất. Tuy nhiên, từ cổ luật đến pháp luật hiện hành và khoa học pháp lý đến nay vẫn chưa thấy có định nghĩa về giao dịch cố đất.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, giao dịch cố đất không được ghi nhận trong các văn bản pháp luật để điều chỉnh nhưng do quá trình hình thành và phát triển trong lịch sử đã để lại những lề thói giao dịch chứa đựng quy tắc riêng về cố đất.

Về mặt ngữ nghĩa, theo Đại Nam Quấc Âm Tự Vị thì "cố" có nghĩa là mướn, cầm, ở mướn. Thuật ngữ "điền cố" có nghĩa là giao ruộng đất cho kẻ khác ăn hoa lợi mà trừ tiền lời, tục kêu là đồ[23]. Ngoài ra, các Từ điển ngôn ngữ hiện đại có cách giải thích tương đối giống nhau: "Cầm" có nghĩa là gửi của cải cho người khác giữ lại làm tin để vay tiền (như cầm ruộng cho địa chủ)[24] và "cố" được hiểu là cầm, thế, giao ruộng đất cho người để vay nợ, sau có tiền chuộc lại với số lời định trước (như cố ruộng cho người)[25].

Trong thực tiễn giao dịch, tùy vào từng giai đoạn lịch sử mà cố đất còn có các tên gọi khác như "điền cố ruộng đất", "cầm thế ruộng đất", "cầm cố QSDĐ", v.v. hoặc tùy từng địa phương còn gọi là "thục đất" (ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh).

Dưới đây là một văn bản giao dịch cố đất điển hình theo tập quán:

"TỜ CỐ ĐẤT RUỘNG

Tôi đứng tên dưới đây là Huỳnh Sơn T, sinh năm 1961.

Cùng với vợ là Nguyễn Hồng T1, sinh năm 1961 và con tôi là Huỳnh Công T2, sinh năm 1981. Ngụ cùng ấp V, xã Q, thị xã N, tỉnh S.

Đồng ý cố đất ruộng cho ông Nguyễn Văn D ngụ cùng ấp V, xã Q, thị xã N, tỉnh S tổng diện tích đất là 04 công tầm cấy (bốn công) với số tiền là 80.000.000 đồng (tám chục triệu đồng). Thời gian cố là 03 năm tính kể từ ngày làm giấy cố, nếu đến ngày tháng năm chuộc đất lại tôi không có tiền thì ông Nguyễn Văn D được quyền tiếp tục canh tác đến khi tôi có đủ số tiền nêu trên thì ông Nguyễn Văn D giao đất lại cho tôi.

Ấp V, 04-11-2019"[26]

Có thể thấy, dù không được điều chỉnh bởi bất kỳ một quy chế pháp lý nào, ngày nay việc cố đất vẫn được thỏa thuận theo tập quán, dựa trên những yếu tố cốt lõi về quyền và nghĩa vụ của các bên đã hình thành từ tập quán giao dịch lâu đời. Hình thức giao dịch thường phải bằng văn bản, được viết tay với sự chứng kiến của bàn cận, kế cận. Nội dung của một văn bản cố đất viết tay thường phải có 04 vấn đề được giao kết rõ, đó là: (1) Thông tin của cả hai bên chủ đất và bên nhận cố đất; (2) Thông tin về diện

---

[23] Huình-Tịnh Paulus Của, Đại Nam Quấc Âm Tự Vị, SaiGon, 1895, tr.176.

[24] GS. Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, tr.132.

[25] Lê Văn Đức, Tự điển Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1970, tr.208.

[26] Tham khảo hồ sơ vụ án do TAND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thụ lý số 02/2023/TLST-HNGD ngày 12/01/2023 về việc "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con và chia tài sản chung khi ly hôn".

tích, vị trí của mảnh đất; (3) giá tiền hoặc vàng mà bên nhận cố đất phải giao cho bên cố đất; (4) thời gian cố đất và thời hạn chuộc, có thể dự liệu xử lý nếu khi đến hạn mà bên cố đất không có tiền chuộc.

Trong thực tiễn xét xử, các Tòa án đều có quan điểm giải quyết không công nhận giá trị pháp lý của giao dịch cố đất; chưa tìm thấy bản án, quyết định nào áp dụng tập quán để giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch cố đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hầu hết Tòa án đều đánh giá được bản chất của loại giao dịch này, điển hình trong phần nhận định của một bản án phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã giải thích rõ giao dịch cố đất theo tập quán như sau: "*Cố đất là từ địa phương ở Nam Bộ, theo đó người có đất gọi là 'Bên cố đất' giao cho 'Bên nhận cố đất' được quyền khai thác, sử dụng đất trong một thời gian nhất định, hết thời hạn thỏa thuận thì hai bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận, bên nhận cố đất phải trả lại đất cho bên cố đất và bên cố đất phải trả lại tiền cho bên nhận cố đất*"[27].

Tóm lại, từ phương diện lý luận đến thực tiễn, khái niệm giao dịch cố đất theo tập quán có thể được hiểu là một giao dịch dân sự mà quyền, nghĩa vụ của các bên được điều chỉnh theo tập quán, Bên cố đất giao QSDĐ của mình cho Bên nhận cố đất; đổi lại, Bên nhận cố đất phải giao cho Bên cố đất một khoản tiền (hoặc kim khí quý, đá quý, v.v.) và được quyền khai thác, sử dụng đất, hưởng hoa lợi, lợi tức từ QSDĐ trong một thời hạn thỏa thuận. Hết thời hạn này, bên cố đất được quyền trả lại tiền (hoặc kim khí quý, đá quý, v.v.) cho bên nhận cố đất để chuộc lại QSDĐ.

1.2.2 Các hình thức thỏa thuận của giao dịch cố đất theo tập quán

Giao dịch cố đất luôn được thể hiện bằng giấy tờ và tùy theo bối cảnh, nhu cầu của các bên mà giao dịch cố đất được thiết lập dưới những hình thức thỏa thuận sau đây:

1.2.2.1 Cố đất đơn thuần có thời hạn chuộc lại

Theo tập quán giao dịch, việc cố đất có thể thỏa thuận cho người có QSDĐ (hay chủ đất) đem thế ruộng đất của mình để vay một số tiền nhỏ. Sau một thời hạn nhất định, chủ nợ đương nhiên phải hoàn lại ruộng đất mà người vay tiền không cần phải chuộc lại. Các hoa lợi do chủ nợ thu hoạch trong thời gian cố đất ghi trong hợp đồng đã bù trừ toàn bộ số nợ, kể cả gốc lẫn lãi.

Ở một số khu vực nông thôn vùng ĐBSCL, hình thức cố đất này còn tồn tại dưới tên gọi là "thục đất bạc tiêu". Người có QSDĐ (chủ đất) cần vốn hay đã mắc nợ từ trước nên thỏa thuận giao QSDĐ của mình cho người chủ nợ sử dụng trong một thời hạn nhất định để nhận được một khoản tiền hoặc cấn trừ khoản nợ. Hết thời hạn thì bên cố đất được quyền lấy đất lại mà không phải trả lại tiền cho người nhận "thục" đất. Có quan điểm cho rằng, quyền và nghĩa vụ trong giao dịch này tương ứng với quyền và nghĩa vụ

[27] Bản án số 189/2024/DS-PT ngày 11/4/2024 của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

của hợp đồng cho thuê QSDĐ trong BLDS[28]. Tuy nhiên, xét ở góc độ tập quán, hai loại giao dịch này đã và đang tồn tại song song trong đời sống dân sự cho thấy chúng có những điểm khác biệt mà người dân đã linh động áp dụng tùy vào những hoàn cảnh, nhu cầu cụ thể. Ở góc độ pháp lý và thực tiễn, tác giả cho rằng quyền và nghĩa vụ của giao dịch cố đất dưới hình thức "bạc tiêu" theo tập quán như trên cũng không hoàn toàn tương ứng với dạng hợp đồng thuê QSDĐ quy định trong BLDS hiện hành.

Ngoài hình thức trên, việc cố đất cũng có thể thế ruộng đất trong một thời hạn để vay một số tiền tương đương với giá trị bất động sản. Chủ nợ được quyền chiếm hữu, canh tác và thu hoa lợi các ruộng đất ấy. Tuy nhiên, khi đáo hạn, con nợ có thể trả lại số tiền vay để chuộc lại ruộng. Nhiều khi thời hạn chuộc ruộng không nói rõ mà trong văn tự, giấy tờ chỉ ghi là khi người vay có tiền thì có thể chuộc lại ruộng, chủ nợ không thể từ chối. Trong trường hợp này, hạn chuộc tối đa là 30 năm. Thực tế, vì trường hợp không thỏa thuận thời hạn chuộc đất trong khi thực hiện loại giao dịch này quá phổ biến dẫn đến tranh chấp nên chính trong sắc dụ niên hiệu Minh Mạng thứ 20, quy định về hạn chuộc ruộng, nhà vua đã ban hành quy định để điều chỉnh như sau: "*Nếu điền cố điền thổ mà trong khế ước không ghi rõ niên hạn thì quá hạn 30 năm, bên nhận điền cố sẽ được làm chủ sở hữu vĩnh viễn đối với các ruộng đất đã cố*". Ngược lại, bên nhận cố đất buộc phải chấp thuận cho người cố đất được chuộc lại khi đến thời hạn thỏa thuận.

Ví dụ 1:

Trong một giấy cố đất theo tập quán thỏa thuận thời hạn chuộc như sau:

"GIẤY CỐ ĐẤT

Tôi tên: Nguyễn Út B, quê ấp Mỹ Đ, xã Mỹ Q, thị xã N, tỉnh S.

Hôm nay ngày 20 tháng 02 năm 2018 âl.

Tôi có cố 03 công đất tầm cấy cho ông: Tô Thanh L, cùng ấp Mỹ Đ, xã Mỹ Q, thị xã N, tỉnh S với giá thỏa thuận hai bên là 90.000.000 (chín chục triệu chẵn). Thời gian ông L canh tác là 05 năm, kể từ ngày ông L canh tác là ngày 20 tháng 02 năm 2018 âl, đến ngày 20 tháng 02 năm 2023 âl là hết thời hạn, đất cặp mé kinh.

Nếu hết hạn mà không ông Út B chưa có tiền chuộc thì ông L canh tác tiếp theo đến hết vụ rồi mới được chuộc.

Mỹ Đ, ngày 20-02-2018"[29]

Hiện nay, ở một số khu vực nông thôn, hình thức giao dịch này còn tồn tại với tên gọi khác là "thục đất bạc còn". Người có QSDĐ (chủ đất) cần tiền nên đã giao đất cho

[28] Trang Thông tin điện tử VKSND tỉnh Bến Tre, *Bàn về hợp đồng "thục" QSDĐ*, https://vksbentre.gov.vn/index.php/hi-a-ap-phap-lut/962-ban-v-hp-ng-thc-quyn-s-dng-t [truy cập ngày 07/8/2024].

[29] Tham khảo hồ sơ vụ án do TAND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thụ lý số 343/2023/TLST-DS ngày 21/11/2023 về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng".

người khác sử dụng có thời hạn nhất định để nhận một số tiền; hết thời hạn "thục", chủ đất trả tiền và chuộc lại đất. Có quan điểm cho rằng quyền và nghĩa vụ trong giao dịch này tương ứng với quyền và nghĩa vụ của biện pháp bảo đảm nghĩa vụ về cầm cố tài sản trong BLDS[30]. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, từ góc độ tập quán giao dịch, pháp lý và thực tiễn cho thấy quyền và nghĩa vụ của giao dịch cố đất dưới hình thức "bạc còn" theo tập quán như trên cũng không hoàn toàn thỏa mãn với dạng hợp đồng cầm cố tài sản, nếu đặt trong bối cảnh quy định của BLDS hiện hành.

1.2.2.2 Cố đất có cam kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong văn tự điển cố, người cố đất còn hứa sau một thời hạn ghi trong văn tự, nếu không có tiền để trả nợ, thì phải bán đứt ruộng đó cho chủ nợ. Trong trường hợp này, khi làm văn khế đoạn mại (bán đứt), người chủ nợ lại phải trả thêm cho người cố đất một số tiền tương đương với giá trị của ruộng đất đã cầm cố.

Đây là hình thức cố đất rất thông dụng ở vùng nông thôn. Khi một nhà giàu có tiền muốn mua ruộng đất mà người chủ đất chưa muốn bán đi, hai bên bắt đầu thương lượng bằng một sự điển cố. Trong thực tế, phần lớn các trường hợp, người vay tiền vì nghèo túng mà ruộng đất đã phải cầm thế cho chủ nợ, không còn phương tiện doanh sinh, nên khó có thể lo liệu tiền chuộc trong thời hạn đã dự liệu. Chính vì thực trạng như vậy, nên chủ nợ thường nài người vay ghi rõ trong văn tự sự cam kết bán đứt ruộng đất nếu không lo được tiền để trả nợ trong một thời hạn.

1.2.2.3 Cố đất có thỏa thuận cho thuê lại đất đã cố

Bên cạnh hình thức cố đất đơn thuần với điều kiện chuộc lại, việc cố đất với thỏa thuận cho thuê lại đất cũng rất phổ biến trong đời sống dân sự ở vùng nông thôn Việt Nam từ xưa đến nay. Thực tế, tập quán giao dịch cố đất đòi hỏi "bên cố đất phải giao ruộng đất của mình cho bên nhận cố đất canh tác", như là một điểm đặc trưng về nghĩa vụ của loại giao dịch này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bên nhận cố đất không có nhu cầu hoặc không có điều kiên trực tiếp canh tác đất ruộng nên thỏa thuận cho bên cố đất thuê lại ruộng đất đã cố. Văn tự, giấy tờ cố đất vẫn ghi rõ đất cố, giá cả, thời hạn chuộc đất, v.v. cho thấy một giao dịch cố đất vẫn phát sinh thực sự, nhưng kèm theo đó là thỏa thuận cho thuê lại đất đã cố; vô hình chung dẫn đến hệ quả là bên cố đất không phải thực hiện nghĩa vụ giao đất mà vẫn tiếp tục canh tác, chỉ phải nộp hoa lợi, tiền thuê đất theo thỏa thuận.

Trong dân sự, tập quán cố đất với thỏa thuận như trên vẫn còn được duy trì và thường được xác lập giữa bên nhận cố đất là người kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp hoặc những chủ nợ không có điều kiện canh tác đất nông nghiệp; với bên cố đất là nông dân đang cần vốn hoặc đã mắc nợ từ trước. Tuy phần đất đã được đem cố cho

[30] Trang Thông tin điện tử VKSND tỉnh Bến Tre, *Bàn về hợp đồng "thục" QSDĐ*, https://vksbentre.gov.vn/index.php/hi-a-ap-phap-lut/962-ban-v-hp-ng-thc-quyn-s-dng-t [ngày 07/8/2024].

chủ nợ, nhưng người chủ nợ vẫn để cho người vay được tiếp tục canh tác, chỉ phải nộp tiền lãi, hoặc một phần hoa lợi, lợi tức cho chủ nợ.

Ví dụ 2:

Trong một vụ án tranh chấp về giao dịch cố đất có thỏa thuận cho thuê lại ruộng đất, nguyên đơn trình bày sự việc như sau: *Vào ngày 02-02-2002 âm lịch, vợ chồng ông Trần Văn M và bà Phạm Thị T cố đất ruộng cho bà Nguyễn Lệ T1 với diện tích là 05 công tầm cấy, tọa lạc tại Khóm M, Phường X, thị xã N, tỉnh S với giá là 20 chỉ vàng 24K. Thời hạn cố đất thỏa thuận 03 năm sau sẽ chuộc lại. Khi cố đất, ông M và bà T xin thuê lại 05 công đất ruộng để canh tác, mỗi năm sẽ trả lúa khô cho bà T1 bằng 200 kg/công/năm. Đến hạn chuộc đất vào năm 2005, vợ chồng ông M và bà T không có tiền, vàng để chuộc đất nên bà T1 tiếp tục quản lý 05 công đất này cho ông M, bà T thuê trả bằng lúa mỗi năm. Tuy nhiên, sau khi ông M chết thì bà T và các con không tiếp tục trả hoa lợi*[31]. Do đó, bà Nguyễn Lệ T1 yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch cố đất vô hiệu, buộc bà Phạm Thị T và những người thừa kế theo pháp luật của ông Trần Văn M trả lại cho bà số vàng 20 chỉ vàng 24K.

1.2.2.4 Cố đất chỉ phát sinh trong tương lai theo điều kiện thỏa thuận

Thông thường, cố đất có thời hạn chuộc lại hay có cam kết chuyển nhượng QSDĐ được phân tích ở trên được xác lập đồng thời với việc xác lập nghĩa vụ (vay tiền hay mượn vàng). Hay nói cách khác, giao dịch "cố đất" để bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay phải được thực hiện cùng lúc với việc bên nhận cố đất giao tiền, vàng cho bên cố đất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp theo tập quán, các bên xác lập giao dịch cố đất thỏa thuận phân tách việc thực hiện hợp đồng bằng 02 giai đoạn:

(1) Giai đoạn thứ nhất là một giao dịch vay tài sản thông thường, bên cho vay giao cho bên vay một số tiền (hoặc vàng) mà người này cam kết sẽ trả trong một thời hạn được ghi rõ trong giấy tờ, văn tự. Số tiền lãi cũng được hai bên ấn định rõ, hoặc trả theo mỗi năm hoặc trả khi hết hạn vay cùng với số tiền vốn gốc đã vay.

(2) Giai đoạn thứ hai là sự bảo đảm, nếu quá hạn đã cam kết mà bên vay không trả được nợ thì phải cố đất cho bên cho vay. Dĩ nhiên, họ vẫn có quyền được trả nợ và chuộc lại ruộng đất của mình sau khi cố một thời hạn nhất định.

Ví dụ 3:

Trong một bản văn tự điền cố được ghi chép lại như sau:

"*Tôi là Hoàng Huy Viêm và vợ, quán làng Mai Xá, huyện Thượng Nguyên, phủ Thiên Trường, vì thiếu lúa ăn có vay của ông bà Hoàng Đình Cố, người cùng làng, 50 nồi thóc (nồi mười lăm) để ăn tạm và sẽ trả lãi hằng năm là 05 nồi thóc cho mỗi mười*

[31] Tham khảo hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm do TAND thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng thụ lý số 266/2024/TLST-DS ngày 17/10/2023 về việc "Tranh chấp giao dịch cố đất và thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại".

nồi thóc vay. Tôi cam đoan đến mùa tháng 5 năm sau sẽ trả gốc lãi. Nếu quá hạn không trả được, tôi sẽ cố (điển cố) cho ông bà Hoàng Đình Cố 03 sào ruộng tư điền tứ chí như sau [...] Khi nào tôi có thóc, tôi sẽ xin chuộc lại ruộng, chủ nợ không được cố chấp.

Theo pháp luật trong nước, nay lập văn tự này làm bằng.

Niên hiệu Thiệu Trị thứ bảy, ngày 27 tháng 7"[32].

Như vậy, hình thức cố đất nêu trên bao gồm 02 hành vi pháp lý, hay nói cách khác là 02 giao dịch được xác lập kết hợp trong cùng một hợp đồng. Trong đó, giao dịch vay tiền được xác lập và thực hiện ngay tại thời điểm thỏa thuận; còn giao dịch cố đất chỉ xảy ra trong tương lai một cách mặc nhiên khi đáp ứng điều kiện là đến hạn mà bên vay không trả được nợ cho bên cho vay. Lúc này, bên vay tiền buộc phải giao đất để cố cho bên cho vay mà không cần phải xác lập một giao dịch cố đất độc lập mới.

1.2.3 Bản chất pháp lý của giao dịch cố đất theo tập quán

1.2.3.1 Quyền, nghĩa vụ của các bên trong giao dịch cố đất

Về vấn đề này, pháp luật thời phong kiến và trước đây không có điều khoản cụ thể nào quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch cố đất. Tuy nhiên, gián tiếp qua các quy định rải rác, sắc lệnh được ban hành của nhà vua và thực tiễn giao dịch hiện nay, có thể thấy rằng khi xác lập giao dịch cố đất, bên cố đất và bên nhận cố đất có các quyền, nghĩa vụ cơ bản sau đây:

Một là, quyền sở hữu ruộng đất hoặc QSDĐ vẫn thuộc về bên cố đất, người nhận cố đất chỉ có quyền quản lý và canh tác.

Hai là, bên cố đất có quyền trả nợ để chuộc lại ruộng đất đã cố khi đến hạn. Nếu trong hợp đồng không ghi rõ thời hạn chuộc, người cố đất được quyền chuộc lại bất cứ khi nào có điều kiện thanh toán nợ, miễn là không quá thời hạn 30 năm.

Ba là, bên nhận cố đất không thể đương nhiên trở thành chủ sở hữu (hay người có QSDĐ) đối với phần đất đã nhận cố nếu chưa quá 30 năm, mặc dù bên cố đất không trả được nợ khi đến hạn. Do đó, để tránh phát sinh tranh chấp về sau, bên nhận cố đất thường yêu cầu bên cố đất phải cam kết bán đứt số ruộng đất này nếu đến hạn mà không trả được nợ. Lúc này, một "văn tự đoạn mại", tức là hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của Luật Đất đai hiện hành sẽ được ký kết để thay thế cho việc cố đất trong đó, giá chuyển nhượng có thể thương lượng nhưng người ưu tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúc này phải là bên đã nhận cố đất.

Bốn là, trong thời hạn cố đất, mặc dù quyền sở hữu (hay quyền sử dụng) đối với ruộng đất vẫn thuộc về bên cố đất nhưng các bên thường thỏa thuận rằng bên nhận cố đất phải có trách nhiệm nộp thuế, phí (hay thuế điền thổ) và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước liên quan đến QSDĐ. Vì theo quan niệm cũ, thuế điền thổ đánh vào

[32] Vũ Văn Mẫu, *Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn giảng*, Nxb Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1975.

một phần các hoa lợi thu hoạch được, mà các hoa lợi này đều do bên nhận cố đất thụ hưởng trong thời gian ruộng đất còn đang được cầm cố.

1.2.3.2 Phân biệt giao dịch cố đất và thế chấp quyền sử dụng đất

Thế chấp QSDĐ là một trong các giao dịch về QSDĐ được quy định cụ thể trong BLDS và Luật Đất đai hiện hành. Hợp đồng thế chấp QSDĐ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên sử dụng đất (gọi là bên thế chấp) dùng QSDĐ của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với bên kia (gọi là bên nhận thế chấp). Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp, được hưởng hoa lợi, lợi tức từ QSDĐ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác"[33].

Mặc dù có những nét tương đồng nhất định, giao dịch cố đất theo tập quán lại có điểm khác biệt căn bản với việc thế chấp QSDĐ đã được pháp luật hiện hành quy định rõ. Thực sự, khi cố đất theo tập quán, bên cố đất vẫn duy trì quyền sở hữu đất (hay QSDĐ) của mình, nhưng buộc phải giao QSDĐ cho bên nhận cố đất canh tác, hưởng hoa lợi trong một thời hạn nhất định. Trong khi đó, giao dịch thế chấp cho phép bên thế chấp tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp, được hưởng hoa lợi, lợi tức từ QSDĐ đó. Do vậy, hoàn toàn không thể áp dụng khung pháp lý về thế chấp QSDĐ để điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán.

1.2.3.3 Phân biệt giao dịch cố đất và cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Trong các quyền của người sử dụng đất hiện nay thì cho thuê, cho thuê lại QSDĐ là quyền mà hộ gia đình, cá nhân sử dụng thực hiện thường xuyên, phổ biến và chiếm ưu thế trong đời sống thực tế. Thuận ngữ "cho thuê" và "cho thuê lại" QSDĐ được phân biệt dựa vào hình thức sử dụng đất: Nếu hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, nhận QSDĐ có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thì giao dịch này được gọi là *cho thuê lại QSDĐ*; còn nếu hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, công nhận QSDĐ, nhận QSDĐ có nguồn gốc được Nhà nước giao đất thì giao dịch này được gọi là *cho thuê QSDĐ* (những phần sau của luận văn gọi chung đây là giao dịch cho thuê QSDĐ).

Về bản chất pháp lý, cho thuê QSDĐ được xếp vào nhóm quyền không có sự chuyển dịch QSDĐ mà chỉ chuyển giao quyền khai thác và sử dụng đất của bên cho thuê đối với bên đi thuê trong một thời gian. Bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại QSDĐ khi hết thời hạn thuê. Hoa lợi, lợi tức phát sinh trong thời hạn thuê thuộc về bên nhận thuê QSDĐ. Từ những đặc điểm gần giống nhau này, có quan điểm cho rằng giao dịch cố đất theo tập quán, nhất là dạng giao dịch gọi là "thục đất bạc tiêu" vốn tương đồng với khái niệm cho thuê QSDĐ đã được quy định trong BLDS,

[33] PGS.TS. Lê Vũ Nam & Cộng sự, Giáo trình "Pháp luật về Bảo đảm nghĩa vụ", Hà Nội, 2020.

Luật Đất đai và đề xuất có thể áp dụng các quy định này để giải quyết các tranh chấp về giao dịch cố đất trong thực tiễn[34].

Tuy nhiên, đánh giá một cách toàn diện hơn, ta thấy giao dịch cố đất, thục đất (dù ở hình thức "bạc còn" hay "bạc tiêu") theo tập quán có những điểm khác biết rất căn bản so với hợp đồng cho thuê QSDĐ theo pháp luật hiện hành:

Một là, thời điểm trả tiền thuê QSDĐ có thể linh động theo sự thỏa thuận của hai bên; song, đối với giao dịch cố đất theo tập quán, bên nhận cố đất phải giao tiền, vàng cho bên cố đất hoặc có thể đối trừ một khoản nợ đã vay, nhưng chung quy thì việc giao tiền, vàng phải thực hiện trước khi nhận đất để canh tác.

Hai là, khi hết thời hạn thuê QSDĐ, chỉ có bên thuê phải trả lại QSDĐ cho bên cho thuê; song, đối với giao dịch cố đất theo tập quán, cả hai bên đều có nghĩa vụ phải thực hiện theo hướng "trả cho nhau những gì đã nhận". Tức là, ngoài việc bên nhận cố đất phải trả lại QSDĐ thì bên cố đất cũng phải trả lại đúng số tiền, vàng đã nhận để có thể chuộc lại QSDĐ của mình.

Tóm lại, tác giả cho rằng giao dịch cố đất theo tập quán và cho thuê QSDĐ vốn mang những bản chất pháp lý riêng biệt. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào mỗi giao dịch là khác nhau; nhu cầu của người sử dụng đất có mối liên hệ với tính ứng dụng của từng loại giao dịch. Do đó, không thể đồng nhất giao dịch cố đất theo tập quán với khái niệm về cho thuê QSDĐ đã được pháp luật quy định mà cần thiết phải có khung pháp lý riêng để điều chỉnh loại giao dịch đặc biệt này.

1.2.3.4 Phân biệt giao dịch cố đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện chuộc lại

Hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại là một dạng hợp đồng mua bán có điều kiện, có tính chất đặc thù được quy định tại Điều 454 của BLDS năm 2015. Theo đó, *bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại. Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá 01 năm đối với động sản và 05 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm giao tài sản, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.*

Về nguyên tắc, khi giao kết loại hợp đồng này, ngoài việc tuân thủ những quy định chung về hợp đồng dân sự nói chung thì phải tuân thủ những quy định riêng theo hướng

[34] Trang Thông tin điện tử VKSND tỉnh Bến Tre, *Bàn về hợp đồng "thục" QSDĐ*, https://vksbentre.gov.vn/index.php/hi-a-ap-phap-lut/962-ban-v-hp-ng-thc-quyn-s-dng-t [truy cập ngày 07/8/2024].

mở rộng quyền của người bán và hạn chế quyền của người mua. Dường như, nhà làm luật đưa ra quy định này nhằm mục đích bảo vệ bên bán, trong một số trường hợp nhất định có quyền chuộc lại tài sản đã bán. Những tài sản này thường là những tài sản có ý nghĩa và gắn với giá trị về tinh thần hơn là vật chất. Chính vì điểm đặc biệt này, có quan điểm cho rằng giao dịch cố đất theo tập quán vốn chính là một dạng hợp đồng mua bán có điều kiện chuộc lại, đã được quy định trong BLDS Việt Nam và đề xuất áp dụng các quy định này để giải quyết các tranh chấp về giao dịch cố đất trong thực tiễn[35].

Tuy nhiên, từ bản chất của giao dịch đã phân tích tại mục 1.2.3 của luận văn này, ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt căn bản giữa cố đất theo tập quán và mua bán có điều kiện chuộc lại theo BLDS năm 2015. Khi thực hiện giao dịch cố đất, QSDĐ được chuyển giao mà vẫn thuộc về bên cố đất, còn bên nhận cố đất chỉ được quyền quản lý, canh tác hưởng hoa lợi trong một thời hạn thỏa thuận. Ngược lại, mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại (thực tế khi áp dụng với đối tượng là QSDĐ, có thể xem như là giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có điều kiện chuộc lại) thì QSDĐ sẽ được chuyển dịch sang bên nhận chuyển nhượng (bên mua), quyền chuộc lại chỉ là một thỏa thuận kèm theo như là một cơ hội dành cho người chuyển nhượng (bên bán) trong một thời hạn nhất định, hết thời hạn này thì mất quyền.

Ở một khía cạnh khác, trong các thời kỳ lịch sử trước đây, khi mà cố đất được ghi nhận trong các quy phạm pháp luật, nó vốn dĩ là một chế định độc lập, gọi là "điển cố" để phân biệt với chế định về mua bán có điều kiện chuộc lại, gọi là "điển mại". Thực tế, điển mại nằm trong phạm vi các khế ước mua bán, nhưng dự liệu cho người bán được quyền chuộc lại các điền sản đã bán; phân biệt với cả đoạn mại và điển cố tài sản. Bộ Dân luật Bắc kỳ cũng đã công nhận điển mại là một khế ước bán với quyền được chuộc lại (Vente à réméré), quy định khế ước này trong các điều 957 và kế tiếp, còn khế ước cầm cố bất động sản (nantissement immobilier) được quy định trong các điều 1331 và kế tiếp.

Do đó, trong bối cảnh hiện đại, cố đất theo tập quán cũng không thể đồng nhất với khái niệm về mua bán tài sản hay chuyển nhượng QSDĐ với điều kiện chuộc lại được quy định trong BLDS năm 2015. Về bản chất pháp lý, nhu cầu ứng dụng, quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào 02 loại giao dịch này là có sự khác biệt nên nhất thiết phải có quy chế pháp lý để điều chỉnh riêng từng loại giao dịch.

1.2.4 Lý do người dân ở nông thôn vẫn lựa chọn giao dịch cố đất theo tập quán

Với bản chất pháp lý, đặc trưng cơ bản của giao dịch cố đất cho thấy chưa có cơ sở đồng nhất giao dịch này với bất kỳ giao dịch nào hiện có trong pháp luật thực định của Việt Nam. Song, thay vì lựa chọn những giao dịch dân sự tương đồng đã được quy định rõ ràng, minh bạch trong luật thành văn; thậm chí là những giao dịch cùng loại

[35] Sỹ Hồng Nam, "*Hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại và giải quyết tranh chấp tại Tòa án*", Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số tháng 01/2012.

được đánh giá có tính "ưu việt" hơn, hiện đại hơn nhưng thực tế, người dân ở nông thôn vẫn lựa chọn thiết lập quan hệ cố đất vì những lý do sau:

Một là, đáp ứng nhu cầu tài chính trước mắt mà không mất QSDĐ lâu dài. Cố đất cho phép người sử dụng đất nhận được một khoản tiền lớn trước mắt để giải quyết nhu cầu tài chính, chẳng hạn như chữa bệnh, đầu tư, hoặc trang trải chi phí sinh hoạt. Đồng thời, giao dịch này không dẫn đến mất QSDĐ vĩnh viễn, bởi bên cố đất có quyền chuộc lại đất sau một thời gian nhất định. Điều này khác với chuyển nhượng QSDĐ, nơi mà QSDĐ sẽ được chuyển giao hoàn toàn và không thể thu hồi.

Hai là, tạo cơ hội khai thác đất trong thời gian tạm thời với số vốn tương đối. Trong quan hệ cố đất, bên nhận cố có quyền sử dụng đất trong thời hạn cố để khai thác và hưởng lợi từ đất, thường là canh tác nông nghiệp hoặc kinh doanh nhỏ. Điều này phù hợp với thói quen và nhu cầu thực tế ở nông thôn, nơi đất đai có giá trị lớn trong việc sản xuất. Với người nhận cố, đây là một cách đầu tư tài chính an toàn, đồng thời tận dụng được giá trị sử dụng đất trong khi chờ bên cố chuộc lại.

Ba là, duy trì mối quan hệ cộng đồng và đảm bảo tính linh hoạt. Cố đất thường được thực hiện giữa các cá nhân trong cùng một cộng đồng, như họ hàng, hàng xóm, hoặc bạn bè thân thiết. Điều này không chỉ tạo niềm tin giữa các bên mà còn đảm bảo tính linh hoạt trong việc chuộc lại đất, chẳng hạn gia hạn thời hạn cố hoặc điều chỉnh số tiền chuộc. Giao dịch này cũng giúp giảm nguy cơ xung đột và bảo vệ mối quan hệ lâu dài trong cộng đồng.

Bốn là, sự ảnh hưởng của truyền thống và thói quen sử dụng đất lâu đời. Quan hệ cố đất phản ánh một tập quán lâu đời ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, nơi đất đai không chỉ là tài sản kinh tế mà còn có giá trị tinh thần và gắn liền với truyền thống gia đình. Người dân thường e ngại việc chuyển nhượng đất vì sợ mất đi nguồn sinh kế và ảnh hưởng đến quyền lợi của con cháu. Cố đất, với tính chất tạm thời, đáp ứng nhu cầu tài chính trước mắt mà vẫn giữ được đất đai trong tay gia đình.

Tóm lại, **s**ự lựa chọn thiết lập quan hệ cố đất thay vì các giao dịch khác phản ánh luận điểm quan trọng của lý thuyết hành động xã hội dựa trên sự lựa chọn hợp lý của các chủ thể. Cụ thể ở đây là nhu cầu linh hoạt về tài chính, tính thực tiễn trong khai thác đất đai, và sự phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở nông thôn.

1.3 Pháp luật về giao dịch cố đất ở một số quốc gia và quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch cố đất qua các thời kỳ

1.3.1 Quy định pháp luật của một số quốc gia về giao dịch cố đất

1.3.1.1 Pháp luật của Pháp

BLDS Pháp[36] được thiết kế dựa trên hai chế định cơ bản là trái quyền và vật quyền. Trái quyền hay còn gọi là quyền đối nhân được hiểu là quyền của một chủ thể đối với

[36] Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bản dịch BLDS Pháp, Hà Nội, 2018.

một chủ thể khác. Vật quyền hay còn gọi là quyền đối vật là quyền của chủ thể tác động lên một vật. Các biện pháp bảo đảm cũng được thiết kế theo triết lý trái quyền và vật quyền và được chia thành hai loại là vật quyền bảo đảm và trái quyền bảo đảm. Vật quyền bảo đảm có sức mạnh đặc biệt vì nó tạo ra quyền trực tiếp của chủ nợ có bảo đảm đối với giá trị kinh tế của tài sản bảo đảm, thể hiện ở quyền theo đuổi và quyền ưu tiên của chủ nợ có bảo đảm. Quyền theo đuổi là quyền truy đòi tài sản bảo đảm dù tài sản đó không còn được con nợ nắm giữ. Quyền ưu tiên là quyền của chủ nợ có bảo đảm được ưu tiên thanh toán trước các chủ nợ không có bảo đảm.

Giao dịch về cố đất được ghi nhận trong pháp luật dân sự của Pháp với tư cách là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đó là cầm cố tài sản. Tuy nhiên, khác với quy định của pháp luật Việt Nam, đất (QSDĐ) là bất động sản thuộc đối tượng được phép giao dịch bảo đảm bằng cầm cố tài sản. Theo đó, Điều 2373 BLDS Pháp quy định: "*Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bằng bất động sản bao gồm quyền ưu tiên, cầm cố bất động sản và thế chấp. Quyền sở hữu đối với bất động sản cũng có thể được bảo lưu hoặc chuyển giao nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ*".

Về quyền, nghĩa vụ của các bên trong giao dịch cầm cố bất động sản cũng được pháp luật nước này quy định rõ từ Điều 2387 đến Điều 2392 của BLDS. Một cách tổng quán, cầm cố bất động sản trong pháp luật dân sự của Pháp là việc dùng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; bên cầm cố phải chuyển giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố. Bên nhận cầm cố được thu hoa lợi, lợi tức từ bất động sản cầm cố với điều kiện phải khấu trừ hoa lợi, lợi tức đó vào lãi, nếu có, và sau đó vào tiền gốc của nghĩa vụ. Bên nhận cầm cố có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn bất động sản và có thể dùng hoa lợi, lợi tức thu được để thanh toán các chi phí đó trước khi khấu trừ vào nghĩa vụ được bảo đảm, nếu không sẽ mất quyền hưởng hoa lợi, lợi tức từ bất động sản cầm cố. Bên nhận cầm cố có thể trả lại tài sản cho chủ sở hữu bất cứ lúc nào để được miễn thực hiện nghĩa vụ trên.

Tóm lại, có thể thấy trong quy định của pháp luật dân sự Pháp, đất đai (hay QSDĐ) vốn được xem là một loại bất động sản nên được phép cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Điều này có sự khác biệt so với pháp luật Việt Nam hiện hành, mặc dù thừa nhận và cho phép cầm cố bất động sản nhưng riêng QSDĐ lại không phải là đối tượng được phép cầm cố. So với cố đất theo tập quán tại Việt Nam thì cầm cố bất động sản trong pháp luật của Pháp cũng có đôi chút khác biệt về quyền, nghĩa vụ của các bên; song, cả hai loại giao dịch này đều giống nhau ở căn bản. Về tính phổ biến, giao dịch cố đất ở Việt Nam diễn ra rất phổ biến ở nông thôn; còn cầm cố bất động sản ở Pháp, theo đánh giá, là không được áp dụng nhiều trên thực tế vì chủ nợ không muốn phải quản lý bất động sản được giao cùng với các nghĩa vụ kèm theo nêu trên[37].

[37] Nhà Pháp luật Việt - Pháp, Tổng hợp một số quy định pháp luật Cộng hòa Pháp về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, Báo Điện tử Chính phủ, https://baochinhphu.vn/tong-hop-mot-so-quy-dinh-phap-luat-cong-hoa-phap-ve-cac-bien-phap-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-dan-su-102117768.htm [truy cập 03/3/2024].

1.3.1.2 Pháp luật của Lào

BLDS năm 2018 của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào[38] có nhiều điểm tương đồng với BLDS năm 2015 của Việt Nam. Liên quan đến giao dịch cố đất, pháp luật của Lào đề cập đến giao dịch này như là một biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bằng "cầm cố tài sản" và được quy định rõ trong BLDS.

So với pháp luật dân sự và Luật Đất đai của Việt Nam, cầm cố tài sản đã được quy định có thể cầm cố bằng động sản hoặc bất động sản nhưng lại không có quy định làm rõ QSDĐ có phải là một trong số các bất động sản được phép cầm cố hay không, từ đó tạo nên nhiều quan điểm áp dụng khác nhau. Ngược lại, BLDS của Lào quy định rõ có 03 loại cầm cố chính đó là: Cầm cố bằng động sản, cầm cố bằng bất động sản và cầm cố bằng quyền. Theo đó, bất động sản có thể được sử dụng làm bảo đảm bao gồm: (1) QSDĐ của cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức: (2) Quyền sở hữu căn hộ, công trình như nhà, dãy hoặc tòa nhà; (3) Các tài sản có liên quan đến hợp đồng thuê hoặc tô nhượng đất theo quy định của pháp luật và các hợp đồng có liên quan.

Cầm cố bất động sản được quy định cụ thể trong 05 điều, từ Điều 535 đến Điều 539 của BLDS Lào. Theo đó, quyền sở hữu đối với bất động sản cầm cố vẫn thuộc về bên cầm cố, nhưng bất động sản thuộc quyền kiểm soát của bên cầm cố. Bên nhận cầm cố có quyền sử dụng hoặc hưởng lợi tức bất động sản nhưng không có quyền tính lãi với bên cầm cố. Bên nhận cầm cố có quyền ưu tiên trong việc được trả nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ trước các chủ nợ khác (Điều 537 BLDS năm 2018 của Lào). Chính những hệ quả pháp lý cơ bản quy định tại Điều luật này cho thấy có sự tương đồng rất gần so với giao dịch cố đất theo tập quán ở Việt Nam. Điểm khác biệt là, giao dịch cầm cố QSDĐ tại Lào đã được pháp luật quy định cụ thể.

1.3.1.3 Pháp luật của Nhật Bản

BLDS Nhật Bản quy định 4 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bao gồm: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, cầm giữ tài sản và quyền ưu tiên thanh toán trước so với các chủ thể khác. Pháp luật cũng làm rõ việc không cho phép các bên được áp dụng các vật quyền bảo đảm khác các vật quyền được quy định trong BLDS (Điều 175 BLDS Nhật Bản). Xuất phát từ nguyên nhân vật quyền có ảnh hưởng không chỉ đến các bên khác mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người khác.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý mà tác giả muốn đề cập khi nghiên cứu về pháp luật của Nhật Bản liên quan đến giao dịch cố đất không phải dưới góc nhìn của một biện pháp bảo đảm theo luật định. Bên cạnh các biện pháp bảo đảm theo luật định, nhiều biện pháp bảo đảm khác được phát triển thông qua thực tiễn xét xử của Tòa án, điển hình là Joto tampo - biện pháp chuyển nhượng quyền sở hữu để bảo đảm.

[38] Tạp chí Lào - Việt, BLDS nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2018 (bản dịch), https://tapchilaoviet.org/phap-luat/thu-vien-phap-luat/bo-luat-dan-su-nuoc-chdcnd-lao-nam-2018-41169.html [truy cập 03/3/2024].

Về cách thức vận hành, biện pháp chuyển nhượng quyền sở hữu để bảo đảm có thể hiểu như sau: Người mắc nợ sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản bảo đảm cho chủ nợ và quyền chiếm hữu tài sản vẫn thuộc về người mắc nợ. Thí dụ, người chuyển nhượng hàng hóa là người sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu để bảo đảm, tuy nhiên vẫn giữ chiếm hữu về mặt vật lý đối với tài sản và sử dụng tài sản với tư cách là đại lý của chủ nợ. Cần lưu ý, việc chuyển giao này đối với hàng hóa chỉ là chuyển giao về mặt danh nghĩa để xác định ngày giao hàng và thứ tự ưu tiên. Như vậy, biện pháp này tương đối giống với thế chấp tài sản thông thường; tuy nhiên, đối với thế chấp tài sản thì người mắc nợ sẽ không cần phải chuyển giao quyền sở hữu thì đối với joto tampo thì việc chuyển giao quyền sở hữu là cần thiết. Biện pháp bảo đảm này mang lại cho bên nhận bảo đảm một số ưu điểm so với biện pháp thế chấp tài sản trên thực tế - đó là tính thuận tiện cho bên bảo đảm cũng như ưu thế khi xử lý tài sản bảo đảm của bên nhận bảo đảm.

Dưới góc độ lịch sử, biện pháp joto tampo đã tồn tại từ lâu trong xã hội Nhật Bản, đặc biệt là trong quá trình chuyển hóa của nền kinh tế Nhật Bản. Từ năm 1906, Tòa án tối cao đã công nhận hiệu lực của Joto tampo và đưa ra các tiêu chí để phân biệt với các loại hợp đồng khác trên thực tế. Sau đó, biện pháp bảo đảm này được tiếp tục củng cố và công nhận bởi Tòa án tối cao trong các phán quyết từ 1915-1916 và được công nhận và áp dụng trên thực tế cho đến ngày nay.

Dưới góc độ so sánh, dễ thấy pháp luật Việt Nam và Nhật Bản có những nét tương đồng trong việc quy định về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ. Cụ thể, pháp luật đều liệt kê các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ cụ thể và dường như không trực tiếp thừa nhận các biện pháp bảo đảm khác do thỏa thuận. Trong bối cảnh đó, để đáp ứng các nhu cầu của xã hội đặt ra, Tòa án tối cao Nhật Bản đã khắc phục khiếm khuyết này thông qua việc công nhận hiệu lực của các biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận thông qua thực tiễn xét xử.[39] Tòa án Nhật Bản chấp nhận các thỏa thuận này giữa các bên, chủ yếu dựa trên sự lý giải như sau: Các thỏa thuận bảo đảm này, mặc dù không được quy định theo BLDS, tuy nhiên, đây là các thỏa thuận có thể thực thi dựa trên cơ sở của pháp luật hợp đồng, cụ thể hơn là pháp luật về nghĩa vụ. Do đó, mặc dù không được quy định bởi BLDS, nhưng có thể dựa vào các quy định pháp luật về nghĩa vụ thì đây có thể xem như một thỏa thuận giữa các bên không trái với pháp luật nên có cơ sở để công nhận.

1.3.2 Quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch cố đất qua các thời kỳ

1.3.2.1 Thời kỳ phong kiến

Quy định cổ nhất về cầm cố ruộng đất mà ngày nay ta còn thấy ghi chép trong chính sử đã được ban hành dưới triều vua Lý Anh Tông (1128 – 1175). Vào tháng 12 năm Đại Định thứ ba (1142), vua xuống chiếu quy định thể lệ cầm cố ruộng đất như sau:

[39] Liên Đăng Phước Hải, *Kinh nghiệm phát triển các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ngoài luật định tại Nhật Bản và một số gợi mở cho Việt Nam*, https://phaply.net.vn/kinh-nghiem-phat-trien-cac-bien-phap-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-ngoai-luat-dinh-tai-nhat-ban-va-mot-so-goi-mo-cho-viet-nam-a257609.html

"*Phàm ai cầm cố những ruộng thực điền thì trong hạn 20 năm được phép chuộc lại; phàm những ruộng hoang bị người khác cày cấy rồi thì trong hạn 01 năm được phép thưa kiện mà nhận lại, quá hạn ấy đều cấm chỉ. Những ruộng đất đã bán đứt rồi hiện có văn khế và khoán ước thì không được chuộc nữa. Kẻ nào vi phạm sẽ bị phạt 80 trượng. Tranh nhau ruộng ao, mà đem đồ binh khí đánh nhau đến tử thương thì phạt 80 trượng, và phải tội đồ; còn ruộng, ao thì trả cho phía người bị tử thương*"[40].

Thời nhà Lê có bộ Quốc triều Hình luật được ban hành dưới triều Lê Thánh Tông (1483) niên hiệu Hồng Đức nên còn được gọi là Luật Hồng Đức. Bộ Quốc triều Hình luật ghi nhận hai chế độ sở hữu đối với ruộng đất là ruộng công và ruộng tư. Ruộng công thuộc quyền sở hữu của Vua và của làng xã, còn ruộng tư thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất cũng được luật Hồng Đức rất chú trọng. Luật quy định nghiêm cấm các hành vi xâm chiếm, bán trộm hay tranh giành ruộng đất như: cấm xâm lấn ruộng đất của người khác (Điều 357). Như vậy, pháp luật nhà Lê thừa nhận và bảo vệ sở hữu tư nhân về đất đai, cho phép chuyển dịch quyền sở hữu đất đai thông qua lập khế ước. Điều đó cũng hàm nghĩa rằng một người có quyền sở hữu đất đai thì đương nhiên có quyền định đoạt đối với đất đai. Giao dịch cố đất cũng được pháp luật điều chỉnh. Tại Đoạn 91 của Hồng Đức thiện chính thư ghi rõ: "*Ruộng đất đã đem cầm mà chưa chuộc, lại đem bán cho người khác, sẽ bị tội trượng tám chục (80 trượng), khép vào tội lưu, ruộng đất ấy trả lại cho chủ mua (cầm) trước. Nếu người sau không biết mà mua lầm, thì không phải tội*".

Trường hợp "Thực kế hư tiền lệ" được dự liệu rõ ràng tại đoạn 314 của Hồng Đức Thiện Chính thư: "*Nếu cầm, bán ruộng, ao, đất, nhà, dẫu có văn khế mà chủ bán vẫn giữ cày hay ở, lúc lúa chín hoặc hoa quả chín, không có thu hoạch rẽ*[41]*, mãi về sau đôi bên mới lại tranh tụng, trường hợp ấy sẽ xử là "Thực khế hư tiền"*[42]*, lấy lại văn khế trả cho chủ bán. Trái lịnh này sẽ bị tội tám mươi trượng. Nếu cầm bán cho người làng khác xa xôi, thì không dùng cấm lệ này*".

Theo lệ này, ta có thể kết luận rằng trong trường hợp thông thường sau khi làm văn khế cầm cố ruộng đất thì ruộng đất đó phải được giao ngay cho người chủ nợ để canh tác. Nếu người nhận cầm cố đất để lại ruộng đất cho người cố đất tiếp tục canh tác thì phải xem là một sự *cho thuê lại ruộng đất đã cầm cố*, phải ghi rõ thỏa thuận cho thuê lại vào văn tự cố đất để tránh việc tranh chấp về sau.

Về thời hạn chuộc đất: Trong Điều 384 của Bộ luật Hồng Đức, nhà làm luật cũng

---

[40] Khâm định Việt sử Thông Giám Cương mục – Chính biên – Quyển IV, tr. 165 và Đại Việt Sử ký toàn thư, 2013, Nxb Thời Đại, tr. 235.

[41] *Thu hoạch rẽ* có nghĩa là "chia đôi" nên giả định *không có thu hoạch rẽ* ở đây được hiểu là trường hợp bên cố đất không chia đôi số lúa chín hoặc hoa quả chín thu hoạch được cho bên nhận cố đất.

[42] *Thực khế* nghĩa là có khế ước, *hư tiền* là không có giao tiền, lệ này tức là nói đến trường hợp có làm văn khế cầm, bán mà bêm cầm, bán chưa thực hiện nghĩa vụ giao tiền.

dự liệu rõ ràng cả thời kỳ chuộc ruộng hàng năm, để khỏi thua thiệt đến mùa màng của người đang nhận cố đất: "*Đối với ruộng mùa (gặt hái vào vụ tháng 10) phải chuộc vào ngày 15 tháng 3; đối với ruộng chiêm (gặt hái vào vụ tháng 5) thì kỳ hạn chuộc là 15 tháng 9*". Nói cách khác, việc chuộc ruộng đã cố phải trước khi làm vụ mùa sau để khỏi gây sự thiệt thòi cho người nhận cố đất đã cày cấy hoặc sắp được thu hoạch. Nếu thời hạn chuộc không được dự liệu rõ ràng thì người cố đất được quyền hành sử quyền ấy trong một hạn là 30 năm. Thời hạn 30 năm này là một thời hiệu tiêu diệt đối với quyền chuộc ruộng đất của người cố đất.

Thời nhà Nguyễn, do sự lệ thuộc về chính trị nên pháp luật triều Nguyễn là bản sao chép pháp luật của nhà Thanh (Trung Quốc). So với Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long của triều Nguyễn "không còn những điều khoản liên quan đến hương hỏa, chúc thư, đến chế độ tài sản của vợ chồng". Pháp luật triều Nguyễn từ Gia Long đến Tự Đức (1802 - 1884), điển hình là bộ Hoàng Việt luật lệ, được biên soạn và hoàn tất năm 1811, năm 1813 Luật được ban hành (Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hựu, 1994). Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất của triều Nguyễn không lớn, xu hướng ngày càng bị thu hẹp. Tuy nhiên, pháp luật thời kỳ nhà Nguyễn tiếp tục công nhận và bảo vệ sở hữu tư nhân đối với đất đai. Người sở hữu đất có quyền định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Giao dịch cố đất thời kỳ này vẫn tồn tại và được điều chỉnh.

Trong quyển "Chúc thư văn khế cựu chỉ" có chép một văn khế cầm cố ruộng đất nhân dịp cưới xin vì nhà trai không có tiền dẫn cưới cho nhà gái, thay vì gán ngay mảnh đất đó cho nhà gái để thay cho tiền dẫn cưới, hoặc bán đứt đi để lấy tiền thì nhà trai đã cầm cố ruộng đất cho nhà gái như sau:

"Tôi là Vũ Tạo, và vợ ở Thôn Trung, làng Thanh Nê, huyện Chân Định, phủ Kiến Xương, có con trai là Vũ Trụ sắp lấy con gái ông Vũ Xuân Đồng và bà Vũ Thị Như, người cùng thôn. Chúng tôi đã nộp tiền cheo trong làng, nhưng còn tiền dẫn cưới là 70 quan tiền, thì chúng tôi cầm thế một mẫu ruộng ở xứ Cái Long, tứ chí như sau: ...

... Người chủ hôn nhà gái có quyền canh tác ruộng ấy. Khi nào tôi có tiền, tôi có thể chuộc lại, không được cố chấp. Theo pháp luật trong nước, nay lập văn tự này làm bằng.

Minh Mạng năm thứ 8, ngày 16 tháng mười một"[43].

Trong sắc dụ niên hiệu Minh Mạng thứ 20, quy định về hạn chuộc ruộng, nhà vua đã ban hành thể lệ "*Nếu điển cố điền thổ mà trong khế ước không ghi rõ niên hạn thì quá hạn 30 năm, bên nhận điển cố sẽ được làm chủ sở hữu vĩnh viễn đối với các ruộng đất đã cố*". Đây là quy định ban ra nhằm giải quyết ngay một "ngách" nhỏ trong hệ thống các thỏa thuận và chế tài để xử lý hệ quả của thỏa thuận cố đất khi đã quá hạn 30 năm mà người cố đất vẫn không chuộc lại đất, tránh trường hợp bên cố đất rõ ràng đã từ bỏ

[43] Vũ Văn Mẫu, Tlđd, tr. 72.

quyền chuộc lại mà bên nhận cố đất thì đang bị lấp lửng về mặt pháp lý, canh tác đất mãi tận 30 năm mà không phải đất của mình. Hệ quả là, theo quy định của pháp luật thời kỳ này khi chưa phải là chủ sở hữu thực sự thì chưa có quyền để thừa kế, sang bán hay tặng cho người khác. Do đó, điều này ban hành để giải quyết vấn đề pháp lý tức thời nhưng cho thấy rằng giao dịch cố đất đã được thừa nhận và áp dụng tương đối rộng rãi trong đời sống xã hội lúc bấy giờ.

1.3.2.2 Thời kỳ Pháp thuộc (1858 – 1945)

Từ năm 1862 - 1884, triều đình nhà Nguyễn lần lượt ký với chính phủ Pháp 3 Hiệp ước chấp nhận ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Việt Nam là một quốc gia thống nhất bị chia cắt thành 3 kỳ: Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ. Bắc và Trung kỳ là xứ bảo hộ, còn Nam kỳ là xứ thuộc địa. Ngay sau khi chiếm được Nam kỳ, chính phủ Pháp đã ban hành Sắc lệnh ngày 25/7/1864 về Tổ chức Tư pháp tại các vùng thuộc Pháp, theo đó Chính quyền thuộc địa sẽ áp dụng các bộ luật, các đạo luật của nước Pháp. Sắc lệnh ngày 03/10/1883 quy định về ban hành "Dân luật giản yếu" sao chép bộ luật Napoléon về nguyên tắc thừa nhận chế độ tư nhân về đất đai, do đó là quyền tặng cho đất. Tại Bắc kỳ và Trung kỳ, chính quyền thực dân đã thực hiện nhiều thể chế pháp lý phù hợp với hoàn cảnh để điều chỉnh quan hệ dân sự ở Việt Nam. Bộ Dân luật Bắc kỳ (tên đầy đủ là Bộ Dân luật thi hành tại các Tòa Nam án Bắc kỳ), Bộ Dân luật Trung kỳ (hay còn được gọi là Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật) đều được ban hành năm 1939 với tổng cộng 1709 điều.

Do pháp luật quy định đất đai thuộc sở hữu tư nhân nên các quyền năng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt của chủ sở hữu đất đai được pháp luật thừa nhận và bảo vệ; vì vậy, quyền cầm cố đối với đất đai cũng được Nhà nước cho phép. "*Việc cầm cố bất động sản là một khế ước do một người mắc nợ giao cho người chủ nợ một bất động sản nào đó để làm tin"* (Điều 1334 Dân luật Bắc kỳ)[44]. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định tương đối chặt chẽ đối với khế ước loại này phải được lập thành văn bản, "*phải có chứng thư do nô-te làm hay viên chức thị thực mới được. Ở nơi nào có địa bạ, thì phải đăng ký vào địa bạ mới có thể đối dụng với bên thứ ba được*" (Điều 1335 Dân luật Bắc kỳ). Đây là quy định nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, đồng thời cũng là cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp của các bên liên quan trong vấn đề cầm cố ruộng đất.

Ở Trung kỳ, Hoàng Việt Hộ Luật[45] cũng đã định ra quy chế pháp lý riêng cho loại giao dịch này. Tuy nhiên, pháp luật lúc này sử dụng thuật ngữ "thế chấp bất động sản" để nói với giao dịch cố đất. Sở dĩ như vậy vì theo quy định từ Điều 1527 đến Điều 1559, quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch gọi là "thế chấp bất động sản" lại chứa đựng hình ảnh của một giao dịch cố đất thực sự. Theo đó, "*việc thế chấp bất động sản là một khế ước thuộc về vật quyền do một người mắc nợ giao cho người chủ nợ một bất*

[44] Gouverment Général De l'Indochine (Phủ Toàn quyền Đông Dương), Code Civil à l'usage des Juridictions Indiènes du Tonkin - Dân luật thi hành tại các Tòa Nam án Bắc kỳ, Hà Nội, 1931.

[45] Hoàng Việt Trung kỳ Hộ Luật (Code Civil de l'Annam), Nxb. Tiếng Dân, Huế, 1944.

động sản để đảm bảo món nợ" (Điều 1527 Hoàng Việt Hộ Luật). Mà như đã biết, việc thế chấp nếu sử dụng đúng bản chất của nó thì bên thế chấp không phải giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Mặc khác, định nghĩa này cũng không có ý nghĩa gì khác biệt so với định nghĩa về "cầm cố bất động sản" được ghi tại Điều 1334 của Dân luật Bắc kỳ nêu trên, có chăng chỉ thay thế cụm từ *cầm cố* bởi cụm từ *thế chấp* mà thôi.

Như vậy, ba bộ luật được thi hành ở ba kỳ của chính quyền thực dân Pháp lúc bấy giờ đã có ý nghĩa lịch sử quan trọng, ngoài việc kế thừa phát huy các yếu tố dân chủ, tiến bộ của BLDS Pháp, nó vẫn phản ánh được phong tục, tập quán, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hai hình thức sở hữu ruộng đất cơ bản xuất phát từ chế độ phong kiến vẫn được duy trì và phát triển. Mặc dù pháp luật thời kỳ này chịu ảnh hưởng của Pháp, song đã có những bước phát triển mới về các quy định về cầm cố ruộng đất.

1.3.2.3 Thời kỳ cải cách ruộng đất đến nay

Ở góc độ luật chung, pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ đều công nhận và cho phép áp dụng tập quán. Tuy nhiên, sự khuyết thiếu quy định pháp luật điều chỉnh về giao dịch cố đất trong một thời gian dài, kể từ khi Luật Đất đai đầu tiên năm 1987, sau đó là BLDS đầu tiên của Việt Nam năm 1995 cho đến nay đã hình thành nhiều quan điểm khác nhau. Trong đó, có quan điểm cho rằng đây là loại giao dịch dân sự bị cấm thực hiện. Các vấn đề đã đặt ra và có nhiều tranh luận đó là: "bản chất của giao dịch cố đất là gì", "pháp luật có cho phép người dân cố đất không?" và bằng thuật ngữ pháp lý Việt Nam hiện đại, câu hỏi đặt ra là: QSDĐ có được phép cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không? Từ thực tiễn xét xử, các vụ án tranh chấp giao dịch cố đất thường được xác định tên quan hệ tranh chấp là "Tranh chấp hợp đồng cầm cố QSDĐ". Kết quả xét xử cho thấy, không ít trường hợp Tòa án tuyên xử theo hướng hợp đồng vô hiệu với nhận định do pháp luật không quy định về quyền cầm cố QSDĐ nên đương sự thực hiện giao dịch này là vi phạm điều cấm, trái quy định của pháp luật[46].

1.4 Nguyên tắc pháp lý, các giá trị và tiêu chí xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam

1.4.1 Khái niệm nguyên tắc pháp lý

Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học, 2020) định nghĩa, *nguyên tắc* là điều cơ bản, cốt yếu làm căn cứ để suy nghĩ hoặc hành động, *pháp lý* là vấn đề liên quan đến luật pháp, thuộc về luật pháp, hoặc được xác định, điều chỉnh bởi luật pháp.

Theo đó, khái niệm nguyên tắc pháp lý có thể hiểu là các quan điểm cơ bản có tính định hướng, chi phối quá trình xây dựng, áp dụng và giải thích pháp luật trong một hệ thống pháp luật. Đây là các chuẩn mực pháp lý mang tính khái quát cao, thể hiện ý chí chung của nhà nước và xã hội, được thừa nhận và bảo vệ bởi hệ thống pháp luật.

[46] Ths. Bùi Ai Giôn, *Bàn về cầm cố QSDĐ và quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí điện tử Kiểm sát, https://kiemsat.vn/ban-ve-cam-co-quyen-su-dung-dat-va-quyen-so-huu-tri-tue-63955.html [truy cập 17/3/2024]

Đặt trong mối quan hệ với khái niệm "khung pháp lý", ta thấy nguyên tắc pháp lý có sự khác biệt về bản chất. Nếu như nguyên tắc pháp lý là tư duy, quan điểm nền tảng mang tính định hướng, khái quát cao, thể hiện các giá trị cốt lõi thì khung pháp lý là tập hợp các quy định cụ thể, chi tiết trong các văn bản pháp luật được xây dựng để điều chỉnh một lĩnh vực hoặc vấn đề nhất định, có tính thực thi cao và thay đổi linh hoạt theo yêu cầu thực tiễn. Nguyên tắc pháp lý đảm bảo tính nhất quán và định hướng còn khung pháp lý là công cụ trực tiếp để quản lý các quan hệ xã hội và thực hiện quyền, nghĩa vụ của các chủ thể. Nói cách khác, nguyên tắc pháp lý là nền tảng, còn khung pháp lý là sự cụ thể hóa các nguyên tắc đó trong đời sống thực tế.

Nguyên tắc pháp lý có các đặc trưng cơ bản sau đây:

- Tính định hướng: Nguyên tắc pháp lý xác định phương hướng cơ bản cho quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật. Nó định hình nội dung và mục tiêu của các quy phạm pháp luật, đồng thời đảm bảo rằng pháp luật được xây dựng phù hợp với những giá trị cốt lõi của xã hội, như công lý, tự do, bình đẳng và nhân quyền.

- Tính khái quát và ổn định: Nguyên tắc pháp lý mang tính khái quát cao, không đi sâu vào các tình huống cụ thể mà tập trung vào việc xác định các chuẩn mực chung. Vì vậy, nguyên tắc pháp lý thường có tính ổn định cao hơn so với các quy phạm pháp luật cụ thể và ít thay đổi theo thời gian.

- Tính ràng buộc pháp lý, hướng dẫn và chỉ đạo: Dù mang tính định hướng, nguyên tắc pháp lý có giá trị ràng buộc đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi và giải thích pháp luật. Mọi quy phạm pháp luật hoặc hành vi pháp lý trái với nguyên tắc pháp lý đều bị coi là không hợp pháp.

1.4.2 Các giá trị mang lại của việc xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh một quan hệ xã hội nội sinh chưa có điều luật áp dụng

Xây dựng nguyên tắc pháp lý là quá trình định hình và thiết lập các quy cơ bản để định hướng việc xây dựng, áp dụng, và thực thi pháp luật. Xây dựng nguyên tắc pháp lý đóng vai trò định hướng tư duy và tạo nền tảng lý luận chung, là cơ sở để xây dựng các văn bản pháp luật, giải thích pháp luật, và áp dụng pháp luật. Đối với một quan hệ xã hội đã phát sinh, tồn tại trong thực tiễn mà pháp luật thành văn chưa có quy định, việc xây dựng những nguyên tắc pháp lý để điều chỉnh mang lại những giá trị cốt lõi quan trọng, góp phần định hướng, điều chỉnh, hỗ trợ việc quản lý các quan hệ này một cách hợp lý, công bằng và hiệu quả. Những giá trị nổi bật đó bao gồm:

1.4.2.1 Lấp đầy khoảng trống pháp lý và tăng cường tính công bằng

Việc xây dựng nguyên tắc pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội chưa có quy định mang lại giá trị quan trọng đầu tiên là lấp đầy những khoảng trống pháp lý trong hệ thống luật hiện hành. Trong nhiều trường hợp, quan hệ xã hội nội sinh, chẳng hạn như các giao dịch dân sự thông qua tập quán ở nông thôn, không được quy định đầy đủ trong luật pháp hiện hành, dẫn đến tình trạng thiếu cơ sở để giải quyết tranh chấp hoặc

bảo vệ quyền lợi các bên. Các nguyên tắc pháp lý giúp thiết lập nền tảng cho việc áp dụng luật một cách linh hoạt, đồng thời tạo ra các tiền lệ cần thiết để xử lý những vấn đề tương tự trong tương lai. Chẳng hạn, trong giao dịch cố đất, khi pháp luật chưa có quy định rõ ràng, việc dựa vào nguyên tắc công bằng giữa bên nhận đất và bên giao đất sẽ giúp đảm bảo lợi ích của cả hai bên.

Hơn nữa, các nguyên tắc pháp lý giúp tăng cường tính công bằng trong quan hệ dân sự bằng cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Chúng cung cấp một khung định hướng rõ ràng cho các thỏa thuận, giảm nguy cơ một bên lạm dụng vị thế mạnh hơn để chèn ép bên yếu hơn. Chẳng hạn, trong các giao dịch dân sự liên quan đến vay mượn tài sản bảo đảm bằng QSDĐ ở vùng nông thôn, nguyên tắc tự nguyện và công bằng giúp các bên đạt được thỏa thuận hợp lý mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào quy định pháp luật cụ thể.

1.4.2.2 Bảo tồn giá trị văn hóa, tập quán và tạo nền tảng pháp lý vững chắc

Một giá trị quan trọng khác của việc xây dựng nguyên tắc pháp lý là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tập quán truyền thống trong quan hệ dân sự. Ở Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, nhiều giao dịch dân sự được thực hiện dựa trên các tập quán lâu đời, như thỏa thuận bằng lời nói hay các giao dịch tín chấp dựa trên sự tin tưởng. Việc xây dựng nguyên tắc pháp lý cần tôn trọng và kế thừa những giá trị này để không làm xáo trộn đời sống xã hội và đảm bảo các quy định pháp lý nhận được sự chấp thuận cao từ cộng đồng. Chẳng hạn, các giao dịch mượn đất tạm thời cho mục đích canh tác hay giao dịch cố đất theo tập quán giữa các hộ gia đình thường không có giấy tờ. Nếu nguyên tắc pháp lý thừa nhận và tôn trọng tập quán này, việc giải quyết tranh chấp sẽ trở nên hợp lý hơn và không gây mâu thuẫn với truyền thống địa phương.

Bên cạnh đó, các nguyên tắc pháp lý đóng vai trò nền tảng, là tiền đề cho việc hình thành các quy phạm pháp luật chính thức. Khi tập hợp và hệ thống hóa các nguyên tắc dựa trên thực tiễn và tập quán, nhà nước có thể xây dựng các quy định pháp luật phù hợp, vừa bảo đảm tính pháp lý vừa gắn kết với thực tế xã hội. Điều này không chỉ giúp nâng cao tính thực tiễn của pháp luật mà còn tạo cơ sở để hoàn thiện hệ thống pháp luật, tránh tình trạng quy định cứng nhắc, xa rời đời sống.

1.4.2.3 Thúc đẩy sự minh bạch, ổn định và phát triển bền vững

Một giá trị nổi bật khác của việc xây dựng nguyên tắc pháp lý là tăng cường tính minh bạch và đảm bảo sự phát triển bền vững của quan hệ dân sự. Trong bối cảnh các giao dịch dân sự ngày càng phức tạp, đặc biệt tại các khu vực chưa có khung pháp luật rõ ràng, sự minh bạch là yếu tố cần thiết để các bên hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Các nguyên tắc pháp lý đảm bảo tính công khai trong giao dịch, từ đó giảm thiểu rủi ro xảy ra xung đột hoặc lạm dụng. Khi phát sinh tranh chấp, Tòa án có cơ sở pháp lý hoặc án lệ rõ ràng để giải quyết vụ việc đúng đắn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

Tóm lại, trước khi xây dựng bộ khung pháp lý hoàn thiện điều chỉnh một quan hệ xã hội phát sinh và tồn tại trong thực tiễn, việc xây dựng những nguyên tắc pháp lý để điều chỉnh nó là bước đi đầu tiên mang lại những giá trị thiết yếu như lấp đầy khoảng trống pháp lý, bảo tồn giá trị văn hóa, tập quán, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các nguyên tắc này không chỉ giúp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh mà còn tạo tiền đề để hoàn thiện khung pháp luật chính thức, góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật hợp lý, công bằng và hiệu quả.

1.4.3 Các tiêu chí xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất vùng nông thôn Việt Nam

1.4.3.1 Tôn trọng, áp dụng và kế thừa các giá trị tập quán tốt đẹp

Là một trong những loại quy phạm xã hội xuất hiện từ buổi bình minh của loài người, tập quán có sức sống kì diệu và đóng vai trò không thể thay thế để điều chỉnh hành vi các thành viên trong cộng đồng nơi nó tồn tại. Trong lịch sử, khi các cộng đồng người hình thành, phát triển, dù có "tính tương cận" - gần gũi về đạo đức và tính người, thì "tập tương viễn" - tập quán lại thường không giống nhau. Tập quán có thể tồn tại theo nhiều cách: truyền miệng qua các thế hệ, hành vi chuẩn mực trong xã hội, được viết, vẽ lên đá, lên giấy v.v. Kể cả khi xã hội loài người có nhà nước, cùng với đó là pháp luật - một loại quy phạm do nhà nước đặt ra, dùng sức mạnh cưỡng chế để bảo đảm thực hiện - thì tập quán vẫn là loại quy phạm xã hội luôn hiện diện.

Tập quán là một thuật ngữ có nhiều cách tiếp cận và nhiều cách hiểu. Tiếp cận từ góc độ ngôn ngữ phổ thông, tập quán là "thói quen hình thành đã lâu trong đời sống, được mọi người tuân theo"[47], là "thói quen đã được mọi người tuân thủ tại một địa phương trong một hoàn cảnh bắt buộc phải chấp nhận lề thói ấy như một phần luật pháp của địa phương"[48]. Thuật ngữ tập quán khi sử dụng độc lập, tách khỏi cụm từ phong tục tập quán thường là do nó được nhấn mạnh đến tính quy phạm, tức là những quy tắc phổ biến mang tính truyền thống được chấp nhận hoặc dự kiến trong một cộng đồng, một nghề nghiệp, trong lĩnh vực của đời sống. Chẳng hạn, việc tảo mộ vào dịp cuối năm hoặc đầu năm là phong tục; những việc mà nếu không làm sẽ bị dư luận lên án, sẽ phải chịu chế tài của cộng đồng thì gọi là tập quán (đối với các dân tộc ít người, loại quy phạm này thường được gọi là luật tục).

Theo cách tiếp cận này, tập quán có thể có những tên gọi khác nhau tùy thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Tập quán là tên gọi chung cho những loại quy phạm xã hội mang tính thói quen và có tính bắt buộc trong một phạm vi đối tượng và địa bàn nhất định. Nếu loại quy phạm này tồn tại trong các dân tộc thiểu số thì nó thường được gọi là luật tục. Loại quy phạm này tồn tại trong các vùng miền gắn với địa bàn nông thôn cấp làng, xã và được văn bản hóa trên cơ sở sự đồng tình, thừa nhận của nhân dân thì thường gọi

[47] Nguyễn Như Ý (chủ biên), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1996, tr.1014.

[48] Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 1997, tr.742.

là hương ước, lệ làng[49]. Tiếp cận từ góc độ pháp lý, khoản 1 Điều 5 của BLDS năm 2015 định nghĩa: "*Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự*".

Tập quán cố đất ở nông thôn Việt Nam đã hình thành từ lâu đời và phản ánh sâu sắc mối quan hệ gắn bó giữa con người với đất đai. Những tập quán này không chỉ là phương tiện để duy trì sinh kế mà còn là biểu hiện của văn hóa, đạo đức, và giá trị cộng đồng. Pháp luật cần được thiết kế sao cho không phá vỡ các giá trị và quan hệ cộng đồng vốn đã ổn định trong các tập quán cố đất. Việc áp đặt các quy định pháp lý cứng nhắc, không phù hợp với bối cảnh thực tiễn có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa pháp luật và văn hóa giao dịch dân sự về đất đai ở địa phương, gây khó khăn trong việc thực thi. Thay vào đó, hệ thống pháp luật nên tìm cách kết hợp một cách linh hoạt giữa các quy định hiện đại và tập quán truyền thống để đảm bảo sự hài hòa và khả năng chấp nhận từ cộng đồng địa phương. Nói cách khác, việc xây dựng các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất cần phải ghi nhận và tôn trọng những giá trị truyền thống này như một phần không thể tách rời của đời sống pháp luật, miễn là chúng không xung đột với các nguyên tắc cơ bản về công bằng và đạo đức xã hội.

Tuy nhiên, trong xã hội thượng tôn pháp luật và yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, không phải tập quán nào cũng có thể được áp dụng để điều chỉnh, giải quyết các mối quan hệ xã hội hiện đại. Giao dịch cố đất ở nông thôn Việt Nam cũng là một quan hệ xã hội nội sinh, không nằm ngoài nguyên tắc này. Theo đó, các tập quán cần phải tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật hiện hành, không trái với các quy định trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Khi áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp về giao dịch cố đất, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nó không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, cũng như không vi phạm các chuẩn mực pháp lý và đạo đức xã hội. Các tiêu chí đánh giá là thước đo quan trọng để xác định khả năng áp dụng tập quán; đối với giao dịch cố đất nói riêng, thước đo quan trọng đó có thể bao gồm nhưng yếu tố pháp lý, xã hội và thực tiễn sau đây:

a) Tính phù hợp của tập quán

Việc áp dụng tập quán phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Theo đó, nguyên tắc cơ bản của pháp luật là nền tảng của hệ thống pháp luật. Nói cách khác, nguyên tắc cơ bản của pháp luật chính là cơ sở cho việc xây dựng, thực hiện pháp luật nói chung và áp dụng pháp luật nói riêng. Áp dụng tập quán trong quản lý xã hội của Nhà nước là áp dụng pháp luật, vì vậy, việc áp dụng tập quán phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, cụ thể như sau:

[49] Hoàng Thị Kim Quế, Ngô Huy Cương, Tập quán pháp ở Việt Nam hiện nay, Văn hóa pháp luật những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.21-215.

Một là, việc áp dụng tập quán phải bảo đảm cho các cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử. Các quy tắc tập quán không bảo đảm điều kiện này thì sẽ không được phép áp dụng. Chẳng hạn, tập quán của một số dân tộc theo chế độ mẫu hệ như người Ê Đê ở Đắk Lắk chỉ cho người con gái hưởng thừa kế do cha mẹ để lại; hoặc tập quán cấm kết hôn giữa những người cùng họ, tập quán thách cưới của nhiều dân tộc thiểu số… sẽ không được thừa nhận áp dụng vì những tập quán này không đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các chủ thể, thậm chí gây cản trở đến việc thực hiện các quyền tự do của cá nhân.

Hai là, việc áp dụng tập quán không được vi phạm điều cấm của luật. Như đã biết, tập quán là loại quy phạm đặc thù gắn với các cộng đồng nhất định, hướng tới lợi ích riêng của cộng đồng, duy trì trật tự của cộng đồng. Trong khi đó pháp luật là loại quy phạm mang tính phổ quát chung cho toàn xã hội, nhằm mang lại lợi ích quốc gia, duy trì trật tự chung. Do vậy, việc áp dụng tập quán phải trên cơ sở pháp luật, không được vi phạm điều cấm của luật. Nói cách khác, lợi ích chung, trật tự chung phải được ưu tiên hơn so với lợi ích riêng của các nhóm xã hội.

Ba là, việc áp dụng tập quán không được trái với các chuẩn mực đạo đức xã hội. Khi nghiên cứu về đạo đức, một tác giả nhận định: đạo đức là lẽ phải ở đời, là nguyên lý tự nhiên của cuộc sống. Chính vì vậy, có thể nói, mọi quan hệ giữa con người với nhau đều phải được diễn ra trên nền tảng đạo đức. Quan hệ xã hội chỉ được khuyến khích, củng cố khi phù hợp với những chuẩn mực đạo đức xã hội, trái lại nó sẽ chịu sự phản đối, sự tẩy chay của dư luận xã hội. Do vậy, điều chỉnh quan hệ xã hội bằng các công cụ khác phải thuận chiều với sự điều chỉnh bằng đạo đức. Các chuẩn mực đạo đức tiến bộ, tốt đẹp của dân tộc là nhân tố quan trọng đảm bảo cho đời sống xã hội có trật tự, phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Tuy nhiên, cần lưu ý, các chuẩn mực đạo đức cũng mang tính lịch sử, một quan niệm, quy tắc đạo đức nào đó có thể là chuẩn mực ứng xử trong thời đại này nhưng sang thời đại khác có thể không còn giá trị. Bởi vậy, các chuẩn mực đạo đức cần tuân theo chỉ bao gồm những chuẩn mực đạo đức đang thịnh hành trong xã hội đương đại.

Bốn là, việc áp dụng tập quán không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Tập quán tồn tại trên thực tế rất đa dạng. Một tập quán cụ thể có thể có lợi cho cá nhân, cộng đồng, nhóm xã hội này nhưng lại không có lợi cho cá nhân, cộng đồng, nhóm xã hội khác. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng cũng như quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể trong xã hội thì việc áp dụng tập quán phải bảo đảm nguyên tắc không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích của người khác.

b) Tính quy phạm của tập quán

Trong môi trường tố tụng Việt Nam hiện đại, Tòa án không được từ chối thụ lý vụ việc với lý do quan hệ tranh chấp chưa có điều luật để áp dụng. Đây là nguyên tắc tố tụng tiến bộ, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật quốc gia và xu hướng chung của pháp

luật quốc tế, được thừa nhận và áp dụng ở nước ta kể từ khi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo đó, khi không có pháp luật thành văn để áp dụng, Tòa án không được từ chối thụ lý và thứ tự ưu tiên liền kề sau đó phải là "tập quán". Khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng. Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định tại Điều 5 của BLDS năm 2015. Do vậy, đòi hỏi tất yếu đối với tập quán được viện dẫn phải có tính quy phạm, thể hiện ở các yếu tố cơ bản sau đây:

Trước hết, tập quán phải có nguồn gốc rõ ràng, tức là, phải xác định được tập quán đó thuộc vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc thuộc lĩnh vực nào của đời sống. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây không chỉ là căn cứ để lựa chọn tập quán áp dụng (theo phạm vi điều chỉnh), mà còn là giải pháp để giải quyết những tình huống xung đột trong áp dụng tập quán. Chẳng hạn, khoản 2 Điều 29 BLDS năm 2015 quy định: "Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn". Như vậy, dựa vào nguyên tắc này, các chủ thể có thẩm quyền sẽ xác định được tập quán cần áp dụng và giải quyết được vấn đề xung đột trong áp dụng tập quán.

Bên cạnh đó, để thỏa mãn tính quy phạm, tập quán phải có nội dung rõ ràng. Một thói quen tồn tại trên thực tế chỉ được thừa nhận trở thành nguồn của pháp luật khi đảm bảo tính quy phạm. Nói cách khác, nội dung của tập quán phải chứa đựng các quy tắc xử sự cụ thể để các chủ thể liên quan có thể hiểu được, thực hiện được; hoặc nếu họ không phải là người thực hiện thì họ cũng có thể đánh giá được tính phù hợp hay không phù hợp tập quán của những hành vi của người khác. Dựa vào nội dung tập quán, các bên trong quan hệ có thể nhận biết được các quyền và nghĩa vụ của mình để thực hiện. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp thì dựa vào nội dung tập quán, chủ thể có thẩm quyền giải quyết vụ việc cũng dễ dàng xác định được tập quán đó có trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hay không; có vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội hay không; có liên quan đến vụ việc cần giải quyết hay không; v.v. Tức là, xác định được tập quán đó có phù hợp để lựa chọn áp dụng khi giải quyết vụ việc đó hay không. Nếu tập quán đó phù hợp và được lựa chọn áp dụng thì chủ thể có thẩm quyền cũng dễ dàng xác định được một cách chính xác quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Ngoài ra, sự ổn định và phổ biến cũng là yếu tố biểu hiện của tính quy phạm của tập quán. Để được coi là có tính quy phạm, tập quán phải được thực hiện một cách ổn định và phổ biến trong một cộng đồng trong một khoảng thời gian dài. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng tập quán có sự thừa nhận rộng rãi và được mọi người trong cộng đồng chấp nhận là quy tắc hành xử chuẩn mực. Tính ổn định của tập quán thể hiện

qua việc nó không thay đổi thường xuyên, đồng thời nó cũng phải có sự thực hành nhất quán trong cộng đồng.

c) Tính chuẩn mực của tập quán

Tập quán được áp dụng phải là những tập quán được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong cộng đồng dân cư, lĩnh vực đời sống nhất định. Điều này đảm bảo cho các chủ thể có thể nhận biết và tuân theo quy tắc tập quán đó trong điều chỉnh các quan hệ của mình. Việc thừa nhận có thể chỉ đòi hỏi ở phạm vi là một cộng đồng dân tộc thường là một bản, làng, buôn, sóc. Việc thừa nhận thể hiện trên thực tế là nhiều người trong bản, làng, buôn, sóc biết đến và áp dụng, do các già làng, người có uy tín trong cộng đồng cung cấp thông tin hoặc xác nhận sự tồn tại của tập quán đó; hoặc trong một ngành nghề nhất định như trong hoạt động nghề nghiệp của các thương nhân, các quy tắc này được các thương nhân thừa nhận và áp dụng khi thiết lập quan hệ với nhau. Đối với tập quán quốc tế thì đòi hỏi phải được các chủ thể của luật quốc tế thừa nhận. Thực chất đây là việc xác định hiệu lực về không gian của tập quán.

Ngoài ra, tập quán được áp dụng phải tồn tại vào thời điểm áp dụng. Nếu một tập quán nào đó mặc dù đã từng tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội nhưng ở thời điểm hiện tại nó không còn được sử dụng rộng rãi nữa thì không được thừa nhận áp dụng. Như vậy, khi áp dụng tập quán cũng cần phải xác định hiệu lực về thời gian của tập quán. Việc xác định hiệu lực về thời gian đặt ra vấn đề cần giải quyết trên thực tế, đó là, có nhiều trường hợp thời điểm phát sinh quan hệ và thời điểm có tranh chấp xảy ra khá xa nhau. Vậy nếu tập quán tồn tại và được thừa nhận áp dụng rộng rãi ở thời điểm phát sinh quan hệ nhưng khi xảy ra tranh chấp, tập quán đó không còn tồn tại hoặc không còn được thừa nhận áp dụng rộng rãi nữa thì có áp dụng tập quán đó hay không? Trong trường hợp do có sự biến đổi của nội dung tập quán nên việc áp dụng tập quán tại thời điểm quan hệ phát sinh gây bất lợi hơn cho một bên so với áp dụng tập quán ở thời điểm phát sinh tranh chấp thì nên áp dụng tập quán ở thời điểm nào? Để giải quyết vấn đề này, đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động áp dụng tập quán thì tập quán được lựa chọn áp dụng phải là tập quán tại thời điểm phát sinh quan hệ, kể cả trong trường hợp tại thời điểm phát sinh tranh chấp tập quán đó không còn tồn tại hay không còn được áp dụng phổ biến. Nguyên tắc lựa chọn này cũng phù hợp và thống nhất với nguyên tắc chung trong xác định hiệu lực về thời gian của văn bản quy phạm pháp luật.

Tập quán hình thành và tồn tại gắn với các điều kiện kinh tế - xã hội nhất định, khi các điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi có thể khiến một số tập quán cũ trở nên lỗi thời không còn phù hợp để áp dụng. Do vậy, tập quán được áp dụng chỉ có thể là những tập quán tiến bộ, thể hiện bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng nguyên tắc này đã gặp phải những vướng mắc, bởi chưa có quy định thế nào thì được coi là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Nguyên tắc chung là những tập quán "tốt đẹp" thì được áp dụng. Tuy nhiên, tính chất "tốt đẹp" lại là một giá trị trừu tượng, có thể được hiểu ở nhiều góc độ khác nhau, phụ thuộc vào quan niệm của từng cá nhân,

cộng đồng, tầng lớp xã hội. Vì vậy, trong thực tế, rất khó xác định tập quán nào là tốt đẹp có thể áp dụng; tập quán nào không tốt đẹp cần được loại bỏ. Hơn nữa, Việt Nam là một nước đa dân tộc, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng nên trên thực tế, có những trường hợp có sự xung đột giữa tập quán của dân tộc này với dân tộc khác. Một tập quán có thể là bản sắc của dân tộc này nhưng lại bị coi là không phù hợp với dân tộc khác. Do đó, trong trường hợp tồn tại các tập quán khác nhau của các bên trong quan hệ thì các chủ thể có thẩm quyền cũng khó lựa chọn áp dụng tập quán nào để giải quyết.

Tóm lại, tôn trọng và kế thừa các giá trị tập quán truyền thống không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà còn cần thúc đẩy việc thích nghi và phát huy những giá trị này trong bối cảnh hiện đại. Điều này đòi hỏi việc điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn theo hướng phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ gìn những yếu tố văn hóa tích cực như tính cộng đồng, tinh thần tương trợ và sự gắn kết giữa các thành viên trong xã hội. Qua đó, pháp luật không chỉ điều chỉnh các mối quan hệ đất đai mà còn góp phần bảo tồn bản sắc truyền thống.

1.4.3.2 Tôn trọng quyền tự do định đoạt, tự nguyện thỏa thuận

Quyền tự do định đoạt và tự nguyện thỏa thuận là một nguyên tắc cơ bản trong pháp luật dân sự, đặc biệt quan trọng trong các giao dịch đất đai, bao gồm giao dịch cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam. Nguyên tắc này đòi hỏi pháp luật phải đảm bảo quyền của các bên tham gia giao dịch trong việc tự do quyết định các điều khoản, miễn là không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất cần đảm bảo tôn trọng quyền tự do định đoạt, tự nguyện thỏa thuận của các bên tham gia giao dịch. Nội dung này được thể hiện qua các khía cạnh cụ thể sau đây:

Một là, quyền tự do định đoạt phản ánh sự tôn trọng đối với quyền sở hữu, sử dụng, và quản lý tài sản của mỗi cá nhân hoặc tổ chức. Trong giao dịch cố đất, các bên cần được phép quyết định các nội dung như thời hạn cố đất, giá trị tài sản, và điều kiện chuộc lại mà không bị ép buộc hay hạn chế bởi các quy định cứng nhắc. Pháp luật cần tạo điều kiện để các bên tự do thương lượng, phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tế, nhằm đảm bảo giao dịch diễn ra một cách công bằng và hợp lý.

Hai là, nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận đảm bảo rằng không bên nào bị ép buộc hoặc lạm dụng trong quá trình giao dịch. Trong thực tiễn nông thôn, nơi các mối quan hệ cộng đồng thường chi phối, việc ghi nhận nguyên tắc này giúp hạn chế tình trạng áp đặt từ các bên mạnh hơn, đồng thời tăng cường tính hợp pháp và tính bền vững của giao dịch. Pháp luật cần đảm bảo rằng sự tự nguyện này không chỉ được thể hiện qua lời nói hay văn bản mà còn được thực hiện trong thực tế, đặc biệt đối với giao dịch cố đất trong thực tiễn thường được xác lập có một bên là người yếu thế (người nghèo, người đang cần vốn, nông dân, v.v.). Do đó, việc tôn trọng quyền tự do định đoạt và tự nguyện thỏa thuận giúp bảo đảm sự linh hoạt trong giao dịch cố đất. Tuy nhiên, pháp luật cũng cần lưu ý đến việc hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch một cách hợp

pháp, đặc biệt khi trình độ pháp lý của họ còn hạn chế. Sự hỗ trợ này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin pháp lý, tư vấn, hoặc hòa giải khi có mâu thuẫn.

Ba là, sự hạn chế hợp lý nhàm đảm bảo lợi ích công cộng. Theo đó, dù tôn trọng quyền tự do định đoạt và tự nguyện thỏa thuận, pháp luật cũng cần đặt ra những giới hạn để bảo vệ lợi ích công cộng và quyền lợi chính đáng của các bên liên quan. Chẳng hạn, các giao dịch cố đất được thực hiện phải đúng đối tượng, đúng hình thức, không được vi phạm các quy định pháp luật về QSDĐ, gây tổn hại đến tài nguyên đất đai hoặc ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Đồng thời, cần có cơ chế kiểm soát để đảm bảo rằng các thỏa thuận không có nội dung bất công, chẳng hạn như việc đặt ra lãi suất hoặc điều kiện chuộc đất quá cao, dẫn đến tình trạng mất đất kéo dài của người cố đất.

Bốn là, tôn trọng quyền tự do định đoạt và tự nguyện thỏa thuận góp phần xây dựng niềm tin giữa các bên tham gia giao dịch. Khi các bên được quyền tự quyết định và cam kết tuân thủ thỏa thuận, các giao dịch sẽ diễn ra minh bạch hơn, giảm thiểu tranh chấp. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cần yêu cầu các giao dịch được thực hiện dưới hình thức rõ ràng (như văn bản có công chứng hoặc chứng thực) để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp.

Tóm lại, xây dựng nguyên tắc pháp lý đảm bảo tôn trọng quyền tự do định đoạt và tự nguyện thỏa thuận là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong các giao dịch cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam. Pháp luật không chỉ cần tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên mà còn phải tạo ra một khung pháp lý linh hoạt, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Điều này không chỉ giúp củng cố niềm tin vào pháp luật mà còn góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

1.4.3.3 Đảm bảo minh bạch, công khai, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

Tiêu chí đảm bảo minh bạch, công khai và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành là một trong những yếu tố nền tảng để xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh các giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam. Các nguyên tắc pháp lý công khai, minh bạch không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên mà còn góp phần duy trì sự ổn định xã hội và phát triển bền vững. Song, một nguyên tắc pháp lý định hình tư duy pháp lý mới phải phù hợp, không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, không được mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định sẵn có trong hệ thống pháp luật hiện hành. Do đó, tiêu chí này thể hiện qua các khía cạnh cụ thể:

Một là, tính minh bạch và công khai đối với việc đề xuất xây dựng nguyên tắc pháp lý là những yêu cầu quan trọng để đảm bảo rằng các giao dịch cố đất được thực hiện một cách rõ ràng, không mập mờ về nội dung hoặc quyền và nghĩa vụ của các bên. Các giao dịch cần được lập thành văn bản với nội dung cụ thể như diện tích đất, giá trị cố đất, thời hạn cố đất và các điều kiện chuộc lại, v.v. Việc thiếu minh bạch trong thông tin thường là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, đặc biệt ở nông thôn, nơi trình độ hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Ở các vùng nông thôn, tính cộng đồng thường

đóng vai trò quan trọng. Do đó, việc thông báo hoặc công khai giao dịch dân sự liên quan đến đất đai không chỉ tạo sự đồng thuận mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro khi phát sinh tranh chấp. Pháp luật có thể yêu cầu các giao dịch này được đăng ký tại cơ quan quản lý đất đai hoặc được xác nhận bởi chính quyền địa phương.

Hai là, nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất phải đảm bảo tính phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Đây là một nguyên tắc cốt lõi là mọi giao dịch cố đất phải tuân thủ các quy định trong hệ thống pháp luật, đặc biệt là các quy định về đất đai, dân sự và tố tụng dân sự. Luật Đất đai của Việt Nam quy định QSDĐ là một loại tài sản đặc biệt, không chỉ giới hạn bởi các quyền mà còn gắn liền với nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên đất. Do đó, các giao dịch cố đất phải phù hợp với quy định về QSDĐ và đặt trong mối quan hệ về bản chất của QSDĐ trong lưu thông dân sự ở Việt Nam; không được vi phạm các điều kiện về quy hoạch, mục đích sử dụng hoặc chuyển nhượng QSDĐ. Bên cạnh đó, giao dịch cố đất là một giao dịch dân sự, phải đảm bảo tính tự nguyện, hợp pháp, và không vi phạm đạo đức xã hội. Điều này bao gồm cả việc lập hợp đồng bằng văn bản và có thể cần công chứng, chứng thực theo quy định. Cuối cùng, sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành cũng không tách rời khỏi tính đồng bộ với chính sách cơ bản của nhà nước. Theo đó, pháp luật cần thiết lập các quy định cụ thể để hạn chế các rủi ro tiềm ẩn, như việc giao dịch cố đất vi phạm mục đích sử dụng đất hoặc dẫn đến tình trạng *mất đất (mất QSDĐ)* của người dân yếu thế.

1.4.3.4 Thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định nguồn lực đất đai ở nông thôn

Ở một khía cạnh khác, đất đai là nguồn lực quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn Việt Nam. Việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định nguồn lực đất đai không chỉ đảm bảo hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, duy trì sinh kế, và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng nông thôn. Do đó, pháp luật liên quan đến đất đai, mà trước hết trong luận văn này tác giả đề cấp đến việc xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh một lĩnh vực nhỏ ở khía cạnh giao dịch về QSDĐ, cần phải đảm bảo mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững nguồn lực đất đai ở nông thôn.

Việc điều chỉnh giao dịch cố đất cần khuyến khích người nhận cố đất sử dụng đất đúng mục đích và khai thác tối đa giá trị kinh tế mà đất mang lại. Điều này đòi hỏi pháp luật phải đặt ra các cơ chế giám sát và khuyến khích việc sử dụng đất nông nghiệp cho sản xuất thay vì bỏ hoang hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép.

Đồng thời, tích tụ đất nông nghiệp là một xu hướng tất yếu trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp ở Việt Nam, nhưng cần được thực hiện một cách thận trọng để tránh làm mất cân bằng QSDĐ, gây bất ổn xã hội hoặc ảnh hưởng đến môi trường. Giao dịch cố đất, nếu được điều chỉnh đúng đắn, có thể trở thành một công cụ quan trọng hỗ trợ tích tụ đất, đồng thời duy trì quyền lợi của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững nguồn lực đất đai ở nông thôn.

Bên cạnh đó, giảm thiểu tranh chấp liên quan đến đất đai hay minh bạch hóa, hòa giải và giải quyết xung đột pháp lý có liên quan đến giao dịch cố đất trên cơ sở quy định rõ ràng của pháp luật cũng là mục tiêu pháp lý hướng đến. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và ổn định nguồn lực đất đai ở nông thôn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Từ Hiến pháp năm 1980, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai chính thức được ghi nhận. Chính sách, pháp luật về đất đai của Việt Nam không ngừng được đổi mới, hoàn thiện để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tư duy về phát huy tiềm năng nguồn lực đất đai thông qua giao dịch QSDĐ trong dân sự và thương mại đã được thể hiện rõ khi Nhà nước sửa đổi pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nếu như Luật Đất đai năm 1987 chỉ cho phép người sử dụng dất có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, thành quả lao động từ đất mà không có các quyền về định đoạt thì Luật Đất đai năm 1993 đã quy định cho người sử dụng đất có 05 quyền về chuyển giao QSDĐ có tính chất định đoạt và các quyền lợi trên đất cũng được phát triển hơn trước; đến Luật Đất đai năm 2003, người sử dụng đất đã có 09 quyền chuyển giao QSDĐ có tính chất định đoạt; Luật Đất đai năm 2013 quy định cho người sử dụng đất có 08 quyền chuyển giao QSDĐ có tính chất định đoạt (bỏ quyền về bảo lãnh bằng QSDĐ).

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030) tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có định hướng: "Phát triển thị trường, đẩy mạnh thương mại hóa QSDĐ, tăng cường đăng ký QSDĐ và áp dụng định giá đất theo thị trường bảo đảm công khai, minh bạch". Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục khẳng định quan điểm: "QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; QSDĐ, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ". Có thể thấy, để phát triển thị trường thì cần có nhiều hàng hóa, trong đó QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh pháp luật hiện hành, bao gồm cả quy định mới của Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất tiếp tục bị "bó buộc" trong 08 quyền. Hay nói cách khác, có 08 loại giao dịch về QSDĐ được thực hiện hợp pháp, gồm: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, giao dịch cố đất. Trong đó, chỉ có 01 trong số 09 biện pháp bảo đảm quy định trong BLDS năm 2015 có thể được thực hiện bằng QSDĐ, đó là thế chấp tài sản.

Trên thực tế, giao dịch cố đất là một giao dịch dân sự mà quyền, nghĩa vụ của các bên được điều chỉnh theo tập quán, Bên cố đất giao QSDĐ của mình cho Bên nhận cố đất; đổi lại, Bên nhận cố đất phải giao cho Bên cố đất một khoản tiền (hoặc kim khí quý, đá quý, v.v.) và được quyền khai thác, sử dụng đất, hưởng hoa lợi, lợi tức từ QSDĐ trong một thời hạn thỏa thuận. Hết thời hạn này, bên cố đất được quyền trả lại tiền (hoặc kim khí quý, đá quý, v.v.) cho bên nhận cố đất để chuộc lại QSDĐ.

Pháp luật hiện hành của Việt Nam không có văn bản pháp luật nào ghi nhận và điều chỉnh trong khi bản thân loại giao dịch này vẫn tồn tại phổ biến, như một tập quán vốn có của người nông dân Việt Nam. Ở góc độ luật chung, BLDS năm 2015 công nhận và cho phép áp dụng tập quán. Tuy nhiên, sự khuyết thiếu quy định về cố đất trong một thời gian dài, kể từ khi Luật Đất đai đầu tiên năm 1987, sau đó là BLDS đầu tiên của

Việt Nam năm 1995 cho đến nay đã hình thành nhiều quan điểm khác nhau, trong đó có quan điểm cho rằng đây là loại giao dịch dân sự bị cấm thực hiện. Tác giả nhận thấy rằng, vẫn còn những rào cản pháp lý nhất định để QSDĐ có thể thực sự phát huy giá trị thương mại, nếu người sử dụng đất vẫn bị giới hạn bởi các quyền năng được Luật Đất đai liệt kê cụ thể. Tham khảo quy định của pháp luật các nước, pháp luật của Việt Nam thời kỳ trước và những quy tắc xử sự của tập quán đã điều chỉnh giao dịch cố đất, có cơ sở lý luận để xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh loại giao dịch này tại Việt Nam.

Chương 2
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT, ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH GIAO DỊCH CỐ ĐẤT THEO TẬP QUÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

2.1 Thực trạng pháp luật liên quan đến giao dịch cố đất hiện nay

2.1.1 Thực trạng quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch cố đất

2.1.1.1 Quy định về các quyền của người sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 26 của Luật Đất đai năm 2024, các đối tượng là người sử dụng đất theo quy định của Luật này có 08 quyền chung cơ bản sau đây:

(1) Được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

(2) Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất sử dụng hợp pháp.

(3) Hưởng lợi ích khi Nhà nước đầu tư bảo vệ, cải tạo và phát triển đất nông nghiệp.

(4) Được hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, phục hồi đất nông nghiệp.

(5) Được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

(6) Được quyền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(7) Được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

(8) Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm QSDĐ hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Trên thực tế, nội hàm của các quyền được gọi là "quyền chung" của người sử dụng đất nêu trên hầu hết đều thể hiện trong mối quan hệ với Nhà nước, chủ thể của quản lý hành chính về đất đai đồng thời là đại diện của chủ sở hữu toàn dân. Quyền "hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất" là một quyền lợi vật chất của người sử dụng đất đối với mảnh đất mà mình được trao quyền sử dụng. Nhìn chung, 08 quyền cơ bản nêu trên của người sử dụng đất đều không mang tính chất chuyển dịch tài sản.

Bên cạnh các quyền chung, Luật Đất đai năm 2024 kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2013 về các quyền của người sử dụng đất được thực hiện giao dịch về QSDĐ. Quyền giao dịch về QSDĐ là việc người sử dụng đất thực hiện các quyền về tài sản của mình đối với QSDĐ, bằng cách đưa QSDĐ vào các giao dịch dân sự. Theo quy định tại Điều 27 của Luật Đất đai năm 2024, giao dịch QSDĐ thực hiện bởi các hình thức gồm: (1) chuyển đổi; (2) chuyển nhượng; (3) cho thuê; (4) cho thuê lại; (5) thừa kế; (6) tặng cho; (7) thế chấp; (8) góp vốn bằng QSDĐ. Theo đó, đối với các giao dịch cho thuê, cho

thuê lại, thế chấp thì QSDĐ chỉ chuyển dịch "tạm thời", người sử dụng đất không mất đi QSDĐ của mình. Đối với các giao dịch còn lại[50], QSDĐ khi đưa vào giao dịch sẽ được chuyển giao từ người này sang người khác.

2.1.1.2 Quy định về cầm cố tài sản là quyền sử dụng đất

Trong bối cảnh của pháp luật thực định, đất đai và QSDĐ đều được quy định là tài sản. Theo đó, đất đai là một loại tài sản thuộc nhóm bất động sản, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 107 của BLDS năm 2015; còn QSDĐ là một loại tài sản thuộc nhóm các quyền tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 115 của BLDS năm 2015. Trong khi QSDĐ không được quy định rõ trong BLDS với tư cách là một tài sản thuộc nhóm bất động sản như đất đai, nhưng đất đai lại không phải là đối tượng xuất hiện trong các giao dịch dân sự hay thương mại. Thay vào đó, QSDĐ lại là một tài sản, hàng hóa đặc biệt xuất hiện trong lưu thông với tư cách là bất động sản, được quy định rõ trong Luật Kinh doanh bất động sản.

Thực tế, "cố đất" cũng như những thuật ngữ giao dịch khác đối với đất từng được xuất hiện trong xã hội như "mua bán đất", " thuê đất" hay "mướn đất", v.v. xét về tên gọi đều có đối tượng giao dịch là đất đai. Tuy nhiên, khi được luật hóa đều dựa vào bản chất của giao dịch để quy về những tên gọi có tính chuẩn mực pháp lý là "chuyển nhượng QSDĐ", "cho thuê hoặc cho thuê lại QSDĐ", v.v. Vấn đề là, quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch đó dường như vẫn được giữ nguyên theo lề thói riêng sẵn có, quy định của pháp luật lúc này chỉ mang tính chất thừa nhận chứ không có sáng tạo thêm quyền, nghĩa vụ gì cho các bên giao dịch ngoài những nghĩa vụ hành chính và tài chính bắt buộc đối với Nhà nước.

Tương tự trong mối liên hệ giữa 02 thuật ngữ "cố đất" và "cầm cố QSDĐ", xét về bản chất pháp lý, như đã phân tích trong phần lý luận của nghiên cứu, cho thấy đây là tên gọi của cùng một loại giao dịch. Nếu đặt trong hệ quy chiếu pháp luật dân sự hiện hành của Việt Nam, giao dịch "cố" mang bản chất của giao dịch "cầm cố", là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 292 của BLDS năm 2015. Nếu đặt trong hệ quy chiếu pháp luật về đất đai, dưới chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và các quy định hiện hành của Việt Nam thì thuật ngữ "đất" trong giao dịch dân sự có bản chất pháp lý là nói đến "QSDĐ" với tư cách một tài sản và hàng hóa đặt biệt được phép giao dịch. Nói cách khác, thuật ngữ "cố đất" đặt trong bối cảnh các quy định pháp luật hiện hành, có cơ sở để gọi là "cầm cố QSDĐ".

Mặc dù vậy, thực trạng quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam không đề cập đến cả 02 tên gọi này. Nói cách khác, pháp luật hiện hành không có quy định về giao dịch "cố đất" hay "cầm cố QSDĐ". Thay vào đó, các giao dịch dưới tên gọi "cố đất" và "cầm cố QSDĐ" là vấn đề của thực tiễn, được nhắc đến trong quá

[50] Riêng đối với giao dịch góp vốn bằng QSDĐ mà không thành lập pháp nhân mới thì không có tính chất chuyển giao tài sản.

trình Tòa án giải quyết tranh chấp và tranh luận, đề xuất trong các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý hiện nay. Điều này rõ ràng phản ánh thực trạng "khuyết thiếu" quy phạm để điều chỉnh trong luật thành văn đối với một loại giao dịch vốn đã và đang tồn tại trong thực tiễn xã hội.

Lý giải cho thực trạng này, nghiên cứu chưa tìm thấy một đáp án thuyết phục, kể cả trong các bản án, quyết định của Tòa án và các đề xuất trong khoa học pháp lý. Theo đó, các bản án, quyết định của Tòa án (sẽ được phân tích cụ thể ở phần thực trạng áp dụng pháp luật) cho rằng sự "khuyết thiếu" quy phạm nên được hiểu là pháp luật dân sự và pháp luật đất đai không cho phép cầm cố QSDĐ. Trong khi đó, đa số các nghiên cứu pháp lý về vấn đề này giải thích rằng sự "khuyết thiếu" quy phạm điều chỉnh một quan hệ xã hội đang tồn tại chính là thiếu sót của luật thành văn[51].

Trong quá trình rà soát hệ thống pháp luật, có ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi cần nghiên cứu, bổ sung cơ chế pháp lý về cầm cố tài sản là QSDĐ để đảm bảo sự thống nhất trong áp dụng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng, tăng cường khả năng và cơ hội tiếp cận nguồn vốn của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất[52]. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 được ban hành cũng chỉ ghi nhận người sử dụng đất có 08 quyền giao dịch cụ thể. Trong đó, chỉ 01 trong số 09 biện pháp bảo đảm quy định trong BLDS năm 2015 được thực hiện bằng QSDĐ, đó là thế chấp tài sản.

2.1.1.3 Quy định về cầm cố tài sản khác không phải quyền sử dụng đất

Cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Theo quy định tại Điều 309 của BLDS năm 2015:

"Cầm cố tài sản là việc bên cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nói cách khác, cầm cố tài sản là sự thỏa thuận của các bên trong giao dịch dân sự về việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để giao cho bên kia nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ".

Do đó, cầm cố tài sản có các đặc điểm của một biện pháp bảo đảm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật dân sự nhưng có những đặc trưng riêng cơ bản.

Thứ nhất, tài sản cầm cố phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố. Theo Điều 309 định nghĩa về cầm cố tài sản và Điều 295 quy định về tài sản bảo đảm của BLDS năm 2015 thì trong giao dịch cầm cố tài sản, tài sản cầm cố phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố. Ngoại lệ, giao dịch cầm cố vẫn có thể phát sinh hiệu lực trong trường hợp tài sản cầm cố không thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố, đó là trường hợp bên cầm cố đại

[51] Huỳnh Thị Kim Lan, Cao Thị Mỹ Duyên, Bàn về cầm cố tài sản là QSDĐ và nhà ở, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, HCMCOUJS- Kỷ yếu, 17 (2), tr.74.

52 Báo cáo số 93/BC-BTP ngày 28/5/2021 của Bộ Tư pháp về việc chỉnh lí Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tình hình tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Phụ lục XIII, tr. 24.

diện cho một cá nhân, pháp nhân khác hoặc bên cầm cố dùng tài sản của người được giám hộ để thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ. Song, quy định tài sản cầm cố phải thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố là bản chất cốt lõi.

Thứ hai, tài sản cầm cố phải chuyển giao cho bên nhận cầm cố. Đây là một trong những điểm phân biệt cầm cố với thế chấp tài sản. Thật vậy, nếu thế chấp tài sản, bên thế chấp không giao tài sản mà chỉ chuyển giao giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu cho bên nhận thế chấp, do đó, bên thế chấp vẫn là bên giữ tài sản thế chấp. Trong khi, đối với biện pháp cầm cố, bên cầm cố phải chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố và bên nhận cầm cố là bên giữ tài sản cầm cố. Yếu tố chuyển giao tài sản là đặc trưng giúp phân biệt biện pháp cầm cố với các biện pháp bảo đảm khác.

BLDS Việt Nam hiện hành không ghi nhận trực tiếp tài sản nào là đối tượng của cầm cố, tài sản nào không thuộc đối tượng của cầm cố tài sản nhưng tại khoản 2 Điều 310 của Bộ luật này có quy định gián tiếp: "*Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký*". Điều này được hiểu theo suy lý rằng tài sản cầm cố có thể là động sản hoặc bất động sản, đây là quy định mới bổ sụng so với BLDS năm 2005. Tuy nhiên, như đã phân tích ở phần trên, trong các văn bản quy định liên quan đến bất động sản hiện hành như Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 lại không ghi nhận hình thức giao dịch cầm cố đối với QSDĐ và nhà ở.

Về kỹ thuật lập pháp, quy định của BLDS Việt Nam hiện hành về cầm cố tài sản chỉ đề cập chung đối với tất cả các loại tài sản, không phân biệt hữu hình hay vô hình, cũng không phân loại giữa cầm cố động sản và cầm cố bất động sản. Trong một chừng mực nào đó, kỹ thuật này cho thấy sự bất tiện và khó hiểu của luật thành văn, thậm chí đã và đang gây hiểu lầm, tranh cãi[53]. Bởi vì, thực tế một số loại tài sản, chẳng hạn như QSDĐ, lại không được thừa nhận là đối tượng của cầm cố tài sản trong thực tiễn. Mặt khác, nếu thừa nhận tất cả các loại tài sản hợp pháp đều được phép cầm cố, thì các động sản hữu hình, động sản vô hình và bất động sản, quyền tài sản, v.v. cùng được áp dụng một quy chế pháp lý chung về cầm cố cũng là vấn đề bất cập.

2.1.1.4 Những quy định khác có liên quan đến quản lý nhà nước và giải quyết tranh chấp trong thực tiễn xét xử tại Tòa án về giao dịch cố đất

a) Về điều cấm của luật

Điều cấm của luật trong pháp luật Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự xã hội và bảo vệ lợi ích công cộng. Khái niệm "điều cấm của luật" đã được định nghĩa rõ tại khoản 1 Điều 123 của BLDS năm 2015. Theo đó, *"điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định"*.

[53] PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy, Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ - nhìn từ góc độ lý luận, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 18 (370), tháng 9/2018.

Nói cách khác, điều cấm của luật là những quy định pháp lý nghiêm cấm các hành vi hoặc giao dịch gây tổn hại đến trật tự công, quyền lợi chính đáng của các cá nhân, tổ chức hoặc vi phạm các nguyên tắc đạo đức xã hội. Theo Điều 123 BLDS 2015, mọi giao dịch dân sự có nội dung vi phạm điều cấm của luật đều bị tuyên vô hiệu, điều này cho thấy tính bắt buộc tuyệt đối của các quy định này. Chẳng hạn, trong lĩnh vực đất đai, Luật Đất đai 2024 nghiêm cấm các hành vi như lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích hoặc chuyển nhượng QSDĐ trái quy định.

Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, một số điều cấm của luật vẫn gặp những bất cập nhất định. Các quy định về điều cấm đôi khi chưa rõ ràng, gây khó khăn trong việc áp dụng hoặc giải quyết các tranh chấp cụ thể. Chẳng hạn, các giao dịch cố đất ở nông thôn tuy không bị cấm nhưng cũng không được pháp luật công nhận chính thức, dẫn đến tình trạng lúng túng khi xử lý các tranh chấp phát sinh.

b) Tòa án không được từ chối thụ lý khi chưa có điều luật để áp dụng

Trong bối cảnh pháp luật thực định của Việt Nam, một nguyên tắc tố tụng quan trọng là Tòa án không được từ chối thụ lý vụ việc dân sự với lý do không có điều luật để áp dụng. Theo đó, khoản 2 Điều 4 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

"*2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.*

Vụ việc dân sự chưa có điều luật để áp dụng là vụ việc dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhưng tại thời điểm vụ việc dân sự đó phát sinh và cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu Tòa án giải quyết chưa có điều luật để áp dụng".

Nói cách khác, trong mọi trường hợp, Tòa án phải thụ lý và giải quyết các tranh chấp khi có đơn khởi kiện hợp lệ, bất kể việc đó có được quy định cụ thể trong luật hay không. Đây là điểm mới đã được cân nhắc đưa vào nội dung sửa đổi của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nguyên tắc cơ bản này được ấn định nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý của các bên, tránh tình trạng bỏ sót, không xử lý các tranh chấp phát sinh từ thực tiễn. Điều này không chỉ là trách nhiệm pháp lý của Tòa án mà còn là một yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.

Vấn đề có tính nguyên tắc tiếp theo là căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng được quy định cụ thể tại Điều 45 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo đó, Điều luật này quy định rõ việc áp dụng các căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng thực hiện theo thứ tự sau: (1) Áp dụng tập quán; (2) Áp dụng tương tự pháp luật; (3) Áp dụng nguyên tắc cơ bản của pháp luật, án lệ, lẽ công bằng.

** Áp dụng tập quán*

Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tập quán không được trái với các

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của BLDS. Khi yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền viện dẫn tập quán để yêu cầu Tòa án xem xét áp dụng. Tòa án có trách nhiệm xác định giá trị áp dụng của tập quán bảo đảm đúng quy định tại Điều 5 của BLDS. Trường hợp các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự.

** Áp dụng tương tự pháp luật*

Tòa án áp dụng tương tự pháp luật để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng theo quy định tại Điều 5 của BLDS và khoản 1 Điều này. Khi áp dụng tương tự pháp luật, Tòa án phải xác định rõ tính chất pháp lý của vụ việc dân sự, xác định rõ ràng trong hệ thống pháp luật hiện hành không có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh quan hệ đó và xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự.

** Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng*

Khi không thể áp dụng tập quán, tương tự pháp luật thì Tòa án áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để giải quyết vụ việc dân sự.

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là những nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của BLDS. cụ thể là: (1) Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản; (2) Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng; (3) Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực; (4) Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; (5) Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử. Án lệ được Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong giải quyết vụ việc dân sự khi đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố.

Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó.

Tuy nhiên, đối với việc giải quyết vụ việc dân sự theo nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng, cần lưu ý, BLTTDS 2015 không xác định thứ tự ưu tiên áp dụng. Như vậy, theo nghiên cứu thấy rằng khi không thể áp dụng tập quán, tương tự pháp luật thì về nguyên tắc, Tòa án có thể áp dụng một hoặc đồng thời áp dụng nhiều căn cứ trong các căn cứ trên để giải quyết vụ việc dân sự.

2.1.2 Thực trạng áp dụng pháp luật liên quan đến giao dịch cố đất

2.1.2.1 Trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai

Thực tiễn xã hội cho thấy, các chủ thể sử dụng đất, mà chủ yếu là đất ruộng ở vùng nông thôn, áp dụng biện pháp cố đất để bảo đảm nghĩa vụ là rất phổ biến và xuất hiện trong xã hội từ rất sớm. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội và pháp lý hiện nay, không phải ngẫu nhiên mà QSDĐ lại tiếp tục được người dân lựa chọn làm đối tượng của quan hệ cầm cố. Lý do bên có quyền và nghĩa vụ lựa chọn QSDĐ làm tài sản cầm cố xuất phát từ thực tế QSDĐ ngày càng có giá trị rất lớn trên thị trường, khi nhận cầm cố bên có quyền có thể được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ QSDĐ cầm cố nếu có thỏa thuận. Bên cố đất (hay bên cầm cố QSDĐ) mong muốn có được một khoản tiền, vàng để giải quyết nhu cầu tạm thời nhưng vẫn giữ lại QSDĐ trong một thời hạn có thể chuộc, vì khả năng họ có thể chuộc, vì đất đai là tài sản có ý nghĩa truyền đời qua các thế hệ. Do đó, việc thực hiện giao dịch cố đất (hay cầm cố QSDĐ) vốn đã và đang mang lại lợi ích nhất định cho các bên.

Trong quản lý hành chính về đất đai, Nhà nước dường như không có sự can thiệp nào đối với việc người dân tham gia vào giao dịch cố đất, cho dù đó là một giao dịch có tính chuyển giao tài sản. Nói cách khác, trên danh nghĩa QSDĐ vẫn đứng tên của bên cố đất, nhưng trên thực tế thì mảnh đất đó lại được chuyển giao cho bên nhận cố đất quản lý, trực tiếp canh tác. Mặc dù pháp luật đất đai các thời kỳ đều có quy định về một trong các hành vi bị nghiêm cấm, đó là: "*Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về QSDĐ mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền*"[54]. Thế nhưng, giao dịch cố đất dù không đăng ký, không báo cáo thì có chăng chỉ phải chịu những rủi ro pháp lý nhất định mà không có chế tài hành chính nào can thiệp. Thực trạng áp dụng pháp luật như vậy, một phần cũng bởi vì cơ quan quản lý đất đai không có đủ cơ chế pháp lý để ngăn cản, kiểm soát hay xử phạt đối với hành vi giao dịch này.

Trong mối quan hệ với Nhà nước về nghĩa vụ tài chính, hoặc các trường hợp thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì bên cố đất cũng luôn là người phải đứng ra giải quyết. Vì thực chất họ mới là chủ thể có tư cách của người được trao QSDĐ trong mối quan hệ với đại diện chủ sở hữu toàn dân và cũng là cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Về thuế, phí thì cũng không giống như thời kỳ mà giao dịch cố đất được thừa nhận, nghĩa vụ nộp thuế được chuyển giao cùng với việc giao đất cố cho bên nhận cố

[54] Khoản 6 Điều 12 của Luật Đất đai năm 2013, tương ứng khoản 8 Điều 11 của Luật Đất đai năm 2024.

đất; còn nay, giao dịch cố đất chưa được thừa nhận thì người đứng tên QSDĐ vẫn là người có nghĩa vụ tài chính và phải nộp thuế, phí cho Nhà nước.

2.1.2.2 Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất

Trong thực tiễn xét xử, các Tòa án đều sẽ giải quyết theo hướng tuyên bố giao dịch cố đất (hay cầm cố QSDĐ) bị vô hiệu và xử lý hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu. Thật vậy, thu thập bản án từ năm 2017 đến nay, tác giả đã tìm kiếm bằng từ khóa "cố đất" có 146 bản án đã công bố, từ khóa "cầm cố QSDĐ" có 203 bản án công bố. Trong đó, các giao dịch này đều bị tuyên bố vô hiệu.

Ví dụ 4: Bản án số 18/2021/DSST ngày 13/5/2021 của TAND huyện A, tỉnh K xét xử vụ án tranh chấp về giao dịch cầm cố QSDĐ nhận định:

"Theo quy định của pháp luật đất đai thì không quy định cho người sử dụng đất có quyền cầm cố QSDĐ, cụ thể, Điều 167, Điều 179 và Điều 188 của Luật đất đai quy định: 'Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ; quyền thế chấp, bảo lãnh, giao dịch cố đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất', nên anh Trần Thanh Ph và anh Nguyễn Văn Nh, chị Phan Thị Bé T thực hiện giao dịch cầm cố QSDĐ ***là vi phạm điều cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật đất đai***[55]*. Do đó, HĐXX xác định giao dịch cầm cố QSDĐ giữa anh Trần Thanh Ph và anh Nguyễn Văn Nh, chị Phan Thị Bé T ngày 30-8-2019 vô hiệu theo quy định tại Điều 123 của BLDS. Đồng thời, giao dịch vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập, các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận*".

Bản án nêu trên khẳng định giao dịch cố đất là vi phạm điều cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật đất đai năm 2013 (tương ứng hiện nay quy định tại khoản 7 Điều 11 của Luật Đất đai năm 2024). Tuy nhiên, quy định được viện dẫn vốn có nội dung minh định một trong các hành vi bị nghiêm cấm, đó là: "*không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất*". Trong khi, các quyền của người sử dụng đất gồm các quyền chung, quyền cụ thể và quyền thực hiện giao dịch đã được quy định (như phân tích tại phần 2.1.1 của luận văn này). Luật Đất đai chưa có quy định về giao dịch cố đất hay cầm cố QSDĐ thì phải thực hiện như thế nào, đảm bảo điều kiện gì. Do đó, nhận định của bản án cho rằng người dân thực hiện giao dịch cố đất là vi phạm điều cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 thì quả thật có phần khiêng cưỡng, nếu không nói là chưa phù hợp với pháp luật.

Ví dụ 5: Bản án số: 84/2019/DS-ST ngày 26/9/2019 của TAND huyện C, tỉnh A xét xử vụ án về tranh chấp hợp đồng cầm cố QSDĐ, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có nhận định: "*phần đất của ông C bà B cố của ông B1 bà N ngày 07 tháng 03 năm*

[55] Theo Luật Đất đai năm 2013, tương ứng quy định tại khoản 7 Điều 11 của Luật Đất đai năm 2024.

2017 diện tích 4000 m2 (đo đạc thực tế là 3.817 m^2) với số tiền 100.000.000 đồng, thời hạn cố là 6 mùa vụ kể từ vụ hè thu năm 2017. Xét thấy, các bên thỏa thuận cầm cố đất ***là trái với quy định tại Điều 167 của Luật đất đai năm 2013 vì trong các quyền thì nhà nước hạn chế quyền cầm cố QSDĐ,*** *do đó giao dịch giữa các bên là vô hiệu. Căn cứ Điều 122, Điều 123, Điều 131 của BLDS năm 2015, nghĩ nên tuyên bố hợp đồng cầm cố đất ngày 07 tháng 03 năm 2017 giữa ông C, bà B đã nhận cố đất của ông B1 và bà N là vô hiệu [...]*".

Về nhận định này, quan điểm của tác giả cho rằng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 BLDS năm 2015,"*Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng*".

Điều 123 BLDS năm 2015 quy định "*Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu. Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng*".

Như vậy, dựa vào nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận nêu trên chỉ giới hạn ở phạm vi mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội nếu không vi phạm nguyên tắc này các cam kết và thỏa thuận sẽ có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng, đối với hợp đồng cầm cố QSDĐ cũng không nằm ngoài nguyên tắc này, khi hợp đồng cầm cố QSDĐ không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội thì hợp đồng có hiệu lực và chủ thể khác phải tôn trọng.

Bên cạnh đó, để coi hành vi xác lập, thực hiện giao dịch cố đất hay hợp đồng cầm cố QSDĐ là điều cấm của luật thì đòi hỏi quy định của luật phải thể hiện rõ "*không cho phép chủ thể thực hiện hành vi cầm cố QSDĐ*", nếu không quy định rõ thì không thể xem là vi phạm điều cấm của luật, và khi đối chiếu với các quy định của Luật Đất đai hiện hành hoàn toàn không có quy định nào cấm người sử dụng đất cầm cố QSDĐ, chính vì vậy không thể xác định hành vi xác lập, thực hiện hợp đồng cầm cố QSDĐ là vi phạm điều cấm của luật và cũng không thể nói rằng luật không có quy định việc cầm cố QSDĐ là đang nghiêm cấm thực hiện giao dịch cầm cố QSDĐ.

Ví dụ 6: Bản án số 222/2023/DS-PT ngày 04/12/2023 của TAND tỉnh Sóc Trăng đã xét xử vụ án về tranh chấp hợp đồng cầm cố QSDĐ, hợp đồng mua bán tài sản và hợp đồng thuê mướn QSDĐ giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn D, bị đơn ông Nguyễn Văn Út N1. Nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

"Nguyên vào ngày 26/4/2012 âm lịch ông Nguyễn Văn D có nhận cố phần đất của ông Nguyễn Văn Út N1 và bà Trần Thị S với diện tích là 04 công tầm cấy, số tiền cố đất

là 80.000.000 đồng, thời hạn cố đất là khi nào vợ chồng ông N1, bà S có khả năng chuộc thì ông D sẽ cho chuộc đất lại. Việc cầm cố có làm giấy tay và có chữ ký của vợ chồng ông Út N1, bà S cùng một số người làm chứng ký tên vào giấy cố đất.

Tuy nhiên, đất cố thì ông D không có nhận đất, cho vợ chồng ông Út N1 thuê đất lại làm ruộng, giá thuê mỗi năm một công là 200 ký lúa, tổng 04 công là 800 ký lúa, giá lúa tính theo thị trường. Số tiền cố đất 80.000.000 đồng thực chất là tiền mà vợ chồng ông Út N1, bà S mua phân, thuốc trừ sâu còn nợ, do vợ chồng ông Út N1 không có khả năng thanh toán nên mới cố đất rồi thuê đất lại làm ruộng".

Đây là một giao dịch cố đất điển hình theo dạng "bên nhận cố cho bên cố thuê lại chính phần đất đã cố" như đã trình bày tại mục 1.2.2.3 của luận văn này. Trên thực tế, bên nhận cố đất ở đây là ông Nguyễn Văn D, là đại lý mua bán phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, v.v. nên không có nhu cầu canh tác đất nông nghiệp. Ông D chỉ nhận cố đất để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của nông dân, nhưng thỏa thuận cho chính người nông dân đó thuê lại phần đất đã cố để thu một phần hoa lợi từ đất. Về phần ông Út N1 và bà S cũng thừa nhận do thiếu tiền mua phân bón của ông D nên ông, bà đã viết giấy cố 04 công đất ruộng của mình cho ông D; đồng thời nhận thuê lại để canh tác theo như thỏa thuận để có thu nhập trả nợ, khi nào có khả năng thì chuộc lại đất. Như vậy, lợi ích của hai bên khi tham gia giao dịch này là khá rõ ràng. Nay phát sinh tranh chấp là vì vợ chồng ông Út N1 và bà S không trả đủ tiền thuê đất nên ông D yêu cầu phải chuộc đất. Trong khi đó, ông Út N1 và bà S chưa có khả năng trả lại tiền cố đất nên đồng ý trả đủ tiền thuê và yêu cầu tiếp tục thực hiện việc cố đất vì giấy cố đất ghi rõ là cố không có thời hạn, khi nào có tiền thì chuộc.

Khi giải quyết giao dịch này, bản án nêu trên đã nhận định như sau:

Tại khoản 1 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 quy định "Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ theo quy định của Luật này". Theo đó người sử dụng đất không có quyền cầm cố QSDĐ theo quy định của pháp luật. Cho nên ,việc ông D và vợ chồng ông N1, bà S thỏa thuận cố đất với nhau là không phù hợp với quy định của pháp luật nên hợp đồng cầm cố QSDĐ giữa ông D và vợ chồng ông N1, bà S là vô hiệu ngay từ thời điểm xác lập ***do vi phạm điều cấm của pháp luật*** *theo quy định tại Điều 123 của BLDS năm 2015.*

Điều 131 của BLDS năm 2015 có quy định về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu: "Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập; Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận…". Có nghĩa là ông D phải trả đất cố lại cho vợ chồng ông N1 và vợ chồng ông N1 phải trả tiền cố đất lại cho ông D, tuy nhiên phần đất cố thì các bên thừa nhận hiện nay vẫn do vợ chồng ông N1 đang canh tác do mướn đất lại làm nên không đặt ra xem

xét việc buộc vợ chồng ông D hoàn trả lại đất cố mà chỉ buộc vợ chồng ông N1 trả lại tiền cố đất cho ông D là 80.000.000 đồng là có căn cứ.

Khác với bản án tại ví dụ 4 và ví dụ 5 nêu trên, bản án vừa nêu tại ví dụ 6 nhận định một cách thẳng thắn hơn rằng "người sử dụng đất không có quyền cầm cố QSDĐ". Lý do là khoản 1 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 (tương ứng hiện nay là khoản 1 điều 27 của Luật Đất đai năm 2024) không có liệt kê quyền cầm cố QSDĐ như là một trong các quyền mà người sử dụng đất được thực hiện. Đồng thời, đối chiếu với quy định của BLDS, giao dịch cố đất bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, quy định tại Điều 123 của Bộ luật này. Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu, bản án nhận định các bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận, vấn đề bồi thường thiệt hại do giao dịch vô hiệu không đặt ra bởi vì cả hai bên đều có lỗi dẫn đến hợp đồng bị vô hiệu.

Như vậy, mặc dù có những điểm tương đối khác nhau trong cách lập luận, các bản án đều có chung quan điểm áp dụng pháp luật về đất đai. Đó là, giao dịch cố đất (hay cầm cố QSDĐ) không thuộc nhóm các giao dịch mà người sử dụng đất được thực hiện vì không được liệt kê tại Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013 (tương ứng với Điều 27 của Luật Đất đai năm 2024). Từ đó, giao dịch cố đất bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật theo quy định tại Điều 123 của BLDS năm 2015.

Hầu hết các bản án không đề cập đến điều cấm của luật mà giao dịch cố đất vi phạm đến đó là điều cấm nào, quy định nào. Cá biệt một số trường hợp như Bản án số 18/2021/DSST ngày 13/5/2021 của TAND huyện A, tỉnh K nêu tại ví dụ 4 cho rằng, điều cấm mà giao dịch cố đất vi phạm đó là quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật đất đai năm 2013 (tương ứng khoản 7 Điều 11 của Luật Đất đai năm 2024). Theo đó, điều này nêu một trong các hành vi bị nghiêm cấm là người sử dụng đất "*không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất*".

Về hậu quả pháp lý của giao dịch cố đất bị vô hiệu theo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hiện nay, điển hình qua các ví dụ kể trên, đều thống nhất áp dụng quy định tại Điều 131 của BLDS năm 2015 để buộc các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Theo đó, bên cố đất trả lại tiền, vàng đã nhận mà không phải trả lãi; bên nhận cố đất trả lại toàn bộ diện tích đất đã nhận. Vấn đề về thời gian hoàn trả không được đề cập ngay trong các bản án nên có thể hiểu và áp dụng các quy định về thi hành án dân sự để thực hiện. Theo đó, pháp luật không đặt ra vấn đề phải hoàn trả sau khi đã thu hoạch xong hay phải giao ở bất cứ thời điểm nào án có hiệu lực. Khi đó, nếu vụ lúa chưa thu hoạch thì khi thu hoạch xong, hoa lợi thu được thuộc về ai là những vấn đề mà thực trạng áp dụng pháp luật còn chưa được đề cập đến

2.1.3 Những hạn chế, bất cập khi thực trạng pháp luật Việt Nam đang "lãng tránh" vấn đề cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam

Từ những quy định pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật có liên quan đến giao dịch cố đất như phân tích tại mục 2.1.1 và 2.1.2 nêu trên cho thấy, dường như pháp luật

Việt Nam hiện hành đang tìm cách "lãng tránh" đi vấn đề của giao dịch cố đất. Bởi lẽ, pháp luật không có quy định nào cấm các chủ thể thực hiện giao dịch cố đất (hay cầm cố QSDĐ) nên không thể quy kết đây là giao dịch vi phạm điều cấm của luật. Ở góc độ luật riêng, loại giao dịch này khi đưa vào hệ quy chiếu của pháp luật đất đai Việt Nam hiện hành với tư cách là một trong các giao dịch về QSDĐ, bản thân nó không có các vấn đề làm phương hại đến trật tự quản lý hành chính nhà nước về đất đai; vấn đề duy nhất có thể tồn tại mâu thuẫn chỉ là do tên gọi của loại giao dịch này chưa được liệt kê ngay trong Điều 27 của Luật Đất đai năm 2024. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy đây là một trong các giao dịch về đất đai (QSDĐ) theo tập quán ở nông thôn Việt Nam mà hiện nay pháp luật thành văn chưa có quy định điều chỉnh. Có thể nói, đây vừa là khoảng trống pháp luật, vừa là điểm nghẽn về mặt pháp lý dẫn đến những hạn chế, bất cập trong áp dụng và thi hành pháp luật, đặc biệt là khi giải quyết các tranh chấp. Cụ thể:

2.1.3.1 Về xây dựng và áp dụng pháp luật

Pháp luật Việt Nam chưa có những quy định cụ thể và đầy đủ về các giao dịch QSDĐ theo tập quán nói chung và giao dịch cố đất (hay cầm cố QSDĐ) nói riêng, dẫn đến tình trạng pháp lý không rõ ràng. Nhiều trường hợp, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, người dân thực hiện các giao dịch cố đất theo cách thức truyền thống mà không có hợp đồng, giấy tờ hợp pháp, hoặc không thông qua các thủ tục hành chính. Điều này không do lỗi của người dân mà do pháp luật chưa có khung pháp lý chính thức để điều chỉnh. Tuy nhiên, các nhà làm luật chưa dành sự chú ý đầy đủ đến giao dịch cố đất, vốn là sự thỏa thuận ngay tình theo tập quán và thực sự phổ biến ở các vùng nông thôn Việt Nam. Do đó, khi xảy ra tranh chấp, việc giải quyết gặp khó khăn, vì các giao dịch này không được pháp luật ghi nhận chính thức.

Thực tiễn áp dụng pháp luật tại Tòa án, các bản án cho rằng giao dịch cố đất vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật (không đề cập đến các lý do vô hiệu khác) là không phù hợp với lý luận chung của pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và pháp luật đất đai hiện hành của Việt Nam. Quy định của pháp luật về áp dụng tập quán chỉ mang tính chất thừa nhận, chưa có cơ chế bảo đảm việc áp dụng, nguy cơ bị sửa/hủy bản án khi áp dụng tập quán tạo áp lực khiến "*các Thẩm phán thấy rất khó khăn khi có yêu cầu liên quan đến tập quán phát sinh tại tòa*"[56]. Do đó, trên thực tế rất ít bản án chính thức áp dụng tập quán. Một phần vì pháp luật ngày nay đã hoàn thiện và bao quát hơn, điều chỉnh sâu rộng các quan hệ trong xã hội và ý thức pháp luật của người dân cũng được nâng cao; song, một phần là do các Thẩm phán có tâm lý e ngại áp dụng tập quán khi giải quyết các vụ việc dân sự. Điều này tạo ra sự mâu thuẫn giữa các quy định thành văn và các phương thức giao dịch truyền thống, khiến cho người dân khó có thể tìm được sự bảo vệ hợp pháp cho quyền lợi của mình khi thực hiện giao dịch cố đất theo tập quán.

[56] Nguyễn Tấn Hoàng Hải, Nguyễn Phương Ân, Hoàn thiện quy định về tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự, Tạp chí TAND điện tử, https://tapchitoaan.vn/hoan-thien-quy-dinh-ve-ap-dung-tap-quan-trong%C2%A0giai-quyet-vu-viec-dan-su10570.html [truy cập 01/12/2024].

Mặt khác, trong các giao dịch cố đất theo tập quán, thường có sự chênh lệch về quyền lực và vị thế giữa các bên tham gia, đặc biệt là giữa những người giàu và nghèo, giữa những người phân phối vật tư nông nghiệp và nông dân sản xuất quy mô nhỏ. Nếu pháp luật không điều chỉnh toàn diện và đầy đủ các giao dịch này, người yếu thế có thể bị thiệt thòi khi tham gia tố tụng tại Tòa án, dẫn đến sự bất công trong xã hội.

2.1.3.2 Về mặt xã hội và chính sách phát triển nông thôn

Về hậu quả xã hội, việc pháp luật không thừa nhận giao dịch cố đất xuất phát từ những bản án, quyết định tuyên giao dịch vô hiệu như trên, dường như đã là câu chuyện khá rõ ràng. Ở một chừng mực nhất định, nghiên cứu cho thấy người nông dân không hẳn đã "lách luật" để tránh những rào cản pháp lý tại Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 8 Điều 45 của Luật Đất đai năm 2024) mà do họ thực sự có nhu cầu về vốn. Đổi lại, bên nhận cố đất thực sự có nhu cầu tích tụ ruộng đất để canh tác lúa với quy mô lớn mà không đủ điều kiện nhận chuyển nhượng vì giá cao, vượt hạn mức, v.v. Việc pháp luật không thừa nhận loại giao dịch này đã dẫn đến những hệ quả xã hội nhất định, người ngay tình phải gánh chịu rủi ro pháp lý, còn người cố tình trục lợi từ hợp đồng thì lại không có chế tài dân sự nào của pháp luật. Các cơ quan báo chí và truyền thông cũng không có cách làm nào khác hơn là tuyên truyền để người dân không thực hiện các giao dịch về cố đất, cầm cố QSDĐ để tránh rủi ro pháp lý.[57]

Thực tế, ở nông thôn, người nông dân thường hiểu và áp dụng pháp luật dựa trên tập quán và thói quen, thay vì các quy định pháp lý chính thức. Sự thiếu đồng bộ này giữa pháp luật thành văn và thói quen giao dịch theo tập quán thực tế đã gây ra sự bất ổn trong việc thực thi các chính sách phát triển nông nghiệp, tạo ra sự khác biệt trong cách xử lý các vụ việc tranh chấp đất đai có giao dịch cố đất (tranh chấp đối với các phần đất đang được cố cho người khác, người đứng tên không trực tiếp sử dụng). Việc không công nhận các giao dịch cố đất theo tập quán thực tế đang là một phần rào cản đối với sự phát triển của thị trường đất đai ở nông thôn. Các chính sách hỗ trợ người dân cải thiện sản xuất, đầu tư và phát triển nông thôn gặp khó khăn khi các giao dịch cố đất không được pháp lý hóa và không có giá trị pháp lý chính thức để đối kháng với người thứ ba khi xảy ra tranh chấp về hợp đồng hoặc tranh chấp khác về QSDĐ.

Tóm lại, có thể thấy rõ những hạn chế và bất cập khi pháp luật Việt Nam không giải quyết đầy đủ vấn đề cố đất theo tập quán ở nông thôn có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, từ việc gia tăng tranh chấp đất đai, đến việc hạn chế quyền lợi của người dân và cản trở sự phát triển kinh tế xã hội. Để khắc phục tình trạng này, tác giả cho rằng pháp luật cần nhìn nhận thẳng thắn vấn đề cố đất là một giao dịch tồn tại lâu đời theo tập quán. Từ đó, cần có sự đổi mới trong chính sách pháp luật về đất đai, bao gồm việc

[57] Truyền hình Đồng Tháp, Pháp luật không thừa nhận cố đất (17/9/2020), https://www.youtube.com/watch?v=ypCakJCNIG4 [truy cập 20/10/2024].

công nhận và điều chỉnh các giao dịch đất đai theo tập quán trong khuôn khổ pháp lý chính thức, đồng thời tạo ra một hệ thống pháp lý rõ ràng, minh bạch và công bằng.

2.2 Kiến nghị áp dụng tập quán để giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất

2.2.1 Định hướng áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất

Áp dụng tập quán làm nguồn bổ trợ cho pháp luật là giải pháp quan trọng trong giai đoạn mà hệ thống pháp luật thành văn chưa thực sự hoàn thiện. Ngay cả trong một hệ thống pháp luật hoàn thiện, áp dụng tập quán cũng sẽ làm cho hệ thống pháp luật thêm toàn diện và khả thi. Bởi vì, trong nhà nước pháp quyền, pháp luật được đặt ở vị trí "thượng tôn" chứ không phải là "độc tôn" và vẫn phải sử dụng nhiều loại nguồn pháp luật khác trong đó có tập quán[58]. Tuy nhiên, để áp dụng tập quán điều chỉnh một quan hệ xã hội nói chung và trong giải quyết vụ, việc dân sự của TAND được hiệu quả, khoa học và bảo đảm pháp chế XHCN, cần dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, đồng thời, đảm bảo những quan điểm định hướng sau đây:

2.2.1.1 Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong áp dụng tập quán

Đảm bảo pháp chế XHCN là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Một trong những nội dung của nguyên tắc pháp chế XHCN là các cơ quan nhà nước phải thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, trong đó, Hiến pháp được đặt ở vị trí tối cao, mọi hành vi pháp lý không được trái Hiến pháp; pháp chế XHCN còn đòi hỏi pháp luật phải được hiểu và thực hiện một cách thống nhất trên phạm vi toàn quốc, tôn trọng tính đặc thù của địa phương nhưng các địa phương không được thực hiện những hoạt động mang tính biệt lệ, vô nguyên tắc. Khi áp dụng tập quán, nguyên tắc đảm bảo pháp chế XHCN đặt ra những yêu cầu cụ thể sau:

- Phải tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật: Quá trình áp dụng tập quán không được trái với những nguyên tắc cơ bản đã được nêu trong Hiến pháp. Trước hết, theo đúng quy định của Khoản 3 Điều 5 Hiến pháp 2013, "*các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình*". Như vậy rõ ràng, những tập quán được áp dụng ở đây bắt buộc phải đảm bảo nguyên tắc Hiến định là tập quán tốt đẹp chứ không phải mọi loại tập quán. Bên cạnh đó, tập quán tốt đẹp để được áp dụng điều chỉnh các quan hệ xã hội cụ thể và để làm cho quan hệ xã hội đó trở thành quan hệ pháp luật thì phải phù hợp với những nguyên tắc được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò là đạo luật gốc.

---

[58] Nguyễn Thị Tuyết Mai, *Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của TAND ở Việt Nam hiện nay*, Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014, tr. 121 – 122.

- Phải hiểu và áp dụng thống nhất những quy định của pháp luật khi áp dụng tập quán; hiểu thống nhất về tập quán. Chẳng hạn như, khi pháp luật cho phép áp dụng tập quán thì đương nhiên cơ quan có thẩm quyền sẽ được thực hiện quyền này. Nhưng đây cũng cần phải được hiểu là nghĩa vụ của cơ quan có thẩm quyền. Nếu không có pháp luật mà có tập quán không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật, ở vào các trường hợp được áp dụng tập quán thì không thể không áp dụng tập quán. Tập quán được viện dẫn phải là những tập quán có sự thống nhất về nội dung. Tức là, tập quán đó không phải là tất cả mọi người trong cộng đồng đều biết, nhưng nhất thiết phải là tập quán mà được những người biết về nó thống nhất về nội dung. Chủ thể có thẩm quyền khi áp dụng tập quán thì phải áp dụng những tập quán đã được xác định là tồn tại và phải áp dụng theo cách hiểu thống nhất của cộng đồng. Việc đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật còn thể hiện ở khía cạnh, trong trường hợp án lệ được coi là nguồn của pháp luật thì pháp luật Việt Nam sẽ có ba loại nguồn là văn bản quy phạm pháp luật, tập quán và án lệ, khi đó, áp dụng án lệ hay áp dụng tập quán phải không được mâu thuẫn, chồng chéo và đảm bảo thứ tự ưu tiên trên cơ sở quy định pháp luật.

2.2.1.2 Áp dụng tập quán về giao dịch cố đất nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ dân sự

Trong quan hệ pháp luật, các bên luôn được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Tuy nhiên, đối với những quan hệ xã hội trong giao lưu dân sự mà pháp luật chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh không đầy đủ, quyền, lợi ích hợp pháp có thể chưa xác định được, thì bản thân các bên cũng luôn có quyền, có nghĩa vụ, có lợi ích chính đáng.

Các tranh chấp dân sự suy cho cùng là tranh chấp về lợi ích, thông thường là lợi ích vật chất, cũng có thể có lợi ích tinh thần liên quan đến những giá trị nhân thân. Dù chưa có pháp luật điều chỉnh hay pháp luật chưa hoàn thiện, thì những nguyên tắc như bảo vệ giá trị đạo đức, trật tự công cộng, tính công bằng... vẫn luôn phải được tính đến. Do vậy, đối với hoạt động áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp dân sự, TAND phải quán triệt nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các bên, vì điều đó cũng chính là bảo vệ giá trị đạo đức, bảo vệ trật tự công cộng, tôn trọng tính công bằng trong các quan hệ xã hội.

2.2.1.3 Áp dụng tập quán về giao dịch cố đất hướng đến việc xây dựng án lệ và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Theo quan điểm của Đảng và trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong nhà nước pháp quyền, hệ thống pháp luật phải thực sự hoàn thiện. Do vậy, việc áp dụng tập quán ngoài mục đích bổ trợ cho pháp luật thì còn mang ý nghĩa là từ thực tiễn áp dụng, nhà nước sẽ lựa chọn những tập quán nào phù hợp với mục tiêu điều chỉnh các quan hệ xã hội của nhà nước để nâng nó lên thành pháp luật, làm cho hệ thống pháp luật trở nên hoàn thiện hơn. Đây vốn dĩ là cách làm truyền thống, ngay từ khi nhà nước mới được thành lập, giai cấp thống trị đã sử dụng phương pháp này để làm

hình thành nên pháp luật bên cạnh việc ban hành những quy định mới. Đối với Việt Nam, cũng đã có trường hợp nhà nước thừa nhận tập quán, sau một thời gian áp dụng đã nâng lên thành pháp luật. Điều này không chỉ xảy ra trong các kiểu nhà nước trước đây mà còn cả trong nhà nước kiểu mới - Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, chẳng hạn như tập quán về hụi, họ, biêu, phường, v.v.

Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam hiện hành, từ khi Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2015, đã thừa nhận và tạo nền tảng pháp lý cơ bản cho việc xây dựng và áp dụng án lệ trong hệ thống pháp luật. Với việc áp dụng án lệ, Việt Nam đã tiến một bước quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và gia tăng tính đồng bộ, nhất quán trong xét xử, đồng thời hỗ trợ việc giải quyết các tranh chấp pháp lý khi các quy định pháp luật còn thiếu hoặc chưa rõ ràng. Theo đó, quá trình hoàn thiện pháp luật từ việc áp dụng tập quán, xây dựng và ban hành án lệ cho đến luật hóa thành quy định trong luật thành văn đã trở thành một quá trình "tiến hóa tự nhiên" của hệ thống pháp lý. Nó phản ánh sự cần thiết điều chỉnh và hoàn thiện pháp luật để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đồng thời đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc giải quyết các quan hệ xã hội.

Do vậy, việc áp dụng tập quán về giao dịch cố đất hướng đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ làm hoàn thiện hệ thống pháp luật theo các hướng:

Một là, sẽ hoàn thiện hệ thống nguồn của pháp luật, làm cho hệ thống pháp luật có nguồn "mở", nguồn phong phú, đa dạng. Thực tế đã chứng minh, nguồn của pháp luật càng phong phú, đa dạng thì hệ thống pháp luật càng trở nên có tính toàn diện. Một hệ thống pháp luật có nguồn "đóng", tức là chỉ dựa vào duy nhất nguồn văn bản quy phạm pháp luật thì sẽ gây nhiều khó khăn trong việc áp dụng pháp luật do sự thiếu toàn diện của chính loại nguồn văn bản này.

Hai là¸ từ việc áp dụng tập quán về giao dịch cố đất trong xét xử để khẳng định tính đúng đắn, đảm bảo công bằng và công lý, các tòa án sẽ lựa chọn các bản án, quyết định có áp dụng tập quán vào giải quyết tranh chấp liên quan đến giao dịch cố đất phù hợp với các tiêu chí của Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 30/9/2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, đề xuất công bố làm án lệ để viện dẫn và áp dụng phù hợp với thực tiễn xã hội.

Ba là, từ việc áp dụng tập quán về giao dịch cố đất, xây dựng, công bố và áp dụng án lệ về giao dịch cố đất trong thực tiễn xét xử sẽ dần chứng minh tính phù hợp và tính phổ biến để đúc kết những quy tắc xử sự của tập quán lên thành văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung những quy phạm còn khuyết thiếu trong hệ thống văn bản quy phạm.

Với ý nghĩa quan trọng đó, việc áp dụng tập quán về giao dịch cố đất trong thực tiễn cần thực hiện nghiêm túc, có tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có căn cứ đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thành công cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

2.2.2 Nội dung áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất

2.2.2.1 Áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất

Trong giao dịch cố đất, điển hình qua các vụ án kể trên, các bên đã tự nguyện thực hiện giao dịch cố đất từ khi các bên tham gia thỏa thuận giao dịch cho đến khi thực hiện đều tự nguyện xuất phát từ tập quán sử dụng đất ở nông thôn Việt Nam hiện nay. Cầm cố đất *chưa được điều chỉnh* chứ không phải là *cấm*. Do đó, việc Tòa án cho rằng giao dịch trên vi phạm điều cấm của luật là chưa phù hợp, có tính khiên cưỡng.

Nghiên cứu cho thấy, nên chấp nhận giao dịch cố đất với những lý do sau:

Một là, thể hiện sự phát triển của pháp luật dân sự trong nước, khi BLDS năm 2015 không hạn chế đối tượng giao dịch cầm cố là động sản mà có thể là bất động sản. Mặt khác, quy định tại Điều 27 của Luật Đất đai năm 2024 không quy định theo hướng hạn chế người sử dụng đất "chỉ" có thể thực hiện 08 quyền, trong đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì "chỉ được thế chấp" mà không được thực hiện các giao dịch nào khác.

Hai là, phù hợp với xu hướng áp dụng tập quán làm nguồn bổ khuyết tạm thời cho luật thành văn, thông qua kiểm nghiệm trong thực tiễn điều chỉnh một quan hệ xã hội nhất định để hoàn thiện pháp luật. Thật vậy, theo dòng lịch sử lập pháp Việt Nam hiện đại, một số tập quán, truyền thống tiến bộ đã được "chuyển" thành hình thức văn bản quy phạm pháp luật để thuận tiện sử dụng[59].

Minh chứng rõ ràng nhất cho sự bổ khuyết luật thành văn từ tập quán giao dịch dân sự đó là hụi, họ, biêu, phường. Đây vốn là một giao dịch về tài sản theo tập quán tồn tại lâu đời. Trước đây, Bộ Dân luật Bắc kỳ năm 1931 và Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật năm 1936 đều có quy định điều chỉnh[60]. Đến năm 1992, TAND tối cao và VKSND tối cao cũng thống nhất hướng dẫn không được coi "nợ hụi" là giao dịch bất hợp pháp để từ chối, mà phải thụ lý như một loại tranh chấp về "vay tài sản"[61]. Thế nhưng, khi BLDS đầu tiên của Việt Nam được ban hành năm 1995 không có quy định. TAND tối cao sau đó đã ban hành Công văn số 16/1999/KHXX ngày 01/02/1999 hướng dẫn các Tòa án địa phương tạm thời chưa thụ lý để giải quyết các tranh chấp về hụi phát sinh từ việc chơi hụi được xác lập từ ngày 01/7/2006[62]. Mãi đến khi BLDS năm 2005 ra đời, quy định về hụi, họ, biêu, phường mới bổ sung quy định:

"*Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định*

---

[59] PGS. TS. GVCC Phan Trung Hiền, *Lý luận về Nhà nước và Pháp luật*, Quyển 1, NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2020, Tr. 62.

[60] Điều 1204 của Bộ Dân luật Bắc kỳ năm 1931 và Điều 1435 của Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật.

[61] Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 08/8/1992 của TAND tối cao và VKSND tối cao hướng dẫn việc giải quyết các tranh chấp về nợ hụi.

[62] Mục 2 Phần III của Công văn số 16/1999/KHXX ngày 01/2/1999 của TAND tối cao giải đáp một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng.

ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên" (Điều 419 của BLDS năm 2005).

Tiếp đó, Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ được ban hành đã quy định cụ thể về thể thức, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch này. Nội dung điều chỉnh của luật đều dựa trên nền tảng cơ sở là những quy tắc xử sự chung của tập quán. Đến nay, BLDS năm 2015 (Điều 471) và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 05/4/2019) vẫn tiếp tục kế thừa, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định trước đó và điều chỉnh có hiệu quả một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán của người dân.

Ba là, xét về bản chất QSDĐ trong bối cảnh pháp luật hiện hành, nếu "đất đai" thuộc sở hữu toàn dân thì "QSDĐ" là tài sản của cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận QSDĐ. Thực tế, QSDĐ là tài sản thuộc nhóm bất động sản, là "một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu"[63]. Do đó, khi đã là một tài sản hợp pháp, về nguyên tắc đều phải được phép đưa vào lưu thông dân sự thông qua các giao dịch. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, vấn đề tự do giao thương tài sản và hàng hóa cần được tôn trọng. Việc thiếu quy phạm điều chỉnh quan hệ xã hội là điều tồn tại hầu như trong mọi ngành luật nên khi chưa có quy phạm điều chỉnh giao dịch cố đất thì không thể hiểu theo hướng đây là điều cấm của luật.

Từ góc độ lịch sử, xã hội và lý thuyết về sự lựa chọn hợp lý mà nói, cố đất không phải là một tập quán giao dịch tự phát và cục bộ mà đã hình thành và duy trì trong suốt chiều dài lịch sử canh tác đất ruộng của nông dân Việc Nam. Ngày nay, giao dịch cố đất, tự bản thân nó vẫn phù hợp với xã hội Việt Nam hiện đại và không phải là những hành vi tiêu cực đáng phải bài trừ, ngăn cấm. Hệ quả xã hội như phân tích ở phần thực trạng là do quá trình áp dụng pháp luật không thừa nhận giao dịch cố đất, dẫn đến rủi ro pháp lý cho người dân. Trong khi đó, Nhà nước cũng không được lợi gì từ việc ngăn cấm này mà ngược lại, còn phải ứng phó với một thực tại xã hội khác ở nông thôn. Đó là, số lượng những người được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nay đã không còn là chủ đất thật sự rất lớn, minh chứng cho vấn đề này là thực tế đã có rất nhiều cá nhân đang canh tác hàng trăm, hàng ngàn hecta đất trồng lúa, đất nông nghiệp mà nhà nước không quản lý được[64]. Thay vì thừa nhận và có sự quản lý hành chính về giao dịch cố đất như một loại hình chuyển giao QSDĐ tạm thời, Nhà nước đã có thể theo dõi và kiểm soát được một cách khoa học hơn.

Thực tế, giao dịch cố đất chưa được ghi nhận trong luật thành văn, nhưng tập quán đã bao hàm những quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của các bên từ lâu đời, thậm chí đã từng được pháp luật thời kỳ phong kiến và các đạo luật

[63] Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

[64] Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022, *Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại vùng ĐBSCL*, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 170-181

thời kỳ thuộc Pháp điều chỉnh trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong phạm vi cả nước, mà tiêu biểu nhất là trong tập quán sử dụng đất ở vùng ĐBSCL. Do đó, trong trường hợp pháp luật thành văn chưa có quy định, Tòa án không thể tuyên vô hiệu giao dịch cố đất do vi phạm điều cấm của luật mà phải áp dụng tập quán theo quy định tại Điều 5 của BLDS năm 2015 để giải quyết. Theo đó, "*trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này*".

Từ những phân tích trên cho thấy, cố đất là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 của BLDS năm 2015 và cũng không có gì trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. Rõ ràng, việc áp dụng tập quán để giải quyết giao dịch cố đất đáp ứng được các tiêu chí về tính phù hợp, tính quy phạm và tính chuẩn mực đã phân tích tại mục 1.5 Chương 1 của luận văn này. Tác giả cho rằng, những vụ án tranh chấp về giao dịch cố đất, điển hình qua những ví dụ kể trên, có thể áp dụng những quy tắc xử sự của tập quán cố đất, quy định về cầm cố tài sản và các quy định khác có liên quan để giải quyết, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch mà không có gì vi phạm vào điều cấm hay trái với quy định của pháp luật.

2.2.2.2 Các quy tắc xử sự chung của tập quán cố đất cần được áp dụng

Về bản chất, khi vận dụng các quy tắc xử sự của tập quán để điều chỉnh và giải quyết tranh chấp, trước hết cần thống nhất nhận thức chung rằng tên gọi "cố đất" chỉ là từ ngữ địa phương, không phải nói về giao dịch đất đai mà là giao dịch về QSDĐ. Đây cũng là sự nhận thức chuyển hóa từ khi áp dụng sáng kiến về "QSDĐ" trong pháp luật đất đai của Việt Nam, như "mua bán đất" được chuyển hóa thành "chuyển nhượng QSDĐ", hay "cho thuê đất" được chuyển hóa thành "cho thuê QSDĐ", v.v. Ngược lại, ở góc độ vùng miền, tên gọi "cố đất" có thể là "cầm cố đất", "điển cố ruộng đất" hay "thục đất" nhưng về quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch không có sự thay đổi về bản chất. Đây cũng là vấn đề thống nhất nhận thức về tên gọi, như trước đây khi Nhà nước chuyển từ ngăn cấm sang thừa nhận tập quán giao dịch về hụi, họ, biêu, phường đều nhận thức chung trong văn bản pháp luật gọi là "họ".

Về định nghĩa "giao dịch cố đất", nghiên cứu đề xuất:

Giao dịch cố đất là một hình thức giao dịch bảo đảm theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận bên cố đất giao QSDĐ của mình cho bên nhận cố đất, bên nhận cố đất giao cho bên cố đất một khoản tiền (hoặc kim khí quý, đá quý, v.v.) và được quyền khai thác, sử dụng đất, hưởng hoa lợi trong một thời hạn. Hết thời hạn này, bên cố đất được quyền trả lại tiền (hoặc kim khí quý, đá quý, v.v.) cho bên nhận cố đất để chuộc lại QSDĐ.

Về quyền, nghĩa vụ của các bên: Do xuất phát là một tập quán giao dịch hình thành trong đời sống xã hội, từng được ghi nhận và điều chỉnh bởi pháp luật các thời kỳ phong

kiến và các Bộ Dân luật Bắc kỳ, Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật cũng như Dân luật giản yếu năm 1883 ở Nam kỳ, giao dịch cố đất ở nông thôn Việt Nam tự nó đã hình thành những quy tắc xử sự chung. Theo đó, nội dung các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia giao dịch đã được định rõ, cần được áp dụng để giải quyết tranh chấp giữa các bên hoặc với người thứ ba có liên quan. Cụ thể như sau:

- Hầu hết các hình thức và trường hợp cố đất, đối tượng là QSDĐ vẫn thuộc về bên cố đất, người nhận cố đất chỉ có quyền quản lý và canh tác trên đất. Ngoại lệ có trường hợp người nhận cố đất vẫn để lại đất cho người cố đất tiếp tục canh tác thì phải có thỏa thuận kèm theo (có thể là cho mượn, cho thuê lại, v.v.) và khi đó người cố đất phải chia sẻ hoa lợi hoặc phải trả bằng một số tiền lãi nhất định.

- Về quyền chuộc và thời hạn chuộc đất: Theo tập quán, bên cố đất có quyền chuộc lại đất trong một thời hạn được ấn định (thường từ 03 đến 05 năm). Nếu trong thỏa thuận không nêu rõ thời hạn, hoặc ghi thời hạn không xác định thì bất cứ khi nào người cố đất có khả năng thì có thể chuộc lại đất. Ngoài ra, trong hầu hết các thỏa thuận thường thấy trên thực tiễn đều ghi rõ khi đến hạn chuộc đất mà bên cố đất chưa chuộc thì bên nhận cố đất vẫn tiếp tục canh tác cho đến khi nào bên cố đất có điều kiện thì chuộc lại. Do đó, cần lưu ý đối với những trường hợp không ghi rõ điều này thì theo quy tắc xử sự chung vẫn phải áp dụng theo hướng thời hạn chuộc đất chỉ là thời hạn phát sinh quyền chuộc, không phải là thời hạn phát sinh nghĩa vụ buộc phải chuộc lại đất của bên cố đất.

- Về thời gian chuộc đất: Trong các văn tự cố đất được khảo cứu trước đây, sau này là các giấy tờ cố đất được viết tay giữa hai bên hầu như chỉ đề cấp đến thời hạn cố đất, chuộc đất mà không nói gì đến thời gian cụ thể để bàn giao lại phần đất cố. Thời hạn luôn được tính bằng năm nên điều này mặc nhiên được hiểu thời gian giao trả đất trùng với ngày, tháng cố đất khi đến hạn. Tuy nhiên, có một thói quen đã thành lệ, đó là việc giao trả đất không thực hiện khi chưa thu hoạch xong vụ mùa đang canh tác. Pháp luật phong kiến, tại Điều 384 của Bộ luật Hồng Đức, nhà làm luật cũng dự liệu rõ ràng thời kỳ chuộc đất hàng năm: "*Đối với ruộng mùa (gặt hái vào vụ tháng 10) phải chuộc vào ngày 15 tháng 3; đối với ruộng chiêm (gặt hái vào vụ tháng 5) thì kỳ hạn chuộc là 15 tháng 9*". Ngày nay, mùa vụ mỗi địa phương mỗi khác, nhưng để khỏi thua thiệt đến mùa màng của người đang nhận cố đất, thiết nghĩ tập quán này cần được áp dụng, khi thi hành việc chuộc đất đã cố phải thực hiện trước khi bắt đầu vụ sau để khỏi gây sự thiệt thòi cho người nhận cố đất đã cày cấy, xuống giống hoặc sắp được thu hoạch.

2.2.2.3 Các quy tắc xử sự chung của tập quán cố đất không được áp dụng

Như đã phân tích, không phải mọi tập quán hay mọi quy tắc xử sự trong một tập quán đều có thể được áp dụng để giải quyết tranh chấp. Thay vào đó, Tòa án cần đánh giá tập quán nào có thể áp dụng dựa trên những tiêu chí cụ thể, như đã phân tích tại Chương 1, phải đảm bảo tính phù hợp, tính quy phạm, tính chuẩn mực, v.v. Đồng thời, trong mỗi tập quán giao dịch đều sẵn có nhiều quy tắc xử sự và thói quen có tính tùy nghi xã hội. Do đó, để được Tòa án áp dụng giải quyết các tranh chấp dân sự, các quy

tắc xử sự chung, mà ở đây là quy tắc xử sự chung trong giao dịch cố đất theo tập quán cần đảm bảo những định hướng, yêu cầu đảm bảo pháp chế XHCN, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hướng tới việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thực tế, tập quán giao dịch cố đất vốn hình thành lâu đời, chịu ảnh hưởng nhiều bởi lịch sử, bối cảnh kinh tế - xã hội và pháp lý của từng thời kỳ nên chứa đựng hệ thống các quy tắc xử sự chung đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, qua khảo cứu, tác giả nhận thấy có những quy tắc, những nội dung thỏa thuận theo thói quen cũ nay đã không còn phù hợp, không thể được áp dụng khi giải quyết các tranh chấp có liên quan trong bối cảnh kinh tế - xã hội và pháp luật Việt Nam hiện hành. Cụ thể:

- Việc bên nhận cố đất đương nhiên trở thành chủ đất (tức người có QSDĐ) khi đã quá 30 năm kể từ ngày cố đất mà bên cố đất vẫn chưa chuộc lại đất.

Đây là quy tắc xử sự chung xử lý trường hợp khi thời hạn chuộc đất không nói rõ mà trong giấy tờ cố đất chỉ ghi là khi người cố đất có tiền thì chuộc lại. Thực tiễn ghi nhận dạng thỏa thuận "không giới hạn thời hạn chuộc đất" theo kiểu này rất phổ biến và quy tắc định ra là thời hạn chuộc đất trong giao dịch cố đất không quá 30 năm. Trong sắc dụ niên hiệu Minh Mạng thứ 20, nhà vua đã ban hành quy định để điều chỉnh về thời hạn chuộc đất như sau: "*Nếu điển cố điền thổ mà trong khế ước không ghi rõ niên hạn thì quá hạn 30 năm, bên nhận điển cố sẽ được làm chủ sở hữu vĩnh viễn đối với các ruộng đất đã cố*". Từ đó, chiếu dụ được thi hành dần đã thành lệ trong dân sự.

Tuy nhiên, việc công nhận QSDĐ hợp pháp cho bên nhận cố đất trong trường hợp như trên là điều bất khả thi và trái với nguyên tắc chung của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai hiện hành. Do đó, quy tắc này không thể được áp dụng.

- Vệ nộp thuế, phí và nghĩa vụ tài chính đối với đất đã cố thuộc về bên nhận cố đất kể từ thời điểm nhận đất, được chuyển giao QSDĐ để canh tác.

Đây là cũng là quy tắc xử sự chung của tập quán cố đất trong các thời kỳ lịch sử trước đây, khi mà giao dịch cố đất (điển cố) được pháp luật ghi nhận. Theo đó, mặc dù không được ghi rõ trong văn bản, giấy tờ cố đất thì mặc nhiên, khi thực hiện bên nhận cố đất phải có nghĩa vụ nộp thuế, phí và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác về đất đối với Nhà nước. Lệ này vốn xuất phát từ việc chính quyền phong kiến, thực dân kiểu cũ đánh thuế đất nông nghiệp trực tiếp dựa trên người hưởng hoa lợi, không dựa trên chủ đất (người có QSDĐ) nên thực tế cho thấy là phù hợp với xã hội nông thôn trước đây.

Tuy nhiên, quy tắc xử sự này đã không còn phù hợp với xã hội Việt Nam hiện đại và trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật hiện hành. Cụ thể, khoản 3 Điều 31 của Luật Đất đai năm 2024 quy định rõ một trong các nghĩa vụ chung của người sử dụng đất là: *"Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật"*. Đồng thời, hành vi của người có QSDĐ mà *"không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa*

vụ tài chính đối với Nhà nước" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai, theo quy định tại khoản 9 Điều 11 của Luật này.

Đối chiếu với quyền, nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch cố đất theo tập quán, QSDĐ vẫn thuộc về bên cố đất, chỉ chuyển giao cho người nhận cố đất quản lý và canh tác tạm thời trong một thời hạn nhất định cho đến khi chuộc lại. Do đó, trong chế độ sở hữu đất đai của nước ta, mối quan hệ giữa chủ sở hữu đất đai là Nhà nước và người được giao QSDĐ thì nghĩa vụ tài chính về đất đai nói chung phải là nghĩa vụ do người có QSDĐ thực hiện, tức là bên cố đất phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác về đất đối với Nhà nước.

Tóm lại, từ những vướng mắc và lập luận nêu trên, tác giả kiến nghị TAND tối cao sớm có văn bản hướng dẫn thi hành để thống nhất trong thực tiễn xét xử theo hướng không tuyên vô hiệu mà cần phải công nhận hiệu lực của giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở vùng nông thôn; áp dụng và không được áp dụng những quy tắc xử sự cụ thể của tập quán cố đất để giải quyết tranh chấp, xác định quyền và nghĩa vụ cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên tham gia giao dịch.

2.3 Đề xuất xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất

2.3.1 Định hướng xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh về giao dịch cố đất

Đất đai là lĩnh vực tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn mâu thuẫn, xung đột. Hoàn thiện pháp luật đất đai không chỉ thúc đẩy kinh tế phát triển, mà còn góp phần ổn định xã hội. Trong cơ chế thị trường, Nhà nước cần phải tạo hàng lang pháp lý thông thoáng để các giao dịch dân sự không bị cản trở bởi các quy định của pháp luật, huy động nguồn lực cho phát triển, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông tự do từ đó nền kinh tế của đất nước sẽ phát triển. Pháp luật về giao dịch dân sự bằng QSDĐ là bộ phận gắn kết chặt chẽ với pháp luật dân sự và hành chính. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải được đặt trong mối tương quan với các lĩnh vực pháp luật có liên quan. Để đáp ứng các yêu cầu trên đây, pháp luật về giao dịch cố đất cần được hoàn thiện theo các định hướng sau đây:

2.3.1.1 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải phù hợp với chế độ sở hữu về đất đai và bản chất pháp lý của QSDĐ

Như đã phân tích ở phần lý luận, đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân. Đây là nguyên tắc hiến định được lập ra từ Hiến pháp năm 1980 và luôn được duy trì, hoàn thiện cho đến nay. Pháp luật đất đai qua các thời kỳ 1987, 2003, 2013 và nay là Luật Đất đai năm 2024 đều nhất quán nguyên tắc này và cụ thể hóa thành những quy định cụ thể để thực thi quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Theo TS. Sỹ Hồng Nam nhận định: "Sở hữu toàn dân đối với đất đai là khái niệm mang tính chính trị pháp lý. Trước đây, do nhận thức không đúng về sở hữu toàn dân, cùng với đó là quan niệm sai lầm về vai trò, giá trị của đất đai nên tài nguyên này đã bị

khai thác và sử dụng một cách lãng phí, không hiệu quả"[65]. Thật vậy, sự không thống nhất trong cách hiểu về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai đã nảy sinh những vấn đề lý luận và thực tiễn hết sức phức tạp. Quan niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên người sử dụng đất chỉ được trao quyền sử dụng (một trong 03 quyền năng của chủ sở hữu) vẫn còn duy trì và bảo vệ ở một chừng mực nào đó trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Thực trạng thực thi pháp luật về giao dịch cố đất ở trên đã tiêu biểu cho vấn đề mà người sử dụng đất chưa thực sự làm chủ được QSDĐ của mình.

Bản chất pháp lý của QSDĐ đất trên thị trường cũng là vấn đề phải quan tâm khi định hướng hoàn thiện pháp luật về giao dịch cố đất. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và bản chất pháp lý của QSDĐ đất đặt trong một bức tranh tổng thể. Hoàn thiện pháp luật sao cho quyền quản lý đất đai được đảm bảo tập trung thuộc về nhà nước, nhưng đất đai phải được vận hành trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thông qua sáng kiến pháp lý mới đó là QSDĐ. Đưa QSDĐ vào giao dịch là để khai thác, sử dụng đất đai có hiệu quả, khơi thông một nguồn lực quan trọng nhất của đất nước để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Quan điểm này đã được thể hiện rõ trong các văn kiện quan trọng của Đảng. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khẳng định: "*QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu; QSDĐ, tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ*". Đây là định hướng đúng đắn, tạo điều kiện tối đa để khai thác và quản lý nguồn tài nguyên đất.

Những chủ trương, quy định pháp luật về quản lý và điều tiết đất đai phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội. Sự hài hòa về lợi ích của Nhà nước và người sử dụng đất mới chính là mục tiêu, là phương pháp đúng đắn để củng cố chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, thay vì ngăn cấm những quan hệ xã hội chưa nắm bắt được, chưa quản lý được. Do đó, hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất cũng là một trong những giải pháp cũng cố chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Tuy nhiên, cơ sở lý luận khoa học pháp lý XHCN, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, bản chất pháp lý của QSDĐ là những yếu tố mang tính định hướng cho vấn đề này.

2.3.1.2 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải phù hợp với tập quán và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Trong giai đoạn hiện nay, pháp luật được xác định là công cụ quan trọng nhất trong điều chỉnh các quan hệ xã hội nói chung, quan hệ dân sự nói riêng, nhưng tập quán với những đặc trưng riêng của mình luôn là nguồn bổ sung, thay thế cho pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội, đặc biệt là các quan hệ cụ thể phát sinh trong đời sống của các cộng đồng dân cư, trong đó giao dịch cố đất là một điển hình.

[65] TS. Sỹ Hồng Nam, Pháp luật về góp vốn bằng QSDĐ, Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2016, tr.119.

Nhà nước với bộ máy công quyền và công cụ pháp luật tồn tại là nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo đảm công lý được thực thi. Tuy nhiên, do các mối quan hệ kinh tế xã hội luôn vận động, phát triển nên sẽ có thời điểm pháp luật chưa theo kịp để điều chỉnh các quan hệ kinh tế xã hội mới phát sinh. Lúc này trách nhiệm thuộc vẫn về nhà nước, chứ không phải của nhân dân. Từ đó, BLDS năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đều đặt ra nguyên tắc chung bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan cơ thẩm quyền và cũng là nguyên tắc của tố tụng, đó là: *Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng*[66]. Trường hợp này, Điều 45 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định rõ, việc áp dụng các căn cứ để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng thực hiện theo thứ tự sau: (1) Áp dụng tập quán; (2) Áp dụng tương tự pháp luật; (3) Áp dụng nguyên tắc cơ bản của pháp luật, án lệ, lẽ công bằng.

Tập quán được ưu tiên áp dụng để giải quyết tranh chấp trong trường hợp pháp luật chưa có quy định. Từ đó, hoàn thiện pháp luật cũng phải trên cơ sở các quy tắc xử sự phù hợp của tập quán. Bởi vì, những quan hệ xã hội đã có tập quán điều chỉnh trong một thời gian lâu dài, thói quen giao dịch đã thành nếp trong đời sống xã hội và những quy tắc xử sự đó đã được mọi người thừa nhận, tuân theo từ đời này sang đời khác. Giao dịch cố đất theo tập quán sử dụng đất ở Việt Nam cũng không nằm ngoài đặc trưng cơ bản đó. Do vậy, hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải xuất phát từ nền tảng là những quy tắc của tập quán thì mới có tính khả thi. Ngược lại, những quy định pháp luật mang tính "áp đặt" trái ngược với lề thói giao dịch đã truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng dân cư thì rất khó có thể đi vào đời sống xã hội.

Xây dựng và hoàn thiện pháp luật dựa trên nền tảng tập quán của cộng đồng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội nói chung, quan hệ dân sự nói riêng không chỉ góp phần giải quyết thấu đáo, hợp tình, hợp lý những vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội mà còn là sự giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển một cách bền vững. Kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội ở nước ta cho thấy, không thể bỏ qua các đặc điểm văn hóa, đặc trưng dân tộc và khu vực trong công tác quản lý xã hội, bởi nếu bỏ qua các yếu tố này thì khi pháp luật đi vào đời sống sẽ khó được người dân tiếp nhận và thi hành một cách tự giác làm cho hiệu quả quản lý xã hội bị giảm đi đáng kể. Do vậy, để pháp luật về giao dịch cố đất có thể đi vào thực tế, quản lý tốt đời sống xã hội thì công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật không thể bỏ qua việc kế thừa những quy tắc xử sự chung của tập quán.

Tuy nhiên, hoàn thiện pháp luật phải đảm bảo định hướng không lệch khỏi quỹ đạo chung bất biến là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Bởi, nguyên tắc cơ bản của pháp luật là nền tảng của hệ thống pháp luật, là sợ chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ hệ thống pháp luật. Hệ thống pháp luật được thiết lập dựa trên các nguyên tắc cơ bản, do đó,

[66] Khoản 2 Điều 4 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

nguyên tắc cơ bản của pháp luật như hệ thống xương cốt làm nên giá đỡ cho toàn bộ hệ thống pháp luật. Nói cách khác, nguyên tắc cơ bản của pháp luật chính là cơ sở cho việc xây dựng, thực hiện và áp dụng pháp luật. Tập quán không chỉ là nguồn bổ sung cho pháp luật, là tiền đề khách quan đưa pháp luật vào cuộc sống mà còn là nguồn nội dung của pháp luật, là "chất liệu quý" để hoàn thiện một nền pháp luật tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Song, những quy tắc xử sự chung của tập quán khi được luật hóa cần phải được sàn lọc, điều chỉnh đảm bảo không trái với các nguyên tắc cơ bản của luật.

2.3.1.3 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải đảm bảo quyền tự do giao dịch trong kinh tế thị trường, thúc đẩy dòng vốn và tích tụ đất nông nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ dân sự, kinh tế ngày càng mở rộng và phát triển. Khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì yêu cầu hoàn thiện pháp luật đáp ứng đòi hỏi của kinh tế thị trường càng trở nên cấp thiết. Với chức năng là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội thì trong bất kỳ nền kinh tế nào cho dù là kế hoạch hóa hay kinh tế thị trường vẫn cần tới pháp luật. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế được vận động chủ yếu thông qua các nguyên tắc tự do kinh doanh, tự nguyện giao dịch tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Bằng pháp luật, Nhà nước ghi nhận các nguyên tắc của kinh tế thị trường như quyền sở hữu tư nhân, quyền tự do kinh doanh, tự do cạnh tranh, quyền tự định đoạt. Nhà nước không can thiệp vào thị trường bằng kế hoạch, mệnh lệnh như trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung mà can thiệp bằng việc tạo hành lang pháp lý an toàn cho các cá nhân sản xuất, kinh doanh.

QSDĐ là một tài sản và hàng hóa đặc biệt trong kinh tế thị trường. Sự vận hành linh hoạt của QSDĐ trong giao lưu dân sự và thương mại là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Trong đó, giao dịch cố đất cũng không nằm ngoài chuỗi quy luật chung của kinh tế thị trường. Người có QSDĐ có nhu vầu về vốn nhưng không thể chuyển nhượng "đứt" ruộng đất của mình, người có vốn nhàn rỗi muốn đầu tư vào đất trực tiếp qua việc nhận đất cố để canh tác, hoặc cho thuê đất cố đó để hưởng hoa lợi, đôi bên đều có lợi. Nguồn lực đất đai vì thế cũng được khai phóng, chuyển đổi dòng vốn phục vụ sản xuất và mở ra một "nguồn cung đất đai" lớn ở khu vực nông thôn để đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả cao nhất nguồn tài nguyên đất mà không ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nào. Thực tế đó đòi hỏi Nhà nước cần tôn trọng sự tự do, tự nguyện giao dịch của người sử dụng đất mà trước hết đó là giao dịch cố đất. Đây không phải là một phát kiến mới của kinh tế thị trường mà vốn là sản phẩm của quá trình tích lũy, chắt lọc trong đời sống xã hội, được lưu truyền từ nhiều thế hệ nên đã gắn bó, gần gũi với lối sống và tâm lý của người nông dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, vấn đề tích tụ đất nông nghiệp còn là mục tiêu kinh tế quan trọng của Đảng và Nhà nước ta khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật đất đai hiện nay. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế, tích tụ đất nông nghiệp hướng đến việc hình thành những thửa đất, cánh đồng rộng lớn, thuận lợi cho hoạt động

tổ chức sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 được ban hành chỉ ghi nhận 02 phương thức tích tụ đất nông nghiệp đó là nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp và nhận góp vốn bằng QSDĐ nông nghiệp[67]. Đây là bước tiến lớn trong chính sách tổ chức sử dụng đất nông nghiệp quy mô lớn. Song, trên thực tế thì cho thuê QSDĐ dài hạn hay cố đất mới là phương thức tích tụ ruộng đất phổ biến ở nông thôn, đòi hỏi người nông dân bỏ ra ít vốn hơn, ít rủi ro hơn so với việc nhận chuyển nhượng QSDĐ mà hiệu quả tập trung ruộng đất cao hơn. Do đó, Luật Đất đai năm 2024 mặc dù đã mở cửa cho việc tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, nhưng xét ở một chừng mực nào đó, đây mới chỉ là một "khe cửa hẹp" dành cho những chủ đầu tư có nguồn vốn dồi dào. Những người nông dân cố cựu, nhất là ở vựa lúa ĐBSCL, vốn đã và đang tích tụ ruộng đất bằng hình thức nhận thuê dài hạn hay nhận cố đất để canh tác trồng lúa quy mô lớn thì vẫn chưa được hợp pháp hóa.

Thực tế cho thấy quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật luôn luôn hướng đến sự đổi mới toàn diện, sâu sắc, đảm bảo quyền tự do giao dịch trong kinh tế thị trường. Quan điểm đó xác định rõ: "*Chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát bỏ tư duy 'không quản được thì cấm'. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài; luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc; không cần quá dài*"[68]. Song, khi cụ thể hóa thì những quy định pháp luật của ta vẫn còn khá "dè dặt", còn giới hạn phương thức này được thực hiện, cấm loại giao dịch kia không được thực hiện. Đó là vẫn còn giữ lối tư duy "không quản được thì cấm", chưa thực sự khuyến khích sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển như đường lối, chủ trương của Đảng. Do vậy, ở góc nhìn của giao dịch "cố đất" theo tập quán ở vùng nông thôn Việt Nam, hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh giao dịch này là nhiệm vụ tất yếu. Trong đó, định hướng là đảm bảo được quyền tự do giao dịch, đa dạng hóa các phương thức trong một hành lang pháp lý ổn định, hiệu quả.

2.3.1.4 Pháp luật để điều chỉnh về giao dịch cố đất phải đảm bảo tính đồng bộ giữa Luật Đất đai và quy định pháp luật khác có liên quan

Tính đồng bộ của pháp luật thể hiện ở cấp độ chung và cấp độ cụ thể. Ở cấp độ chung là sự đồng bộ giữa các ngành luật. Ở cấp độ cụ thể đó là thể hiện sự thống nhất, không mâu thuẫn, chồng chéo trong mỗi ngành luật, mỗi chế định pháp luật. Tính đồng bộ của hệ thống pháp luật thể hiện khả năng đáp ứng được đầy đủ nhu cầu điều chỉnh quan hệ xã hội. Tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật còn có ảnh hưởng

[67] Khoản 1 Điều 193 của Luật Đất đai năm 2024.

[68] Kênh YouTube VTV24, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 21/10/2024, https://www.youtube.com/watch?v=BnvDIWGe5eQ [truy cập 01/12/2024].

quan trọng tới tính khả thi của pháp luật. Do dó, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật phải quan tâm đến các văn bản pháp luật khác nhau trong cùng lĩnh vực.

Thực tế cho thấy, giao dịch cố đất chưa có văn bản pháp luật nào điều chỉnh, nhưng để điều chỉnh nó đòi hỏi phải hoàn thiện quy định của nhiều ngành luật với nhiều văn bản pháp luật, trong đó pháp luật dân sự và pháp luật đất đai là chủ đạo. Điều này đặt ra yêu cầu phải hệ thống hóa quy phạm pháp luật có liên quan đến điều cấm của luật, việc áp dụng tập quán trong giao dịch dân sự, các quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, các quyền cụ thể của người sử dụng đất, quản lý của nhà nước trong đăng ký giao dịch về QSDĐ, v.v. Đồng thời, nhiều vấn đề khác có liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của BLDS, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.3.2 Nội dung xây dựng nguyên tắc pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất

2.3.2.1 Quy định về "điều cấm của luật" và vấn đề "áp dụng tập quán"

Hiện nay, khái niệm "điều cấm của luật" đã được định nghĩa rõ tại khoản 1 Điều 123 của BLDS năm 2015. Theo đó, *"điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định"*.

Tuy nhiên, như đã phân tích, đánh giá tại phần 2.1.2.2 của Chương này, các Tòa án khi tuyên xử giao dịch cố đất vô hiệu, dù lập luận từ nhiều hướng khác nhau, song vẫn có chung kết luận rằng giao dịch cố đất vô hiệu là do "vi phạm điều cấm của luật" theo quy định tại Điều 123 của BLDS năm 2015. Có thể thấy, dường như đường lối nhất quán của Tòa án là phải làm sao để "không thừa nhận giao dịch cố đất", nên xét trong bối cảnh chung của pháp luật Việt Nam hiện hành, lập luận và nhận định của các bản án khi tuyên vô hiệu giao dịch này đã tỏ ra rất khiên cưỡng. Bản thân thuật ngữ "điều cấm của luật" hoàn toàn không bao hàm những trường hợp mà luật không quy định.

Vấn đề thứ hai có liên quan mật thiết đó là việc "áp dụng tập quán" theo quy định tại Điều 5 của BLDS năm 2015 chỉ mang tính tùy nghi lựa chọn. Theo quy định tại khoản 2 Điều này, "*trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì **có thể** áp dụng tập quán ...*". Nói cách khác, khi pháp luật thành văn không có quy định điều chỉnh một quan hệ xã hội, dù sẵn có tập quán phù hợp thì Tòa án "có thể" áp dụng hoặc quyết định không áp dụng. Đây rõ ràng là một quy định tùy nghi, thiếu tính áp đặt cần thiết của một quy phạm. Bởi vì Điều luật chỉ quy định ở mức "có thể áp dụng" nên việc các TAND không áp dụng tập quán trong những trường hợp cụ thể, dù có đưa đến một kết quả không công bằng thì cũng không phải là vi phạm pháp luật hay có thiếu sót trong áp dụng pháp luật. Ngược lại, lựa chọn không áp dụng tập quán tỏ ra là một lựa chọn an toàn hơn cho các bản án, quyết định của Tòa án.

Vì vậy, để khắc phục hạn chế, bất cập nêu trên và tạo hành lang pháp lý để Tòa án không tuyên giao dịch vô hiệu mà phải áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất, giải pháp trước hết cần hoàn thiện quy định của pháp luật như sau:

Thứ nhất, TAND tối cao cần có văn bản giải thích thống nhất để nhận thức đúng khái niệm "điều cấm của luật". Mặc dù BLDS năm 2015 đã có định nghĩa rõ ràng, song thiết nghĩ việc giải thích áp dụng pháp luật trong trường hợp này không hẳn là một việc làm vô nghĩa. Theo đó, tác giả kiến nghị TAND tối cao nên giải thích rõ và yêu cầu các Tòa án địa phương chỉ được xác định "giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật" khi có quy định cụ thể của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Chẳng hạn, theo quy định tại Điều 471 của BLDS năm 2015 quy định:

"Điều 471. Họ, hụi, biêu, phường

1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

2. Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này.

4. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi".

Như vậy, trong giao dịch về họ, hui, biêu, phường đơn thì chỉ có hành vi "tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi" mới vi phạm điều cấm của luật. Tương tự, bản thân giao dịch cố đất không phải là giao dịch vi phạm điều cấm của luật vì không có quy định nào trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành "không cho phép" thực hiện giao dịch này, chỉ khi nào người tham gia giao dịch lợi dụng việc cố đất để chiếm đoạt tài sản của người khác thì mới xem xét là hành vi vi phạm điều cấm của luật.

Thứ hai, quy định tại khoản 2 Điều 5 của BLDS năm 2015 về áp dụng tập quán cần được sửa đổi theo hướng mệnh lệnh dứt khoát. Cụ thể, *"trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này"*. Như vậy, thứ tự ưu tiên áp dụng được xác định rõ, từ thỏa thuận của các bên, quy định của pháp luật đến quy tắc xử sự chung của tập quán. Lúc này, Tòa án từ chối áp dụng một tập quán hoặc một quy tắc xử sử chung nào đó của tập quán được đề nghị, buộc phải nhận định rõ lý do vì sao không áp dụng. Có như thế, quy định về áp dụng tập quán mới đi vào đời sống xã hội, được thực thi trong thực tiễn xét xử.

2.3.2.2 Quy định về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố quyền sử dụng đất

Một trong những định hướng hoàn thiện pháp luật về giao dịch cố đất là để đảm bảo quyền tự do giao dịch tài sản trong kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho các bên tham gia giao dịch được chủ động, tự nguyện giao kết không trái với các nguyên tắc cơ bản của luật. Song, việc hoàn thiện pháp luật đề điều chỉnh giao dịch cố đất, đưa loại

giao dịch này vào trong bức tranh tổng thể của pháp luật hiện hành phải phù hợp với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và bản chất pháp lý của QSDĐ tại Việt Nam. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn đã phân tích cho thấy, giao dịch cố đất là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự xuất hiện từ sớm, đang tồn tại trong tập quán và cần thiết phải được luật hóa để điều chỉnh. Theo đó, quy định về giao dịch cố đất trong pháp luật Việt Nam cần được hoàn thiện với các nội dung sau đây:

Thứ nhất, về tên gọi "cố đất" cũng như những giao dịch khác về đất đai từng được xuất hiện trong xã hội như "mua bán đất", "thuê đất", "tặng cho đất" khi được luật hóa đều dựa vào bản chất của giao dịch để quy về những tên gọi có tính chuẩn mực pháp lý là "chuyển nhượng QSDĐ", "cho thuê QSDĐ", "tặng cho QSDĐ". Tương tự, thuật ngữ "cố đất" như đã phân tích ở phần lý luận, nếu đặt trong hệ quy chiếu pháp luật dân sự hiện hành của Việt Nam, giao dịch "cố" mang bản chất của giao dịch "cầm cố", là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 292 của BLDS năm 2015. Nếu đặt trong hệ quy chiếu pháp luật về đất đai, dưới chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và các quy định hiện hành của Việt Nam thì thuật ngữ "đất" trong giao dịch dân sự có bản chất pháp lý là nói đến "QSDĐ" với tư cách một loại tài sản và hàng hóa đặt biệt được phép giao dịch. Do đó, trong bối cảnh pháp luật Việt Nam hiện hành, hoàn thiện pháp luật có liên quan để điều chỉnh giao dịch cố đất theo tập quán trước hết cần thống nhất về tên gọi, giao dịch "cố đất" chính là giao dịch "cầm cố QSDĐ".

Thứ hai, về cấu trúc quy định của luật về biện pháp cầm cố tài sản, BLDS hiện hành (khoản 2 Điều 310) ghi nhận đối tượng cầm cố tài sản có thể là động sản hoặc bất động sản. Tuy nhiên, BLDS và các văn bản pháp luật có liên quan đều không có quy chế pháp lý riêng dành cho việc cầm cố bất động sản. Theo đó, quy định cụ thể trong 08 điều (từ Điều 309 đến Điều 316) của BLDS năm 2015 và các Điều 31, Điều 32 của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là những quy định áp dụng chung cho các loại tài sản.

Vấn đề cấu trúc của luật về cầm cố tài sản được xây dựng với quy định chung và riêng dành cho mỗi loại tài sản được đặt ra bởi đặc trưng "giao - giữ" tài sản khi thực hiện biện pháp cầm cố. Theo đó, với những loại tài sản vô hình như quyền tài sản, hay các tài sản đặc biệt như QSDĐ và bất động sản khác đòi hỏi pháp luật có những quy định đặc thù để điều chỉnh quyền, nghĩa vụ của mỗi bên tham gia giao dịch. Thực tế, pháp luật dân sự của các quốc gia trên thế giới đều có xu hướng quy định riêng cầm cố tài sản đối với động sản (hữu hình và vô hình), bất động sản và quyền tài sản.

Trong pháp luật của Pháp, BLDS nước này khi quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (Quyển IV) đã cấu trúc thành 02 thiên gồm: Các biện pháp bảo đảm đối vật và các biện pháp bảo đảm đối nhân. Trong đó, bảo đảm đối vật bao gồm các biện pháp bảo đảm bằng động sản và các biện pháp bảo đảm bằng bất động sản. Vì thế, cầm cố tài sản cũng được phân định theo đối tượng tài sản cụ thể (động sản hữu hình, tài sản vô hình và bất động sản). Với cấu trúc này, bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố đối với bất

động sản là đất đai (hay QSDĐ) được minh bạch trong quy định của luật. Tương tự như trong pháp luật của Lào, biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố được quy định từ Điều 526 đến Điều 545 của BLDS năm 2018 của nước này. Trong đó, Bộ luật này dành hẳn Điều 527 quy định rõ biện pháp cầm cố gồm có 03 loại cầm cố chính là cầm cố bằng động sản; cầm cố bằng bất động sản và cầm cố bằng quyền. Đồng thời, từng loại cầm cố nêu trên được cấu trúc thành từng mục riêng biệt với định nghĩa cụ thể, quy định cụ thể về điều kiện thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch, hệ quả của cầm cố cũng như việc chấm dứt quan hệ cầm cố, v.v. Do vậy, cầm cố bất động sản và cầm cố QSDĐ trong pháp luật của Lào cũng được quy định một cách rõ ràng.

Trong phạm vi nghiên cứu này, từ góc nhìn lý luận và thực tiễn của giao dịch cố đất theo tập quán ở nông thôn Việt Nam, tham khảo quy định pháp luật các nước, tác giả kiến nghị sửa đổi BLDS năm 2015 quy định về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố tài sản theo hướng phân định rõ các loại cầm cố chính gồm bảo đảm bằng động sản, bảo đảm bằng bất động sản và bảo đảm bằng quyền tài sản. Trong đó, bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố QSDĐ cần được ghi nhận là một vật quyền bảo đảm đặc biệt với các quyền, nghĩa vụ cụ thể của các bên khi tham gia giao dịch.

2.3.2.3 Quy định về các quyền thực hiện giao dịch bằng quyền sử dụng đất

Trên cơ sở đề xuất sửa đổi BLDS năm 2015 về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố bất động sản, quy định về các quyền thực hiện giao dịch bằng QSDĐ của người sử dụng đất trong Luật Đất đai hiện hành cũng cần được hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật yêu cầu loại bỏ tư duy "không quản được thì cấm", là đòi hỏi có tính tất yếu, tôn trọng thực tại khách quan của xã hội. Nếu như QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt thì các giao dịch về QSDĐ cần được điều chỉnh bởi một hành lang pháp lý đặc biệt, thay vì kiểm soát bằng việc giới hạn người sử dụng đất chỉ 08 quyền giao dịch cụ thể như hiện nay là quan điểm hạn chế sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu khai phóng sức sản xuất và nguồn lực đất đai để phát triển. Theo đó, tác giả kiến nghị rằng giao dịch về QSDĐ ở nước ta cần được giải phóng ra khỏi khuôn khổ của 08 loại hình hiện tại (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ; thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ).

Giao dịch dân sự là các hợp đồng hoặc hành vi pháp lý làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự, có tính chất đa dạng, phong phú. Tùy vào thực tại môi trường xã hội, mục tiêu cụ thể mà các chủ thể lựa chọn cho mình hình thức giao dịch phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Vấn đề đặt ra là giao dịch hợp lý đối với một chủ thể không làm phương hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác[69]. Đối với QSDĐ, tuy là tài sản và tuy là hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là hàng cấm hay hàng hóa phải hạn chế giao dịch. Thực tế, cùng là

[69] Khoản 4 Điều 3 của BLDS năm 2015.

biện pháp bảo đảm nghĩa vụ mang lại lợi ích chính đáng cho người sử dụng đất nhưng thế chấp QSDĐ thì được công nhận, còn cố đất (cầm cố QSDĐ) bị vô hiệu chính là điểm bất cập lớn. Nếu như lập luận cho rằng giao dịch cầm cố không được ghi nhận là một trong các quyền tại Điều 27 của Luật Đất đai thì các giao dịch như "cho mượn QSDĐ" cũng không được ghi nhận nhưng thực tiễn xét xử lại thừa nhận giao dịch hợp pháp và xử lý quyền, nghĩa vụ của các bên theo thỏa thuận, rõ ràng đây là vấn đề không nhất quán, bất cập và mâu thuẫn trong hoạt động xét xử của Tòa án.

Do đó, tác giả đề xuất Luật Đất đai không nên liệt kê các quyền giao dịch về QSDĐ theo hướng "đóng khung" 08 loại quyền giao dịch cụ thể. Điều này dẫn đến cách hiểu và áp dụng pháp luật theo hướng xác định mọi loại giao dịch khác được thực hiện không với tên gọi của 08 giao dịch tại Điều 27 của Luật Đất đai đều được xem là vi phạm. Giải pháp cụ thể cần sửa đổi, bổ sung quy định Điều 26 của Luật Đất đai về quyền chung của người sử dụng đất. Trong đó, bổ sung khoản 9 của Điều này quy định "quyền được thực hiện giao dịch về QSDĐ theo quy định của pháp luật". Đồng thời, sửa đổi quy định tại Điều 27, Điều 45 của Luật Đất đai theo hướng bổ sung "quyền cầm cố QSDĐ, giao dịch khác về QSDĐ" và điều kiện thực hiện "quyền cầm cố QSDĐ, giao dịch khác về QSDĐ" phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

2.3.3 Nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về giao dịch cố đất

2.3.3.1 Hoàn thiện quy định về thông tin và đăng ký quyền sử dụng đất

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, những biến động về đất đai thông qua các giao dịch bằng QSDĐ đều phải được đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch cố đất, trong tương lai gần nếu được công nhận là hợp pháp, cũng thuộc nhóm các giao dịch có việc chuyển giao QSDĐ từ chủ thể này sang chủ thể khác. Thực tế cho thấy, giao dịch cố đất (trừ trường hợp thỏa thuận cho thuê lại) được thực hiện dẫn tới việc bên cố đất giao QSDĐ cho bên nhận cố đất quản lý, canh tác; đôi khi có sự cải tạo, hợp thửa, ngăn bờ, dẫn nước, tiêu nước, v.v. Pháp luật không quy định rõ trường hợp này thì càng khó khăn hơn trong công tác quản lý đất đai. Đây là vấn đề không chỉ đặt ra đối với các bên trong quan hệ cố đất mà còn đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, trước hết là các Văn phòng đăng ký đất đai hiện nay.

Văn phòng đăng ký đất đai là nơi đăng ký những biến động về đất đai, là nơi lưu trữ và cũng là nơi chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất. Điều này có nghĩa khi mọi giao dịch liên quan đến QSDĐ phải được đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ khi được đăng ký. Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai còn là nơi lưu trữ thông tin về đất đai. Việc lưu trữ thông tin về đất đai không chỉ phục vụ cho việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, mà còn là nơi để cung cấp thông tin giúp người sử dụng đất tìm hiểu khi có yêu cầu. Chính vì vậy, đòi hỏi giao dịch cố đất không chỉ cần được công nhận và cần phải có sự quản lý chặt chẽ để cập nhật biến động về chủ thể đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất, góp phần minh bạch hóa thông tin về đất đai.

Luật Đất đai năm 2024 đã khắc phục được một số bất cập, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Ngoài ra, sự liên thông dữ liệu về đất đai giữa các địa phương còn chưa được thực hiện đầy đủ. Việc đăng ký bất động sản trong đó có QSDĐ được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật có giá trị pháp lý khác nhau. Chúng ta chưa có một đạo luật thống nhất về đăng ký bất động sản. Trong khi đó, một bất động sản có thể tham gia nhiều quan hệ khác nhau và phải thực hiện nhiều loại đăng ký như đăng ký là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong pháp luật đất đai hay đăng ký giao dịch bảo đảm khi QSDĐ là đối tượng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về giao dịch cố đất, thì việc đồng thời với xây dựng hành lang pháp lý điều chỉnh giao dịch cố đất thì cũng cần phải hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, dữ liệu, liên thông dữ liệu về đất đai tiến tới nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Đăng ký bất động sản.

2.3.3.2 Hướng dẫn áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất

TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Bên cạnh chức năng xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định thì tại điểm đ và điểm e khoản 2 Điều 3 của Luật Tổ chức TAND năm 2024 đã bổ sung 02 nhiệm vụ quan trọng của Tòa án đó là: (1) Giải thích áp dụng pháp luật trong xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc; (2) Tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; phát triển án lệ.

Để các Tòa án địa phương mạnh dạn hơn trong việc viện dẫn các quy tắc xử sự chung của tập quán giao dịch cố đất trong xét xử, giải quyết các vụ việc có liên quan một cách công bằng, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và hướng tới mục tiêu hoàn thiện các quy định của pháp luật từ thực tiễn áp dụng, thiết nghĩ Hội đồng Thẩm phán TANDTC cần sớm có văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong giải quyết các tranh chấp có liên quan đến giao dịch cố đất trong thực tiễn. Trước hết, nghiên cứu đề xuất nội dung hướng dẫn của TAND tối cao cần giải đáp được:

Một là, nhận thức thống nhất về "điều cấm của luật" là *những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định* đã được định nghĩa một cách rõ ràng theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của BLDS năm 2015. Do đó, các Tòa án không được tùy tiện suy đoán và viện dẫn, cho rằng một giao dịch dân sự hay một hành vi được xác lập là vi phạm điều cấm của luật khi chưa có quy định của pháp luật nói rằng không cho phép chủ thể thực hiện hành vi đó, giao dịch đó.

Hai là, trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự cụ thể liên quan đến giao dịch cố đất (cầm cố QSDĐ), các Tòa án không tuyên bố vô hiệu đối với giao dịch cố đất nếu chỉ có lý do cho rằng đây là "giao dịch vi phạm điều cấm của luật" theo quy định tại Điều 123 của BLDS năm 2015. Tùy trường hợp cụ thể, Tòa án cần áp dụng quy tắc xử sự chung của tập quán tại địa phương để xem xét, giải quyết theo hướng công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc buộc các bên thực hiện quyền, nghĩa vụ đã thỏa thuận

khi xác lập giao dịch, đảm bảo phù hợp với tập quán tốt đẹp của địa phương, không trái với các nguyên tắc cơ bản của BLDS và đạo đức xã hội.

2.3.3.3 Lựa chọn và công bố án lệ về giao dịch cố đất ở nông thôn Việt Nam

Từ những vấn đề đã phân tích, có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để lựa chọn và công bố các án lệ về giao dịch cố đất ở nông thôn, tạo tiền đề pháp lý quan trọng cho việc tổng kết thực tiễn và hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan. Thật vậy, việc lựa chọn và công bố án lệ về giao dịch cố đất ở nông thôn Việt Nam là một giải pháp quan trọng để giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong thực tiễn.

Giao dịch cố đất, mặc dù phổ biến ở nhiều địa phương, nhưng hiện nay chưa có quy định pháp luật rõ ràng để điều chỉnh. Điều này tạo ra sự lúng túng trong việc áp dụng pháp luật và giải quyết tranh chấp, đặc biệt là trong bối cảnh những giao dịch này không hoàn toàn phù hợp với các quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Án lệ, theo quy định tại Điều 45 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, có giá trị pháp lý và có thể là một công cụ hữu hiệu để hướng dẫn xét xử trong các trường hợp chưa có quy định cụ thể. Việc lựa chọn và công nhận án lệ về giao dịch cố đất sẽ giúp đảm bảo tính nhất quán trong áp dụng pháp luật, tạo cơ sở vững chắc cho các Thẩm phán trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến loại giao dịch này.

Quy trình lựa chọn án lệ về giao dịch cố đất có thể bắt đầu bằng việc thu thập và phân tích các vụ án có liên quan đến giao dịch cố đất. Các phán quyết này sẽ được đánh giá dựa trên cơ sở pháp lý đã áp dụng và tính phù hợp với các nguyên tắc chung của pháp luật dân sự. Sau khi phân tích, những phán quyết này sẽ được đề xuất cho Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xem xét và công nhận các bản án làm án lệ nếu có tính chất điển hình, có thể áp dụng rộng rãi trong các trường hợp tương tự. Việc công bố án lệ về giao dịch cố đất giúp các Thẩm phán, Luật sư và các bên liên quan có một tài liệu tham khảo quan trọng trong quá trình xét xử, giảm thiểu sự không thống nhất trong các phán quyết và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xét xử của Tòa án.

Công bố án lệ về giao dịch cố đất sẽ mang lại nhiều lợi ích, trong đó nổi bật là việc tạo ra sự thống nhất trong áp dụng pháp luật. Các Thẩm phán sẽ có căn cứ rõ ràng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch này, từ đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Việc áp dụng án lệ cũng giúp giảm thiểu sự mơ hồ trong quá trình xét xử, góp phần tạo ra một hệ thống pháp lý minh bạch, công bằng và ổn định hơn.

Bên cạnh đó, án lệ sẽ tạo tiền đề cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, bổ sung các quy định rõ ràng vào Luật Đất đai hoặc BLDS để giải quyết những vấn đề pháp lý chưa được điều chỉnh đầy đủ. Việc lựa chọn và công bố án lệ về giao dịch cố đất không chỉ giải quyết vấn đề thực tiễn mà còn tạo điều kiện cho hệ thống pháp lý phát triển bền vững trong tương lai.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định nào đề cập đến cái gọi là "giao dịch cố đất" hay thậm chí là "giao dịch cầm cố QSDĐ". Trong khi đó, quy định của BLDS năm 2015 không cấm các chủ thể thực hiện cầm cố đối với tài sản là bất động sản. Song, Luật Đất đai năm 2024 chỉ đề cập đến 08 quyền giao dịch về QSDĐ của người sử dụng đất gồm: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng QSDĐ. Theo đó, thực tiễn xét xử đều giải quyết theo hướng tuyên bố giao dịch cố đất (hay cầm cố QSDĐ) bị vô hiệu do "vi phạm điều cấm của luật" theo quy định tại Điều 123 của BLDS năm 2015.

Thế nhưng, cố đất không phải là một tập quán giao dịch tự phát và cục bộ mà đã hình thành và duy trì trong suốt chiều dài lịch sử canh tác đất ruộng của nông dân Việc Nam. Ngày nay, giao dịch cố đất, tự bản thân nó vẫn phù hợp với xã hội Việt Nam hiện đại và không phải là những hành vi tiêu cực đáng phải bài trừ, ngăn cấm. Thực tế, giao dịch cố đất chưa được ghi nhận trong luật thành văn, nhưng tập quán đã bao hàm những quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của các bên từ lâu đời, thậm chí đã từng được pháp luật thời kỳ phong kiến và các đạo luật thời kỳ thuộc Pháp điều chỉnh trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong phạm vi cả nước, mà tiêu biểu nhất là trong tập quán sử dụng đất ở vùng ĐBSCL. Do đó, trong trường hợp pháp luật thành văn chưa có quy định, giải pháp đặt ra là Tòa án không thể tuyên vô hiệu giao dịch cố đất do vi phạm điều cấm của luật mà phải áp dụng tập quán với những quy tắc xử sự chung phù hợp và các quy định khác có liên quan để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch mà không có gì vi phạm vào điều cấm hay trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hoàn thiện pháp luật giao dịch cố đất ở Việt Nam là yêu cầu tất yếu khách quan, phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế, đồng thời phải xuất phát từ đường lối, chính sách của Đảng. Hoàn thiện pháp luật đất đai không chỉ thúc đẩy kinh tế phát triển, mà còn góp phần ổn định xã hội. Trong cơ chế thị trường, Nhà nước cần phải tạo hàng lang pháp lý thông thoáng để các giao dịch dân sự không bị cản trở bởi các quy định của pháp luật, huy động nguồn lực cho phát triển, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông tự do từ đó nền kinh tế của đất nước sẽ phát triển. Hoàn thiện pháp luật về giao dịch cố đất còn là một trong những biện pháp cụ thể hóa chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai trong điều kiện đất đai được xác định là một hàng hóa đặc biệt, một nguồn vốn quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Song, hoàn thiện pháp luật về giao dịch cố đất phải đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giao dịch cố đất bao gồm: Cần có quy định thống nhất về tên gọi, theo đó giao dịch cố cầm cố QSDĐ được sử dụng thống nhất trong tất cả các văn bản pháp luật cho phù hợp với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và bản chất pháp lý của QSDĐ tại Việt Nam; sửa đổi cấu trúc quy định của BLDS về bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố động sản và bất động sản; mở rộng phạm vi thực

hiện các quyền giao dịch về QSDĐ theo hướng công nhận người sử dụng đất có quyền thực hiện giao dịch cầm cố QSDĐ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực thi quy định của pháp luật về giao dịch cố đất thông qua việc hoàn thiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm; hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất và ban hành án lệ trong việc giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất.

KẾT LUẬN

"Giao dịch cố đất " là một trong những phương thức giao dịch được xác lập theo tập quán, phổ biến đối với đất nông nghiệp ở các vùng nông thôn Việt Nam. Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề này nhưng vẫn còn rất hạn chế. Bản thân giao dịch cố đất là một loại hình giao dịch đặc thù liên quan đến đất đai nhưng pháp luật hiện hành chưa có quy định để điều chỉnh. Do đó, lý luận vẫn còn nhiều tranh luận và thực tiễn đôi khi tìm cách "lãng tránh" khi giải quyết các tranh chấp có liên quan. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả rút ra một số kết luận như sau:

Thứ nhất, QSDĐ là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, trị giá được bằng tiền và lưu thông trong các giao dịch dân sự, thương mại bằng các phương thức được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Khi một chủ thể quyết định đem QSDĐ của mình tham gia vào một giao dịch nào đó nằm ngoài các quyền được liệt kê tại Điều 27 của Luật đất đai (như cầm cố, bảo lãnh, chuyển nhượng có điều kiện chuộc lại) thì đó cũng không phải là điều ngẫu nhiên hay họ cố tình làm điều gì đó ngoài luật định. Thực tế, lợi ích và nhu cầu của các chủ thể là yếu tố khởi điểm cho mọi hành động xã hội. Từ lý luận và thực tiễn cho thấy, giao dịch về QSDĐ cần được giải phóng ra khỏi khuôn khổ của 08 phương thức cụ thể xác định bởi Luật Đất đai hiện hành. Người có tài sản là QSDĐ có quyền lựa chọn phương thức giao dịch và đưa tài sản của mình tham gia vào giao dịch đó; điều này thúc đẩy lưu thông dân sự, huy động mọi nguồn lực ở mọi khía cạnh để tạo ra nhiều giá trị hơn cho kinh tế thị trường. Việc giới hạn tự do hợp đồng không phải ở việc thừa nhận giao dịch này, loại bỏ giao dịch kia ra khỏi đời sống dân sự, mà là ở những công cụ pháp lý vĩ mô đảm bảo cho sự bình đẳng, an toàn của các chủ thể khi tham gia giao dịch.

Thứ hai, sự tồn tại của giao dịch cố đất trong đời sống xã hội ở khu vực nông thôn là một tất yếu khách quan, có tính lịch sử và hiện thực. Giao dịch cố đất chưa được ghi nhận trong luật thành văn, nhưng tập quán đã bao hàm những quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của các bên từ lâu đời, thậm chí đã từng được pháp luật thời kỳ phong kiến và các đạo luật thời kỳ thuộc Pháp điều chỉnh trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong phạm vi cả nước, mà tiêu biểu nhất là trong tập quán sử dụng đất ở vùng ĐBSCL. Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định nào đề cập đến cái gọi là "giao dịch cố đất" hay thậm chí là "giao dịch cầm cố QSDĐ". Trong khi đó, quy định của BLDS năm 2015 không cấm các chủ thể thực hiện cầm cố đối với tài sản là bất động sản. Song, Luật Đất đai năm 2024 chỉ đề cập đến 08 quyền giao dịch về QSDĐ của người sử dụng đất gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng QSDĐ.

Thứ ba, thực tiễn xét xử hiện nay giải quyết các tranh chấp có liên quan theo hướng tuyên bố giao dịch cố đất (hay cầm cố QSDĐ) bị vô hiệu do "vi phạm điều cấm của luật" theo quy định tại Điều 123 của BLDS năm 2015. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy đây là đường lối giải quyết không phù hợp với lý luận pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và pháp luật đất đai hiện hành của Việt Nam. Bởi vì, pháp luật hiện hành chưa có quy định để

điều chỉnh nhưng cũng không có quy định nào "cấm" các chủ thể thực hiện giao dịch cố đất hay cầm cố QSDĐ. Do đó, lập luận của các bản án cho rằng giao dịch cố đất vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật là có phần "khiêng cưỡng" và cố tình "lãng tránh" đi vấn đề thực tiễn đây là giao dịch chưa có điều luật áp dụng. Thay vào đó, trong trường hợp này, nghiên cứu đi đến đề xuất Tòa án không thể tuyên vô hiệu giao dịch cố đất vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật mà phải áp dụng tập quán với những quy tắc xử sự chung phù hợp, cùng với việc áp dụng tương tự pháp luật ở các quy định khác có liên quan, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật, án lệ (nếu có), lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp đó nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

Từ đó, một trong những giải pháp quan trọng là pháp luật cần điều chỉnh và công nhận các giao dịch cố đất theo tập quán trong khuôn khổ pháp lý chính thức. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên trong giao dịch mà còn giảm thiểu tranh chấp về đất đai trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giao dịch cố đất được đề xuất bao gồm: Cần có quy định thống nhất về tên gọi, theo đó giao dịch cố cầm cố QSDĐ được sử dụng thống nhất trong tất cả các văn bản pháp luật cho phù hợp với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và bản chất pháp lý của QSDĐ tại Việt Nam; sửa đổi cấu trúc quy định của BLDS về bảo đảm nghĩa vụ bằng cầm cố động sản, bất động sản và quyền tài sản; mở rộng phạm vi thực hiện các quyền giao dịch về QSDĐ theo hướng công nhận người sử dụng đất có quyền thực hiện giao dịch cầm cố QSDĐ, các giao dịch khác bằng QSDĐ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực thi quy định của pháp luật có liên quan đến giao dịch cố đất thông qua việc hoàn thiện quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch về QSDĐ, hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất và sớm lựa chọn, công bố những án lệ điển hình, có liên quan trong việc giải quyết tranh chấp về giao dịch cố đất.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, GIÁO TRÌNH, TẠP CHÍ, LUẬN VĂN

1. Dương Anh Sơn, Hoàng Vĩnh Long, "Tự do hợp đồng – từ bàn tay vô hình đến chủ nghĩa can thiệp", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 397 – Tháng 6/2011.
2. Đảng cộng sản Việt Nam (2021): *"Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*", Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.
3. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bản dịch BLDS Pháp, Hà Nội, 2018.
4. Gouverment Général De l'Indochine (Phủ Toàn quyền Đông Dương, thuộc Pháp), Code Civil à l'usage des Juridictions Indiènes du Tonkin - Bộ Dân luật thi hành tại các Tòa Nam án Bắc kỳ, Hà Nội, 1931.
5. Hoàng Việt Trung kỳ Hộ Luật, Nxb. Tiếng Dân, Huế, 1944.
6. Hoàng Phê (chủ biên), *Từ điển tiếng việt*, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, tr. 132, 214.
7. Hoàng Thị Kim Quế, Ngô Huy Cương, Tập quán pháp ở Việt Nam hiện nay, Văn hóa pháp luật những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng chuyên ngành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.21-215.
8. Huình-Tịnh Paulus Của, Đại Nam Quấc Âm Tự Vị, SaiGon, 1895, tr.176.
9. Huỳnh Thị Kim Lan, Cao Thị Mỹ Duyên, Bàn về cầm cố tài sản là QSDĐ và nhà ở, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, HCMCOUJS- Kỷ yếu, 17 (2), tr.74.
10. Jonh Stuart Mill (1863), Utilitarianism, Batoche Book, Kitchener, Canada, edited by George Sher (2001), tr.96.
11. Lê Hồng Hạnh, Bản chất pháp lý của QSDĐ trong pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 8/2017, tr. 23.
12. Lê Thị Thu Thủy, Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ - nhìn từ góc độ lý luận, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 18 (370), tháng 9/2018.
13. Lê Văn Đức, Tự điển Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1970, tr.208.
14. Lê Vũ Nam, Giáo trình Pháp luật về Bảo đảm nghĩa vụ, Hà Nội, 2020.
15. Lý Văn Toán, Nguyễn Trường Thọ, *Giao dịch cầm cố QSDĐ: Thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật*, Tạp chí Công Thương số 16, 2019, tr. 14 – 18.
16. Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật Hợp đồng, Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2013, tr.27.
17. Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023.
18. Nguyễn Như Ý (chủ biên), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1996, tr.1014.
19. Nguyễn Quang Tuyến, *Vài suy nghĩ về sở hữu toàn dân đối với đất đai*, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 1 (2016), tr.12.

20. Nguyễn Thị Tuyết Mai, *Áp dụng tập quán trong giải quyết các vụ việc dân sự của TAND ở Việt Nam hiện nay*, Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014.

21. Phan Trung Hiền, *Lý luận về Nhà nước và Pháp luật*, Quyển 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2020, tr. 62.

22. Phan Trung Hiền (chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*, Nxb Đại Học Cần Thơ, năm 2017, tr.93.

23. Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân. 2022, *Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại vùng ĐBSCL*, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58. 170-181.

24. Phan Trung Hiền, Hugh D. Spitzer. 2023. VIETNAM'S "ENTIRE PEOPLE OWNERSHIP" OF LAND: THEORY AND PRACTICE. University of Pennsylvania Asian Law Review. 19. 1-26.

25. Phạm Duy Nghĩa, *"Sửa đổi luật đất đai để bảo vệ tốt hơn quyền tài sản của các chủ sở dụng đất*", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 2+3 (2020), tr.48 – 55.

26. Phùng Thị Ánh Xuân, *Tập quán cố đất ở ĐBSCL - lý luận và thực tiễn*, Luận văn cử nhân Luận, Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ, năm 2011.

27. Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử Thông Giám Cương mục – Chính biên – Quyển IV, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr. 165.

28. Sỹ Hồng Nam, *Pháp luật về góp vốn bằng QSDĐ*, Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2016, tr.119.

29. Sỹ Hồng Nam, "*Hợp đồng mua bán tài sản có điều kiện chuộc lại và giải quyết tranh chấp tại Tòa án*", Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số tháng 01/2012.

30. Toà án nhân dân tối cao, *Giải đáp số 16/1999/KHXX ngày 01 tháng 02 năm 1999 về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng*, 1999.

31. Trương Kim Phụng, Nguyễn Hoàng Chương, *Một số vướng mắc về việc tuyên bố vô hiệu hợp đồng cầm cố QSDĐ do vi phạm điều cấm của luật và hướng hoàn thiện*, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô, số 16/2022, tr. 108 – 118.

32. Vũ Hào Quang, Về lý thuyết hành động xã hội của M. Weber, Tạp chí Xã hội học, Số 1 (57), 1997.

33. Vũ Văn Mẫu, *Dân luật khái luận*, Nxb Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1960.

34. Vũ Văn Mẫu, *Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn giảng*, Nxb Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1975.

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

35. Bùi Ai Giôn, *Bàn về cầm cố QSDĐ và quyền sở hữu trí tuệ*, Tạp chí điện tử Kiểm sát, https://kiemsat.vn/ban-ve-cam-co-quyen-su-dung-dat-va-quyen-so-huu-tri-tue-63955.html [truy cập 17/3/2024].

36. Đặng Hùng Võ, Vận hành chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong cơ chế thị trường, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương,

https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/nghien-cuu-trao-doi/bai-1-van-hanh-che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-trong-co-ch.html [truy cập ngày 09-10-2024].

37. Liên Đăng Phước Hải: *Kinh nghiệm phát triển các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ngoài luật định tại Nhật Bản và một số gợi mở cho Việt Nam*, https://phaply.net.vn/kinh-nghiem-phat-trien-cac-bien-phap-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-ngoai-luat-dinh-tai-nhat-ban-va-mot-so-goi-mo-cho-viet-nam-a257609.html, Tạp chí điện tử Pháp Lý, [truy cập ngày 03/3/2024].

38. Bích Phượng – Hồng Ngọc: *QSDĐ có được cầm cố không?*, https://tapchitoaan.vn/quyen-su-dung-dat-co-duoc-cam-co-khong, Tạp chí TAND điện tử, [truy cập ngày 03/3/2024].

39. Nhà pháp luật Việt - Pháp: *Tổng hợp một số quy định pháp luật Cộng hòa Pháp về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự*, Báo điện tử Chính phủ, https://baochinhphu.vn/tong-hop-mot-so-quy-dinh-phap-luat-cong-hoa-phap-ve-cac-bien-phap-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-dan-su-102117768.htm [truy cập ngày 03/3/2024].

40. Nguyễn Tấn Hoàng Hải, Nguyễn Phương Ân, Hoàn thiện quy định về tập quán trong giải quyết vụ việc dân sự, Tạp chí TAND điện tử, https://tapchitoaan.vn/hoan-thien-quy-dinh-ve-ap-dung-tap-quan-trong%C2%A0giai-quyet-vu-viec-dan-su10570.html [truy cập 01/12/2024].

41. Tạp chí Lào - Việt, BLDS nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2018 (bản dịch), https://tapchilaoviet.org/phap-luat/thu-vien-phap-luat/bo-luat-dan-su-nuoc-chdcnd-lao-nam-2018-41169.html [truy cập 03/3/2024].

42. Truyền hình Đồng Tháp, Pháp luật không thừa nhận cố đất (17/9/2020), https://www.youtube.com/watch?v=ypCakJCNIG4 [truy cập 20/10/2024].

43. Vũ Văn Phúc, *Sở hữu toàn dân về đất đai: Tất yếu lịch sử trong điều kiện nước ta hiện nay*, Tạp chí Cộng sản điện tử, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/20654/so-huu-toan-dan-ve-dat-dai--tat-yeu-lich-su-trong-dieu-kien-nuoc-ta-hien-nay.aspx [truy cập 09-10-2024].

44. Kênh YouTube VTV24, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 21/10/2024, https://www.youtube.com/watch?v=BnvDIWGe5eQ [truy cập 01/12/2024].

DANH MỤC VĂN BẢN

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 1980.
2. Hiến pháp năm 1992.
3. Hiến pháp năm 2013.
4. BLDS năm 1995.
5. BLDS năm 2005.
6. BLDS năm 2015.
7. Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018.
8. Luật Đất đai năm 2024.
9. Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.
10. Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành BLDS về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
11. Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 08/8/1992 của TAND tối cao và VKSND tối cao hướng dẫn việc giải quyết các tranh chấp về nợ hụi.

B. VĂN BẢN KHÁC

12. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
13. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.